

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º incisos I a XI, § 3º)

Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º incisos XII a XXXVI)

Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º incisos XXXVI a LXXVIII)

Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º incisos I a XI, § 3º)

Direitos e Garantias Individuais

Antes de iniciarmos o estudo dos direitos e garantias fundamentais na espécie, é importante recordar que o art. 5º da Constituição traz quatro parágrafos que estabelecem condições aplicáveis aos direitos e garantias individuais e coletivos, e que precisamos incorporar ao nosso estudo.

Dois deles já comentamos: o § 1º do art. 5º define que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais **têm aplicação imediata**. Entretanto, nem todas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem eficácia plena ou imediata. Algumas constituem normas de **eficácia limitada**, que necessitam de complementação legislativa para sua plena aplicabilidade ou **eficácia contida ou restringível**, que podem ter sua eficácia reduzida ou restringida pelo legislador.

Art. 5º.....

.....

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Entretanto, o §1º do art. 5º aplica-se, via de regra, a **todas as normas** de direitos e garantias fundamentais. Na realidade, em termos semânticos, pouca distinção existe entre aplicabilidade e aplicação da norma e a confusão fica por conta dos doutrinadores. Mas para a prova, precisamos distinguir, fazer o quê? A **aplicabilidade** diz respeito à possibilidade de a norma produzir ou não seus imediatos efeitos (eficácia da norma).

Para o **ex-juiz Sérgio Moro**, a melhor interpretação do art. 5º, § 1º, da Constituição (**aplicação imediata**), é a que **autoriza o juiz a suprir as omissões** do Poder Público, para que este aplique imediatamente os direitos e garantias fundamentais, em relação àqueles catalogados no art. 5º, da CF, em sua maioria compostos por direitos de liberdade, defesa e participação; os direitos situados fora do catálogo não estariam ao abrigo do referido §1º, mas sim sob a tutela do Princípio de Interpretação da Máxima Efetividade Constitucional (**MORO, Sérgio Fernando. Desenvolvimento e efetivação judicial das normas constitucionais. São Paulo, Max Limonad, 2001**).

Ingo Wolfgang Sarlet, ao enfrentar esse tema, afirma que a inovação mais significativa da CF/88 no campo dos direitos fundamentais foi justamente o §1º do art. 5º, de acordo com o qual as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata, **excluindo, em princípio, o caráter programático destes preceitos**, mas **não há consenso quanto ao alcance desse dispositivo**. O que é certo é a consagração do **status jurídico diferenciado e reforçado** dos direitos fundamentais na Constituição, inclusive com a sua inclusão no rol das cláusulas pétreas, do art. 60, § 4º.

Assim, os direitos e garantias fundamentais foram elevados à condição de normas jurídicas **diretamente aplicáveis**, capazes de gerar efeitos jurídicos. Sarlet alerta que, apesar de inexistir norma constitucional destituída de eficácia jurídica, o princípio da aplicação imediata outorga uma **"juridicidade reforçada"** a esta categoria específica de normas constitucionais (**SARLET, Ingo Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 10 ed. rev. atual. e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009. p. 66 e 73**).

Ressalte-se que quando o autor refere-se a direitos fundamentais como "cláusulas pétreas", está se referindo, decerto, aos **direitos e garantias individuais mais proeminentes**, albergados pelo art. 60, § 4º, não somente os constantes do catálogo do art. 5º, da Constituição Federal:

Art. 60.....

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

.....

IV - os direitos e garantias individuais.

Também o § 2º define que os direitos e garantias expressos na Constituição **não excluem outros** decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, notadamente tratados e convenções internacionais de **Direitos Humanos**.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Vamos então ver os outros dois parágrafos.

O **§ 3º** do art. 5º da CF estabelece o seguinte:

Art. 5º.....

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

É dizer, a Constituição Federal ampliou as possibilidades de estabelecer novos direitos fundamentais com **status constitucional**, não só por meio de emendas à Constituição mas também por intermédio de **Tratados e Convenções internacionais de Direitos Humanos**, desde que estes sejam aprovados pelo mesmo quórum de aprovação das emendas à Constituição, estabelecidas no art. 60, § 2º:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

(...)

§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

Vamos aproveitar para estudar as regras concernentes aos tratados internacionais de que o Brasil é signatário, e que cairão na sua prova.

O processo de incorporação dos tratados internacionais na ordem jurídica interna perpassa as seguintes fases:

I - **Assinatura** do Tratado pelo **Presidente da República** (art. 84, VIII, CF), em sua função de **Chefe de Estado**; o Presidente pode fazer reservas ao Tratado durante o processo de negociação ou após a ratificação pelo Poder Legislativo;

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

.....

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional ;

II - O Presidente da República envia **Mensagem ao Congresso Nacional** encaminhando a minuta de Tratado e sua justificativa;

III - O **Congresso Nacional**, mediante **Decreto Legislativo** (art. 49, I, CF) aprova o Tratado Internacional, iniciando-se o processo na Câmara dos Deputados e terminando no Senado Federal, cuja promulgação é feita pelo Presidente do Senado. Caso o Congresso rejeite o Tratado, expede comunicação ao Presidente da República, mediante Mensagem.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional ;

IV - Após a promulgação do Decreto Legislativo, o **Presidente da República está autorizado a editar o Decreto Presidencial**, que ratificará e promulgará definitivamente o texto do Tratado, dando a ele executóriedade no plano nacional, e obrigando o Brasil no âmbito do seu direito positivo, com força de **lei ordinária**. Ou seja, a ratificação é derivada de um ato complexo, fruto da conjugação de vontades do Executivo e Legislativo.

Com relação aos **tratados internacionais de direitos humanos**, após pressões internacionais derivadas de sucessivas condenações do Estado brasileiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o processo de incorporação sofreu algumas modificações em relação aos tratados em geral:

1º) Via de regra, os tratados e convenções internacionais são incorporados ao ordenamento jurídico pátrio com força de **lei ordinária**.

2º) Caso versem sobre **direitos humanos**, os tratados assim internalizados assumem caráter de **supralegais**, ou seja, no confronto com a legislação infraconstitucional (leis complementares, ordinárias, medidas provisórias, resoluções do Congresso etc), os **tratados prevalecem**, revogando legislação interna, no que lhe for contrária, e estabelecendo diretrizes para a legislação futura. Ou seja, **acima da legislação ordinária mas em nível abaixo da Constituição** (**dentre vários, o RE 349.703, RE 466.343 e HC 87.585**).

Ficam, desse modo, em **uma posição intermediária** entre as leis e a Constituição Federal.

Foi o que ocorreu com o **Pacto de San José da Costa Rica** (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), cujo art. 7º.7 derogou disposições infraconstitucionais que autorizavam a **prisão do depositário infiel**, quais sejam o **art. 319 do Código de Processo Penal e o art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.866/1993**, neste caso a prisão do depositário infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, apesar de esta prisão estar autorizada pelo art. 5º, LXVII, da CF/88. O tratado em questão foi **firmado em 1969** e promulgado internamente **em 1992**, pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 1992.

Estabelece o inciso LXVII, do art. 5º, da Constituição Federal:

Art. 5º.....

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

A referida Convenção só permite a prisão civil na hipótese de **inadimplemento voluntário e inescusável de pensão alimentícia**. A esse respeito, o STF assentou:

"Há o caráter especial do Pacto Internacional dos Direitos Civis Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ratificados, sem reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado o lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo **supralegal** dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação" (**HC 95.967, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, julg. em 11/11/2008**).

"desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O *status* normativo **supralegal** dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do CC de 1916 e com o DL 911/1969, assim como em relação ao art. 652 do novo CC (Lei 10.406/2002)" (**RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes, julg. 3/12/2008, Plenário**)

Como consequência, foi editada a **Súmula Vinculante 25/STF**: *É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.*

Entretanto, o caráter supralegal **não derroga as disposições constitucionais**, que continuam integralmente válidas e vigentes.

Outro exemplo de tratados que se sobrepõem à legislação ordinária são os que regem a responsabilidade das companhias aéreas de passageiros (indenização por perda de bagagens etc), nos termos do art. 178 da Constituição e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O STF se pronunciou no sentido de que a Convenção de Varsóvia se sobrepõe ao CDC nas questões de responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros:

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (**RE 636.331, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento 25/5/2017, Plenário, Tema 210**).

Mas neste caso, os tratados em questão não gozam de estatura normativa supralegal de acordo com a orientação firmada no RE 466.343, uma vez que seu conteúdo não versa sobre a disciplina dos direitos humanos. Sendo assim, a antinomia deve ser solucionada pela aplicação ao caso em exame dos critérios ordinários, que determinam a prevalência da lei especial em relação à lei geral e da lei posterior em relação à lei anterior.

3º) Hipótese do § 3º do art. 5º da Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004, em que os tratados de direitos humanos são aprovados em cada Casa do Congresso Nacional pelo mesmo quórum diferenciado das emendas constitucionais, o que os torna **equivalentes às normas da Constituição**, em sentido **material**:

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Até 2016, o único tratado atualmente nessa condição era a **Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo**, assinada em Nova York, em 30 de março de 2007, e incorporada com status de Emenda à Constituição pelo Decreto Legislativo 6.949/2009, que em seu preâmbulo consigna:

Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007;

Esse tratado foi promulgado pelo **Decreto Presidencial 6.949, de 25/8/2009**.

Entretanto, o Brasil ratificou, por meio do **Decreto Legislativo 261, de 25 de novembro de 2015**, o **Tratado de Marraquexe para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas para Pessoas Cegas**, aprovado em junho de 2013, no âmbito da conferência diplomática da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) realizada na cidade marroquina que dá nome ao documento.

Referido Decreto também foi aprovado pelo Congresso Nacional seguindo o rito do § 3º, do art. 5º, da Constituição Federal, tendo sido publicado ainda o **Decreto Presidencial 9.522, de 8/10/2018**. O tratado entrou em vigor em **30/9/2016**, com a adesão ao Tratado do 20º país, o Canadá, em junho/2016:

O Congresso Nacional decreta: Art. 1º Fica aprovado, nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, o texto do Tratado de Marraquexe para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso, celebrado em Marraquexe, em 28 de junho de 2013.

Todos os tratados internacionais firmados pelo Estado brasileiro sujeitam-se à autoridade da Constituição da República, podendo, por conseguinte, ser declarados inconstitucionais, mesmo aqueles incorporados com status de emenda à Constituição. É isso que se depreende, inclusive, de julgados do Supremo Tribunal Federal:

"Supremacia da Constituição da República sobre todos os tratados internacionais. O exercício do treaty-making power, pelo Estado brasileiro, está sujeito à observância das limitações jurídicas emergentes do texto constitucional. Os tratados celebrados pelo Brasil estão subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Nenhum valor jurídico terá o tratado internacional, que, incorporado ao sistema de direito positivo interno, transgredir, formal ou materialmente, o texto da Carta Política" (**MI 772 AgR, rel. min. Celso de Mello, julg. 24/10/2007**).

Embora alguns Ministros do Supremo defendam ou defendessem a posição de que **todos os tratados de direitos humanos** teriam status constitucional (os Ministros Celso de Mello, Cezar Peluso, Eros Grau e Ellen Gracie), a posição oficial e majoritária do STF é de que os tratados internacionais de direitos humanos subscritos pela República Federativa do Brasil possuem **status Supralegal**, ou seja, **acima da legislação ordinária mas em nível abaixo da Constituição**. Essa corrente majoritária, como vimos, admite dar a eles status de constitucionalidade, **se votados pela mesma sistemática das emendas constitucionais** pelo Congresso Nacional, ou seja: maioria de três quintos, em dois turnos de votação, conforme previsto no parágrafo 3º, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 ao artigo 5º da Constituição Federal" (**dentre vários, o RE 349.703, RE 466.343 e HC 87.585**).

Já o **§ 4º do art. 5º**, estabelece que "o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão." Perceba que não é **Tribunal Constitucional** Internacional e sim **Tribunal Penal**! Este dispositivo é cobrado nas provas literalmente não oferecendo maiores dificuldades.

Art. 5º.....

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

Em julho de 1998, foi aprovado pelas Nações Unidas o **Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional**, com sede em Haia, na Holanda.

O Brasil aderiu ao Tratado, assinando-o em 7/2/2000, ratificando-o por meio do Decreto Legislativo 112/2002 e promulgando-o internamente através do Decreto 4.388/2002, do Presidente da República.

Nos termos do preâmbulo do Estatuto de Roma, um dos objetivos dos Estados-Partes, ao criar um tribunal penal internacional de caráter permanente, foi o de **processar e julgar crimes de maior gravidade** que afetem a comunidade internacional como um todo, como os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão.

Bem, agora podemos finalmente adentrar nos direitos e garantias fundamentais **na espécie**. Trata-se de uma das vertentes mais importantes do Direito Constitucional, e também das mais cobradas em concurso; portanto, você precisa guardar os conceitos e os princípios que serão apresentados neste capítulo.

Princípio da Igualdade

Estabelecido no caput do art. 5º da CF/88 e em seu inciso I:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
(...)

Se o caput do art. 5º refere-se aos **estrangeiros residentes no Brasil**, o STF, por intermédio de uma interpretação **conforme à Constituição** (sem alteração de texto), ampliou a abrangência do termo "estrangeiros residentes no Brasil", para alcançar **todo e qualquer estrangeiro** que estiver em território brasileiro, mesmo em trânsito, que gozarão dos direitos e garantias individuais, podendo inclusive fazer uso dos remédios constitucionais (*writs*), tais como mandado de segurança, habeas corpus e outros. Nesse sentido,

"O súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do *status libertatis* e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do *due process*. O súdito estrangeiro, mesmo o não domiciliado no Brasil, tem plena legitimidade para impetrar o remédio constitucional do *habeas corpus*, em ordem a tornar efetivo, nas hipóteses de persecução penal, o direito subjetivo, de que também é titular, à observância e ao integral respeito, por parte do Estado, das prerrogativas que compõem e dão significado à cláusula do devido processo legal" (**HC 94.477, rel. min. Gilmar Mendes, julg. 6.9.2011, 2ª Turma**).

Alguns desses direitos, entretanto, como a **ação popular**, são restritos aos **cidadãos brasileiros**, ou **portugueses equiparados** (art. 12, § 1º, CF) que devem comprovar, inclusive, essa condição, que dentre outros requisitos, exige a regularidade eleitoral (alistamento, comprovante de votação).

O princípio da **igualdade** é a base fundamental do princípio republicano e do Estado Democrático de Direito, sendo **norma de eficácia plena cuja aplicação é imediata e incondicionada**. Dele decorrem inúmeros outros princípios e preceitos constitucionais, dentre eles:

- I) Proibição ao racismo (art. 5º inciso XLII);
- II) Proibição de diferença de salários, exercício de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, cor ou estado civil (art. 7º, XXX);
- III) Exigência de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II);
- IV) Princípio da isonomia nas licitações públicas (art. 37, XXI);
- V) Princípio da isonomia tributária (art. 150, II);
- VI) Igualdade de jurisdição - proibição de tribunal de exceção (art. 5º, XXXVII).



Fique ligado!

Importante entendimento do STF a respeito da aplicação desse princípio, diz respeito ao seu alcance, em algumas vertentes importantes:

I - **Igualdade na lei**: alcança o Estado-Legislator, que ao fixar normas gerais e abstratas, inovando no mundo jurídico, não poderá fazê-lo de forma desarrazoada e desproporcional entre os indivíduos.

II - **Igualdade perante a lei**: atinge o Estado-Juiz e o Estado-Administrador, que ao aplicar as normas ao caso concreto, não poderá estabelecer tratamento anti-isonômico.

"O princípio da isonomia (...) – cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do poder público – deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (RDA 55/114), sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei; e (b) o da igualdade perante a lei. A igualdade na lei – que opera numa fase de generalidade puramente abstrata – constitui exigência destinada ao legislador que, no processo de sua formação, nela não poderá incluir fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. A eventual inobservância desse postulado pelo legislador imporá ao ato estatal por ele elaborado e produzido a eiva de inconstitucionalidade." **(STF, MI 58, rel. p/ o ac. min. Celso de Mello, julg. 14/12/1990)**

III - As chamadas **políticas de discriminação reversa ou de ação afirmativa do Estado** consistem em medidas adotadas pelo Estado para inclusão de grupos sociais historicamente periféricos, e que se encontrem em situação de desvantagem ou desigualdade, com vistas a assegurar o princípio constitucional da igualdade, vertido em seu aspecto social ou material, como direitos fundamentais de segunda dimensão.

Exemplos dessas medidas são a reserva de **vagas em concursos públicos para portadores de necessidades especiais, cotas raciais em universidades e outros processos seletivos públicos, e a proteção especial às mulheres**.

As discriminações positivas são albergadas pelo nosso Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não contraria – ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, assentado no caput do art. 5º da Constituição, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que alcançam um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, atribuindo a estes determinadas vantagens, por prazo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades e vulnerabilidades decorrentes de situações históricas particulares.

Entretanto, o STF entende que as políticas afirmativas não devem se converter em benesses vitalícias, instituídas em prol de determinados grupos sociais em detrimento da coletividade como um todo, situação que se mostraria incompatível com o espírito de qualquer Constituição democrática, devendo as mesmas respeitarem a proporcionalidade entre os meios e os fins perseguidos, e uma vez alcançados os objetivos para os quais foram propugnadas, serem suprimidas ou substituídas por medidas de menor intervenção. (**Dentre outros, ADPF 186, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 26-4-2012; RE 597.285, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-5-2012; ADI 3.330, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 3-5-2012**)

IV - proteção à mulher: a Constituição estabeleceu tratamento especial às mulheres em determinadas situações, a fim de assegurar a igualdade de direitos e obrigações entre os sexos, nos termos da Constituição (art. 5º, I), como por exemplo, a proteção do trabalho da mulher (art. 7º, XX), e a aposentadoria antecipada das mulheres por tempo de serviço público (art. 40, § 1º, III), aposentadoria pelo regime geral de Previdência (art. 201, § 7º), dentre outros:

Art. 5º....

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Art. 40....

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

...

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo; (Redação da EC 103/2019)

Art. 201...

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições;

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; (Redação da EC 103/2019)

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Redação da EC 103/2019)

V - proibição genérica de acesso a carreiras públicas em função da idade: as hipóteses legítimas de limitação de idade para acesso a cargos públicos devem se justificar como imposição de natureza e das atribuições do cargo a preencher. Nesse sentido, o STF editou a **Súmula 683**:

"O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido"

VI – Igualdade nas relações homoafetivas e entidade familiar: O STF reconhece a união homoafetiva como **entidade familiar**, que merece proteção estatal, seguindo-se as mesmas regras da união estável heteroafetiva. É o reconhecimento do direito de orientação sexual sem embargo do **direito à constituição de família**. Da mesma forma, o STJ reconheceu que a concepção de casamento deve ser plural, pois plurais são as famílias.

"6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA "INTERPRETAÇÃO CONFORME"). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de "interpretação conforme à Constituição". Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva." (STF, ADPF 132, rel. min. Ayres Britto, julg. em 5/5/2011)

Ainda no direito à igualdade entre homens e mulheres, cumpre enfatizar que além dos tratamentos diferenciados entre homens e mulheres previstos na própria Constituição (art. 7º, XVIII e XIX, 40, §1º, 143, §§ 1º e 2º, 201, § 7º), pode a legislação infraconstitucional também atenuar as diferenças de tratamento em razão de gênero. Nesse sentido, conforme assentado pelo Supremo, a imposição de discriminação para fins de participação em concurso público só é compatível quando demonstrada a proporcionalidade e a **legalidade** da imposição, em razão da natureza do cargo (RE 528.684/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes). É o caso, por exemplo, de presídios femininos/masculinos, institutos de internação de menores.

Não se esqueça que, assim como na discriminação por idade, **o edital, por si só, não poderá estabelecer restrições de gênero**, mas sim **a lei de regência do cargo**.

Ufa! Quanta coisa sobre o princípio da igualdade não é? Pois é e estamos apenas começando...



Veja como foi cobrado!

(CESPE/TJDFT/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2015) Diante da

inaplicabilidade de analogia com a legislação referente às relações estáveis heteroafetivas, é vedado o reconhecimento *post mortem* de união homoafetiva.

ERRADA. Segundo recente jurisprudência do STJ, na esteira do que já vem decidindo o STF, à união homoafetiva é dispensado o mesmo tratamento conferido à união de heterossexuais, de sorte que, para ambos, devem estar disponíveis os mesmos instrumentos processuais destinados ao reconhecimento da entidade familiar, como a ação de reconhecimento de união homoafetiva *post mortem*.

(CESPE/DELEGADO POLÍCIA FEDERAL/1997) Considere a seguinte situação: a assembléia legislativa de um estado da federação aprovou lei, que veio a ser sancionada pelo governador, criando o título de Benfeitor do Estado, a ser outorgado por ato do chefe do Poder Executivo e que conferiria ao respectivo portador certas vantagens e privilégios, como alíquotas tributárias reduzidas e pontos adicionais em concursos públicos e licitações. Na situação descrita, a despeito da aparente ofensa ao princípio da igualdade, esta, na verdade, não foi ferida, porquanto a Constituição Federal consagra a igualdade perante a lei, que é dirigida aos aplicadores da lei, mas não a igualdade na lei, direcionada ao legislador.

ERRADA. Questão antiga mas muito atual. A Constituição Federal estabeleceu expressamente o princípio da igualdade perante a lei, no caput do art. 5º, direcionado ao Estado-Juiz e ao Estado-Executor, mas também de forma implícita o princípio da igualdade na lei, destinado ao legislador positivo (Estado-Legislator) e mesmo ao constituinte derivado, que deve assegurar a isonomia no exercício da função legislativa.

Princípio da Legalidade

O princípio da legalidade, também chamado de legalidade ampla, não se confunde com o princípio da legalidade para o setor público, tampouco com o princípio da reserva legal ou legalidade estrita.

O princípio da **legalidade ampla**, ou legalidade **para o cidadão**, enunciado em sua versão mais genérica no art. 5º, II, prescreve que:

Art. 5º.....

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

"Lei" aqui entenda-se **tanto a lei em sentido formal**, aprovada pelo processo legislativo das leis, como atos com força de lei e **atos regulamentares** expedidos nos limites da lei (resoluções, portarias, decretos), além **dos atos normativos das Casas Legislativas** (Resoluções, decretos legislativos) e **dos órgãos do Poder Judiciário** (regimentos internos). Lei aqui está no sentido lato senso, de norma jurídica.

Já o princípio da **reserva legal** ou **legalidade estrita**, exige a edição de **lei em sentido estrito ou atos equiparados** (medidas provisórias, resoluções do Senado e da Câmara, decretos legislativos do Congresso Nacional, decreto autônomo), como por exemplo, a exigência de lei para estabelecimento das hipóteses de interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII); a exigência de lei para fixação da remuneração dos servidores do poder executivo (art. 37, X); as regras para aquisição da nacionalidade brasileira, que deverão ser previstas em lei (art. 12, II, a).

Consoante lição de José Afonso da Silva, o **princípio da legalidade** significa a submissão e o respeito **à lei e aos atos normativos em geral**, a atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador e no poder amplo e geral que a Constituição outorga sobre qualquer espécie de relações. Todavia, quando a Constituição reserva conteúdo específico, caso a caso, de determinadas matérias que deverão ser necessariamente ser reguladas **por lei formal** ou **atos equiparados** (medida provisória, lei complementar, decreto autônomo) encontramos-nos diante do princípio da **reserva legal** (SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 38ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 425).

Em resumo, temos as seguintes características para os princípios da legalidade e da reserva legal:

Legalidade	Reserva Legal
Vocábulo "lei" empregado em sentido amplo (norma jurídica em geral)	Vocábulo "lei" empregado em sentido estrito - estrito senso (lei formal)
Engloba as leis e os atos administrativos que as regulamentam	Só admite lei ou ato normativo com força de lei (ex: medida provisória, decreto legislativo do Congresso Nacional, decreto autônomo)
Alcance amplo	Alcance restrito
Menor densidade normativa	Maior densidade normativa

O princípio da legalidade para o **setor público** assume uma outra conotação, na medida em que, se para o particular é permitido fazer tudo o que a lei não proíba, para o administrador público é **defeso (proibido) agir sem respaldo expresso da lei**.

Tratando agora das nomenclaturas comumente presentes em concursos, o princípio da legalidade ou legalidade ampla abrange um número maior de matérias constitucionais, possuindo, portanto, uma **maior abrangência**, maior amplitude. Já o princípio da legalidade estrita ou reserva legal abrange um menor número de matérias, mas com maior conteúdo, importância, maior garantia frente ao Estado, sendo pacífico considerar que este princípio possui uma **maior densidade**.

Por fim, cabe aqui também fazer uma distinção entre **lei em sentido formal** e **lei em sentido material**. O princípio da reserva legal exige a edição de lei em **sentido formal**, ou seja, a norma que obedeceu ao processo legislativo de elaboração das leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas ou leis complementares.

Entretanto, pode acontecer que a matéria tratada nessa lei **não tenha caráter materialmente legal**, caráter que pode ser resumido na expressão **GIA – Geral, Impessoal e Abstrata**. Portanto, não serão leis em sentido material. Mas qual a relevância disso?

Bem, durante algum tempo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as normas que não atendessem ao critério "GIA - generalidade, impessoalidade e abstração", não obstante ostentasse, a forma de lei, constituem as chamadas **leis de efeitos concretos**, verdadeiros **atos administrativos em sentido material**, e estariam **imunes ao controle abstrato de constitucionalidade** (v.g., **lei orçamentária anual, lei que autoriza instituição de empresa pública, sociedade de economia mista, ou que cria autarquia e fundação**).

No entanto, **o STF reverteu essa posição**, tendo decidido que o controle abstrato de constitucionalidade não se confunde com a concretude do ato legislativo, e **admitiu o controle de constitucionalidade das leis de efeitos concretos**.



Veja como foi cobrado!

(CESPE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TJ-RO/2012) O princípio da legalidade é mais amplo que o princípio da reserva legal, que é restrito e concreto.

CERTO. O princípio da legalidade abrange todas as espécies normativas admitidas em direito, sendo, por isso, mais abrangente e mais amplo. Já o princípio da reserva legal só admite a lei em sentido formal, aprovada como tal pelas Casas Legislativas, e por isso mais restrito e de maior densidade normativa.

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

Desdobramento de um dos fundamentos da República (art. 1º, III), este princípio está insculpido também nos incisos III e XLVII do art. 5º:

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

XLVII - não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

O inciso XLVII será melhor visto junto com o **princípio da individualização da pena**. Trata-se de uma das normas constitucionais de caráter penal.

Ainda como desdobramento da dignidade da pessoa humana, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a alteração de nome e gênero no assento de registro civil mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. O Supremo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade para dar à lei dos registros públicos (Lei 6.015/1973) interpretação conforme a Constituição Federal e a pactos internacionais que tratam dos direitos fundamentais, de modo a reconhecer aos transexuais, que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil, sendo desnecessários a autorização judicial e os requisitos propostos de maioria ou outros que limitem a proteção da identidade de gênero autopercebida (**ADI 4.275, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 1º/3/2018**).

Por seu turno, a partir do Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos), em seus artigos 1º e 18, resulta que a interpretação dada pelo STF é consentânea com o direito à não discriminação por motivo de sexo e o direito ao nome:

Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos

1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.

Artigo 18 - Direito ao nome

Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário.



Veja como foi cobrado!

(**ESAF/ANALISTA ADMINISTRATIVO/AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS/2009**) O uso de algemas só é lícito em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada previamente a excepcionalidade por escrito.

ERRADO. Questão maldosa, que remete ao princípio da dignidade da pessoa humana e à Súmula Vinculante 11 do STF: "*Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado*".

Ou seja, qual o erro da questão? A justificativa das algemas por escrito não necessita ser **prévia**, podendo ser lavrada posteriormente.

Liberdade de pensamento e suas limitações

A liberdade de manifestação do pensamento é um direito fundamental, e como todos os demais, **não é absoluto**. Previsto no art. 5º, inciso IV, além do art. 220, essa liberdade tem seu temperamento ou suas limitações/regulações previstas, de uma maneira ou de outra, na própria Constituição da República, no mesmo artigo 5º, incisos V (direito de resposta proporcional ao agravo e indenização por dano material, moral ou à imagem), X (inviolabilidade da intimidade e da vida privada) e XXXIII (direito de acesso à informação, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado), além do art. 220, § 3º, I (regular as diversões e espetáculos públicos, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada).

Na verdade, o próprio inciso IV já estabelece limitações ao vedar o anonimato;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

Trata-se de regra sem destinatários definidos, já que qualquer pessoa, em princípio, pode manifestar o que pensa, desde que não o faça sob o manto do anonimato. A proibição do anonimato tem por objetivo proteger eventuais destinatários da manifestação de juízos caluniosos, ofensivos ou depreciativos.

Ainda como decorrência dessa vedação do anonimato, não é possível ainda, regra geral, o acolhimento de denúncias anônimas, conforme já confirmado em arestos do STF. Assentou ainda a Suprema Corte a possibilidade de utilização do *habeas corpus* para trancamento de ação penal, por requisição do Ministério Público, fundada unicamente em **denúncia anônima**.

Segundo o STF, a delação anônima, enquanto fonte única de informação, não constitui fator que se mostre suficiente para legitimar, de modo autônomo, sem o concurso de outros meios de revelação dos fatos, a instauração de procedimentos estatais. É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Resolução STF nº 290/2004 – que instituiu o serviço de Ouvidoria – expressamente vedou a possibilidade de formulação de reclamação, críticas ou denúncias de caráter anônimo determinando a sua liminar rejeição (**HC 97.197, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 2/10/2009**).

Na mesma linha, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o **MS 24.405/DF, do Rel. Min. Carlos Velloso**, declarou, “*incidenter tantum*”, a inconstitucionalidade da expressão “manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia” constante do § 1º do art. 55 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/92). Em virtude da decisão do STF, o Senado Federal, de forma estranhamente rápida, diga-se de passagem, editou a Resolução de nº 16/2006, que suspendeu a manutenção do sigilo em relação à autoria de denúncias, garantido na Lei Orgânica do TCU e no Regimento Interno, dando efeitos *erga omnes* à decisão do Supremo.

A justificativa do Supremo para tal entendimento é que os documentos apócrifos ofenderiam o princípio da dignidade da pessoa humana, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando eventual indenização por danos morais ou materiais, contrariando essas garantias previstas nos incisos V e X do art. 5º.

Entretanto, entende a mesma Corte, ser possível a utilização dos fatos colhidos na denúncia para a abertura de **investigação autônoma**, seja por parte da autoridade policial, do Ministério Público, seja no âmbito do Tribunal de Contas da União, quando então poderão ser confirmados de *per si* as alegações trazidas pelo denunciante, mas nunca a utilização da denúncia ou das provas trazidas diretamente pelo denunciante anônimo, sob pena de nulidade do processo.

Por isso, o STF deixou assentadas as seguintes conclusões:

(a) os escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da *persecutio criminis*, eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que materializem o *crimen falsi*, p. ex.);

(b) nada impede, contudo, que o poder público provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da *persecutio criminis*, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas;

(c) o Ministério Público, de outro lado, independentemente da prévia instauração de inquérito policial, também pode formar a sua *opinio delicti* com apoio em outros elementos de convicção que evidenciem a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de sua autoria, desde que os dados informativos que dão suporte à acusação penal não tenham, como único fundamento causal, documentos ou escritos anônimos. (**Inq 1.957, rel. min. Carlos Velloso, voto do min. Celso de Mello, julgamento em. 11/5/2005**).

Já o inciso V estabelece o **direito de resposta proporcional ao agravo**, no âmbito do qual pode haver ainda a cumulação de indenizações pela ofensa (material, moral e de imagem):

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

Guarde essas posições relativas à **jurisprudência do STF e do STJ** quanto a esta garantia fundamental:

I - pode haver indenização por danos morais, oriundas de lesões deformantes;

II - pode haver indenização por danos morais ou à imagem praticado pela imprensa, bem como direito de resposta, pautados pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mas não pode haver censura prévia;

III - o direito de liberdade de expressão não consagra o direito de incitação ao racismo ou outras formas de discriminação;

IV - o direito de resposta não pode ensejar a violação da intimidade, da vida privada e da honra do agressor.

V - Ao julgar a **ADPF 130/2009**, o STF declarou a não-recepção de dispositivos da Lei de Imprensa, afastando a prática de qualquer controle prévio sobre a liberdade de imprensa e expurgando indevidas limitações infraconstitucionais ao exercício desse direito.

VI - O mesmo Supremo Tribunal, no julgamento do **RE 683.751/RS**, Rel. Min. Celso de Mello, reconheceu que a incompatibilidade da Lei de Imprensa com a vigente Constituição da República não impede, consideradas as razões que expõe, que qualquer interessado, injustamente atingido por publicação inverídica ou incorreta, possa exercer, em juízo, o direito de resposta. Entendeu o Relator que o art. 5º, inciso V, da Constituição assegura direito de resposta proporcional ao dano, além de indenização. Assim, tal dispositivo teria **aplicabilidade imediata**.

VII - Mais recentemente ainda, em 16/12/2015, o ministro Dias Toffoli, do STF, concedeu medida cautelar a fim de garantir ao magistrado integrante de tribunal a **prerrogativa de suspender, em recurso, o direito de resposta sem manifestação prévia de colegiado**. A decisão foi tomada na ADI 5415, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, e afasta a interpretação literal do artigo 10 **da Lei 13.188/2015, sancionada pela Presidente Dilma Rousseff quatro dias antes**, a qual atribui a colegiado a competência para conceder efeito suspensivo a recurso contra decisão que assegura o direito de resposta. O STF entendeu **assimétrica** a possibilidade de um juiz apenas conceder o direito de resposta e o recurso contra esse direito depender de colegiado do Tribunal.

VIII - Referida **Lei 13.188/2015**, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é que **regulamenta o inciso V do art. 5º, da Constituição Federal**.

IX - Se inicialmente os direitos fundamentais surgiram como tendo titulares as pessoas naturais, pessoas físicas, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido direitos fundamentais às pessoas jurídicas, tais como o direito ao nome, à honra, e mesmo em favor do Estado, como o direito de propriedade. Nesse sentido, o STF assentou que pessoa jurídica pode ser vítima de difamação, mas não de injúria ou calúnia (**RHC 83.091/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 26/9/2003**). São direitos que atingem, direta ou indiretamente, a atividade institucional da pessoa jurídica. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido também direitos fundamentais às pessoas jurídicas de **direito público**:

"A imposição de restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do 'due process of law', assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária" (**AC 2.032-QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, julg. 15/5/2008**).

Importante ainda você saber que o **STJ** (e não o STF) assentou que pessoa jurídica pode sofrer dano moral por violação da honra ou da imagem, inclusive de acordo com o **Enunciado de Súmula 227** do STJ:

Súmula 227/STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"

X - Curiosamente, entretanto, o Supremo Tribunal Federal afirmou a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos morais, mas que tal direito não alcança nível constitucional a viabilizar a abertura da via extraordinária, ou seja, o conhecimento de recurso extraordinário pelo Supremo (**RE 221.250-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 06/04/01**).

O inciso IX do art. 5º, juntamente com o art. 220 reforçam o direito de liberdade de manifestação do pensamento e de informação, **vedando qualquer tipo de censura:**

Art. 5º, IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

XI - Entretanto, não confunda censura **com classificação indicativa** de programas de televisão, vídeos ou películas cinematográficas, que devem ter efeito classificativo e indicativo, principalmente para controle de conteúdo inadequado a crianças e adolescentes. Esse tema estava sendo discutido no âmbito do STF (**ADIn 2404/DF, julgamento em 31/8/2016**), notadamente quanto ao modelo de controle a ser adotado - público estatal, auto-regulação pelas emissoras ou co-regulação e foi assim decidido:

"(...) Não há horário autorizado, mas horário recomendado. Esse caráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao sistema de classificação, *data venia*, não se harmoniza com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da República. (...) 4. Sempre será possível a responsabilização judicial das emissoras de radiodifusão por abusos ou eventuais danos à integridade das crianças e dos adolescentes, levando-se em conta, inclusive, a recomendação do Ministério da Justiça quanto aos horários em que a referida programação se mostre inadequada (...) 5. Ação direta julgada procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão “em horário diverso do autorizado” contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90”.

Art. 21. Compete à União: XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão ;

XII - O STF declarou **inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias**, dando interpretação conforme à Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença de pessoa biografada, relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas) (**ADI 4.815, rel. Min. Cármen Lúcia, jul. em 10/6/2015**).



Veja como foi cobrado!

(CESPE/AUDITOR FISCAL/SEFAZ ES/2013) A CF assegura a liberdade de manifestação de pensamento, sem excluir a responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes do seu exercício e sem afastar o direito de resposta para rebater qualquer tipo de ofensa, e não apenas aquelas configuradoras de ilícitos penais.

CERTO. Questão que está de acordo com os incisos IV e V do art. 5º, e da jurisprudência do STF, que admite o direito de resposta para oferecer réplica a qualquer ofensa, e não apenas os crimes contra a honra tipificados no Código Penal.

(FCC/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/SEFAZ/SP/2010) No que se refere à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas é certo que:

- a) a dor sofrida com a perda de ente familiar não é indenizável por danos morais, porque esta se restringe aos casos de violação à honra e à imagem.
- b) a indenização, na hipótese de violação da honra e da intimidade, não responde cumulativamente por danos morais e materiais.
- c) a condenação por danos morais face à divulgação indevida de imagem, exige a ocorrência de ofensa à reputação da pessoa.
- d) o Estado também responde por atos ofensivos (morais) praticados pelos agentes públicos no exercício de suas funções.
- e) as pessoas jurídicas, por serem distintas das pessoas físicas, têm direito a indenização por danos materiais, mas não por danos morais.

Gabarito: **Alternativa d.** O item A está errado pois a perda de ente querido é ofensa moral, não tendo conteúdo patrimonial, e devendo ser indenizável por danos morais; o item B está errado pois pode haver cumulação de indenizações; o item C está errado pois a imagem é conceito distinto da honra, podendo sofrer indenização independente; o item D está certo pois trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva do Estado; o item e está errado, pois as pessoas jurídicas têm igualmente assegurado o direito ao nome, à honra e à imagem, podendo ser indenizadas por danos a elas causados (Súmula 227 do STJ)

Liberdade de consciência, credo ou filosofia e escusa de consciência

A liberdade de crença religiosa e de convicção política e filosófica está estabelecida no **art. 5º, incisos VI, VII e VIII.**

Art. 5º.....

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

O Brasil é um Estado **laico ou secular**, isto é, que **não possui religião oficial**. Perceba que Estado laico não é o mesmo que Estado ateu, ou que proíbe o exercício de qualquer culto, como o eram os regimes totalitários comunistas. **Estado laico** é o Estado que não tem religião oficial, mas que assegura a liberdade de crença e de convicção religiosa. **Estado confessional** é o que reconhece determinada denominação religiosa como religião oficial do Estado. **Estado teocrático** é aquele cujas normas políticas, civis e mesmo jurídicas são submetidas a regras religiosas, como ocorre em alguns Estados islâmicos. O Brasil teve um Estado **confessional**, por exemplo, até a vigência da Constituição Imperial de 1824, que em seu art. 5º, estabelecia:

Art. 5: A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casa para isso destinadas, sem fórmã alguma exterior de Templo.

A CF, no **art. 5º, VII**, assegura ainda a prestação de **assistência religiosa** em presídios, hospitais e outras unidades de internação coletiva:

Art. 5º....

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

Com relação à eficácia dessa norma há divergências; parte da doutrina (Alexandre de Moraes) encara esse dispositivo como norma de **eficácia limitada**, por conta da expressão “nos termos da lei” (**MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional 31ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 50**). De outra vertente, Pedro Lenza a indica como norma de **eficácia contida** (**LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, 16ª ed. 2012, p. 219**).

As normas de eficácia contida são dotadas de aplicabilidade **imediata** (porque estão aptas para produzir efeitos imediatamente, com a simples promulgação da Constituição); **direta** (porque não dependem de nenhuma norma regulamentadora intermediária para a produção de efeitos); mas **não integral** (porque sujeitas à imposição de restrições).

Já as norma de eficácia limitada são dotadas de aplicabilidade **mediata** (só produzirão seus efeitos essenciais posteriormente, depois da regulamentação por lei); **indireta** (não asseguram, diretamente, o exercício do direito, dependendo de norma regulamentadora intermediária para tal); e **reduzida**.

Efetivamente, a **Lei 9.982/2000** regulamentou a referida norma constitucional, ao dispor sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares, bem como a **Lei 6.923/1981**, que dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas e que foi recepcionada pela CF/88:

Lei 9.982/2000: Art. 1º *Aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus familiares no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Parágrafo único. (vetado)*
Art. 2º *Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no art. 1º deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional.*
Art. 3º *(vetado)*
Art. 4º *O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias.*

Lei 6.923/1981: Art . 1º - O Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas - SARFA será regido pela presente Lei.
Art . 2º - O Serviço de Assistência Religiosa tem por finalidade prestar assistência Religiosa e espiritual aos militares, aos civis das organizações militares e às suas famílias, bem como atender a encargos relacionados com as atividades de educação moral realizadas nas Forças Armadas.
....
Art . 4º - O Serviço de Assistência Religiosa será constituído de Capelães Militares, selecionados entre sacerdotes, ministros religiosos ou pastores, pertencentes a qualquer religião que não atente contra a disciplina, a moral e as leis em vigor.

Mas ainda que não houvesse tal frase, o legislador ordinário poderia estabelecer restrições, observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e pela máxima de que não há direitos fundamentais de natureza absoluta. Os que defendem a posição de **eficácia contida** entendem que hospitais ou casas de internação não poderiam recusar

assistência religiosa a seus internos pela ausência de lei disciplinando a prática, não obstante a lei pudesse estabelecer balizas e limites.

Agora veja estas questões do Cespe/Unb:

(CESPE/2016/TRT-8ª Região/Analista Judiciário/Serviço Judiciário) é correto afirmar que o art. 5º, VII, da Constituição constitui norma de aplicabilidade imediata. Gabarito: **correto**.

(CESPE/2016/DEPEN/Agente Penitenciário) Segundo a Constituição Federal de 1988, é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Entretanto, tal norma é de eficácia limitada, pois depende de complementação de lei ordinária ou complementar para ser aplicada. Gabarito: **correto**.

(CESPE/2014/Polícia Federal/Nível Superior) A prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva pode ser considerada exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. Gabarito: **correto**.

Note que as normas de **eficácia limitada** possuem **aplicabilidade mediata**, não obstante os direitos e garantias fundamentais possuam **aplicação** imediata, nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição Federal. As normas de eficácia **contida** é que possuem **aplicabilidade imediata**, não obstante **não integral**. Portanto, a **questão do TRT de 2016** adotou a vertente da **eficácia contida**. São termos similares, que causam controvérsia doutrinária. Entretanto, para a prova, são importantes!

Entretanto, nas duas outras questões o Cespe indicou a norma como sendo de **eficácia limitada**. Mas e aí Jean, como diria Rui Barbosa, eu levo ou deixo a galinha? Reze!!!

Peço agora sua licença para nos atermos aqui ao inciso VIII do art. 5º:

VIII - Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

O dispositivo em comento consagra o direito à denominada “escusa ou objeção de consciência”, sendo que a consequência do não cumprimento da prestação alternativa, está no art. 15, IV:

*Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
(...)
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;*

Trata-se de uma norma constitucional de **eficácia contida**, porquanto a escusa de consciência é plenamente exequível, sem consequências para o indivíduo, até que fosse editada a lei que estabeleça quais as prestações alternativas ao cumprimento de determinadas obrigações, que na hipótese, é a **Lei 8.239/1991**.

Uma vez editada tal lei, o indivíduo terá de cumprir as obrigações alternativas, para que não sofra privação de direitos.

Também o art. 210, § 1º, da Constituição Federal trata do **ensino religioso** em escolas públicas:

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

A respeito do ensino confessional nas escolas públicas do País, o Supremo julgou **improcedente a ADI 4.439** por maioria apertada (6 x 5), decidindo que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras **pode ter natureza confessional**, ou seja, vinculada a uma ou outra religião específica. A PGR pedia a interpretação conforme a Constituição para que fosse proibida a admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas, e que sendo tal disciplina facultativa, deveria ser voltada para a história e doutrina das várias religiões, sob uma perspectiva laica. Entretanto, a posição majoritária consignou que:

"A laicidade do Estado brasileiro não impediu o reconhecimento de que a liberdade religiosa impôs deveres ao Estado, um dos quais a oferta de ensino religioso com a facultatividade de opção por ele. (...) o modelo de laicidade adotado no Brasil compreende uma abstenção do Estado, impedindo que se favoreçam corporações religiosas ou que se prejudiquem indivíduos em razão de suas convicções ou impeça a liberdade de expressão religiosa. Mas abrange, também, por expressa previsão constitucional, condutas positivas do poder público, entre as quais a permissão de aporte de recursos públicos a escolas confessionais comunitárias, a isenção de impostos, que em seu entendimento pode ser vista como um fomento à liberdade de expressão religiosa (**ADI 4.439, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julg. em 27/9/2017**).

Segundo a Presidente do STF, Cármen Lúcia, que votou pela improcedência da Ação, "todos estão de acordo com a condição do Estado laico do Brasil, a tolerância religiosa, bem como a importância fundamental às liberdades de crença, expressão e manifestação de ideias".

Já o art. 150, IV, b, prevê a imunidade tributária **de impostos** sobre **templos de qualquer culto**:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes; (**Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023**)

Importante ainda comentar sobre o § 4º do art. 150:

*§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as **finalidades essenciais das entidades** nelas mencionadas.*

É dizer, se determinada agremiação religiosa não pode se utilizar de sua condição para se isentar do pagamento de tributos sobre atividades não ligadas à finalidade essencial da agremiação – comércio, rede de televisão comercial, indústria ou outra atividade.

Inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X)

Estabelece o inciso X do art. 5º:

Art. 5º.....

.....

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Você pode perguntar: Jean, mas qual a diferença deste inciso e o inciso VI, que estudamos lá atrás? Bem, aqui o conceito é um pouco mais amplo, porque trata da intimidade e da vida privada, gênero que abrangem importantes espécies como o sigilo bancário e fiscal, assuntos que vamos tratar a seguir.

Segundo o STF, para condenações por dano moral, **não se exige** a comprovação de ofensa à reputação do indivíduo, mas a mera publicação não consentida de fotografias, escritos ou outros registros desabonadores, que gerem desconforto ou constrangimento, geram para o lesado o direito à reparação.

Estão incluídas nessa proteção tanto as pessoas físicas quanto jurídicas, e a expressão “ou moral” não é excludente, isto é, poderá haver cumulação de condenações. Para condenação em **dano material**, é **indispensável** a comprovação da ocorrência do dano.

O STJ decidiu que sobrevivendo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o **dano moral**, passível de indenização, inclusive quanto aos danos estéticos. Também o STF tem decidido que não afronta o princípio da legalidade a reparação de **lesões deformantes** a título de dano moral.

Em relações às ações civis de investigação de paternidade, o STF firmou orientação reconhecendo a **impossibilidade de coação** do pai para realização do exame de DNA, porque essa medida implicaria ofensa a garantias constitucionais explícitas e implícitas, como a preservação da dignidade humana e da intimidade, além da inexecução específica e direta da obrigação de fazer.

"INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DNA - CONDUÇÃO DO RÉU "DEBAIXO DE VARA". Discrepa, a mais não poder, de garantias constitucionais implícitas e explícitas - preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer - provimento judicial que, em ação civil de investigação de paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório, "debaixo de vara", para coleta do material indispensável à feitura do exame DNA". (HC 71.373, rel. min. Francisco Rezek, red. p/ o acórdão min. Marco Aurélio, P, j. 10/11/1994)

Em outra decisão, o STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à extração do **perfil genético de criminosos perigosos** (Tema 905), pendente de julgamento definitivo e definição de tese, relator do Min. Gilmar Mendes, envolvendo suposta violação de direitos da personalidade e da prerrogativa de não se incriminar:

"Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direitos fundamentais. Penal. Processo Penal. 2. A Lei 12.654/12 introduziu a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético na execução penal por crimes violentos ou por crimes hediondos (Lei 7.210/84, art. 9-A). (...) Possível violação a direitos da personalidade e da prerrogativa de não se incriminar – art. 1º, III, art. 5º, X, LIV e LXIII, da CF. 3. Tem repercussão geral a alegação de inconstitucionalidade do art. 9-A da Lei 7.210/84, introduzido pela Lei 12.654/12, que prevê a identificação e o armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos. (RE 973.837 RG / MG, rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 23/6/2016)

O entendimento do STF é de que o sigilo fiscal e bancário é espécie do gênero direito à privacidade, inerente à personalidade das pessoas físicas e jurídicas, sob o albergue, portanto, do inciso X do art. 5º. Idas e vindas na jurisprudência do STF alteraram o entendimento sobre a possibilidade de quebra do sigilo bancário e fiscal, sendo que o Tribunal somente considerava, até pouco tempo, possível a quebra de sigilo bancário:

I - por determinação judicial;

II - pelo Poder Legislativo, mediante determinação aprovada pelo Plenário das Casas, Comissões Parlamentares ou Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs):

"A fundamentação exigida das **Comissões Parlamentares de Inquérito** quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida" (**MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julg. 29/9/2004, Plenário**).

Decisão recente do STF, superando o entendimento anterior, assentou que operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. Em tais situações, **é prerrogativa constitucional do Tribunal de Contas da União o acesso a informações relacionadas a operações financiadas com recursos públicos**. (**MS 33.340, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 26-5-2015, Primeira Turma, DJE de 3-8-2015**).

Questão tormentosa diz respeito à possibilidade da quebra de sigilo por **agentes do fisco** no exercício da atividade de fiscalização. A jurisprudência do STF inicialmente admitia e depois afastou a possibilidade de a quebra de sigilo fiscal e bancário por agentes da receita, ainda que no curso de processo administrativo fiscal, sem autorização judicial. Esse entendimento foi assentado em **sede de controle difuso, notadamente no julgamento do Recurso Extraordinário 389.808/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio**.

Entretanto, **em 2016**, houve nova reviravolta na jurisprudência do Supremo, quando do julgamento conjunto de um recurso extraordinário e de 4 ações diretas de inconstitucionalidade (**RE 601.314, rel. min. Edson Fachin e ADIs 2.859, 2.390, 2.386 e 2.397, rel. min. Dias Toffoli, julg. em 24/2/2016**). O STF, por maioria, entendeu constitucionais dispositivos da Lei 105/2001 que **permitem à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos**. O Relator dos processos, **Dias Toffoli**, destacou, em seu voto, que não se trata propriamente a quebra de sigilo bancário, o que pressupõe a circulação desses dados, mas sim a **transferência desse sigilo** dos bancos ao **agentes do Fisco**, e que a lei prevê severas punições ao servidor público que vazar essas informações.

Perfilhou o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em **transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros**. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não haveria ofensa à Constituição Federal. Assentou a constitucionalidade do art. 6º da LC 105/2001:

Art. 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

Na prática, para sua prova, considere como **a última posição vigente ser possível a quebra de sigilo bancário por agentes da Receita (fisco)**.

Além disso, guarde que o STF assentou no Tema 990 de repercussão geral e possibilidade de os serviços de inteligência financeira da Receita Federal **compartilharem** as informações colhidas com os órgãos de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial:

É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. **(RE 1.055.941, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em: 4-12-2109, Tema 990.)**

Segundo o STF, **estados, DF e municípios** também poderão se valer dos dispositivos da Lei Complementar, **com relação aos seus agentes fiscais**, com algumas condições:

"somente poderão obter as informações previstas no artigo 6º da LC 105/2001, uma vez regulamentada a matéria, de forma análoga ao Decreto Federal 3.724/2001, tal regulamentação deve conter as seguintes garantias: **pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado; a prévia notificação do contribuinte quanto a instauração do processo e a todos os demais atos; sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico; existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso; estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios.**"



Fique ligado!

Como as bancas têm sido muito voláteis a qualquer decisão divergente do STF, guarde para sua prova, neste momento, a certeza da possibilidade da quebra de sigilo bancário e fiscal determinada:

- i) pelo **Poder Judiciário**
- ii) pelo **Poder Legislativo** (Plenário, Comissões e **CPI**), na sua função fiscalizatória (**MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julg. 29/9/2004, Plenário**)
- iii) **pelo Tribunal de Contas da União, quando estiverem em jogo recursos do erário** (**MS 33.340, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 26-5-2015, Primeira Turma, DJE de 3-8-2015**).
- iv) pelos **agentes da fiscalização tributária**. (**RE 601.314, rel. min. Edson Fachin e ADIs 2.859, 2.390, 2.386 e 2.397, rel. min. Dias Toffoli, julg. em 24/2/2016**)
- v) **Ministério Público**, excepcionalmente, quando envolver recursos públicos (**RHC 133.118, relator Min. Dias Tóffoli, julgamento em 26/9/2017**).

Existia **dúvida** quanto à possibilidade de o **Ministério Público** determinar a quebra de sigilo bancário, quando o processo envolver recursos públicos. Apesar de haver precedentes nesse sentido (STF/MS 21.729-DF), há julgados do próprio Supremo (INQ 2245/MG) e do STJ (HC 160.464/SP) **afastando essa prerrogativa** do *parquet*. Em 2017, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que o Ministério Público tem legitimidade para requisitar, diretamente às instituições financeiras, **informações bancárias de município**, notadamente por envolver **recursos e contratos públicos**. Segundo o Relator, Min. Dias Tóffoli:

"o poder do MP de requisitar informações bancárias de conta corrente da prefeitura compreende, por extensão, o acesso aos registros das operações bancárias realizadas por particulares a partir das verbas públicas creditadas naquela conta, a fim de se ter acesso ao real destino dos recursos públicos" **(RHC 133.118, relator Min. Dias Tóffoli, julgamento em 26/9/2017)**

Outro entendimento do STF que você deve guardar é que a quebra de sigilo bancário de **congressista**, no âmbito de investigação criminal, só pode ser adotada no âmbito de procedimento investigatório em curso perante o **Supremo Tribunal Federal** (CF, art. 102, I, "b"), Órgão judiciário competente para tal. É esse o entendimento consolidado do STF (**dentre outros julgados, Rcl 511/PB, Rel. Min. Celso de Mello**). Portanto, não pode o juiz de primeiro grau fazê-lo. Nesse sentido, assentou o Supremo:

O STF, sendo o juiz natural dos membros do Congresso Nacional nos processos penais condenatórios, é o único órgão judiciário competente para ordenar, no que se refere à apuração de supostos crimes eleitorais atribuídos a parlamentares federais, toda e qualquer providência necessária à obtenção de dados probatórios essenciais à demonstração de alegada prática delituosa, inclusive a decretação da quebra de sigilo bancário dos congressistas.

Guarde, entretanto, que apesar de o TCU deter, agora, a **prerrogativa de determinar a quebra de sigilo bancário** quando houver **operações financeiras que envolvam recursos públicos federais**, conforme mencionamos (**MS 33.340, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 26-5-2015, Primeira Turma, DJE de 3-8-2015**), isso **não significa, entretanto, que o Tribunal está autorizado determinar a quebra de sigilo bancário de congressista**, portanto **permanece vigente o julgado anteriormente referido**, especificamente relativo aos parlamentares, até que o Supremo depare-se com um caso concreto da espécie, para aí então termos uma posição definitiva sobre o tema.



Veja como foi cobrado!

(CESPE/PROCURADOR/BANCO CENTRAL DO BRASIL/2013) No exercício da atividade de controle de contas, o TCU tem competência legal para impor a quebra de sigilo bancário de dados constantes do BACEN.

ERRADO. Como vimos, a prerrogativa para determinar a quebra de sigilo bancário cinge-se aos membros e órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Legislativo (Plenário e Comissões), com a divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de o Ministério Público fazê-lo quando o processo envolver a investigação do desvio de recursos públicos. Entretanto, considerando a **nova jurisprudência do STF**, esta questão seria no mínimo **ANULADA** ou considerada **CERTA** pois o TCU tem competência para quebra de sigilo bancário quando o processo envolver investigação de desvio de recursos públicos federais.

(FCC/ANALISTA LEGISLATIVO/ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS/2014) Câmara dos Deputados mediante requerimento de 181 de seus 513 membros, instala Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, com vistas a apurar, em determinado prazo, supostas irregularidades na execução de contratos de fornecimento de refeições para presídios mantidos pelo Governo federal. Para dar início a suas atividades, a CPI pretende convocar o Ministro de Estado da pasta responsável pelos estabelecimentos prisionais, para que preste esclarecimentos, bem como determinar a quebra de sigilo bancário de um servidor do primeiro escalão do Ministério, que figura como indiciado, diante da existência de fortes elementos de que teria se apropriado irregularmente de parte dos recursos que seriam destinados ao pagamento das refeições. Nessa hipótese, a CPI

- a) atende aos requisitos constitucionais quanto ao requerimento para instalação e objeto, bem como dispõe de poderes investigatórios para a prática dos atos pretendidos.
- b) não poderia ter sido instalada, uma vez que não foi observado o quorum mínimo estabelecido pela Constituição da República para seu requerimento.
- c) não poderia ter sido instalada, uma vez que seu objeto não atende aos requisitos estabelecidos na Constituição da República, para investigação parlamentar.
- d) não poderá convocar o Ministro de Estado para prestar esclarecimentos, por não se incluir esta faculdade entre seus poderes de investigação.

e) não poderá determinar quebra de sigilo bancário do servidor indiciado, por se tratar de matéria sujeita à reserva jurisdicional.

Gabarito: **alternativa a**. Excelente questão. A CPI foi criada atendendo aos critérios constitucionais (iniciativa de 1/3 dos membros = 171 parlamentares), constantes do § 3º do art. 58, bem como detém a prerrogativa de determinar a quebra de sigilo bancário de investigado, no âmbito das investigações a que procede.

Inviolabilidade domiciliar

Determina o art. 5º, inciso XI:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Esta é a regra, e como, sempre, o que vale para o concurso é a interpretação do STF para o inciso em comento. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a busca e apreensão em domicílio, o que inclui o domicílio profissional, só pode ser determinada por ordem judicial, e durante o dia:

"Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público, ainda que vinculado à administração tributária do Estado, poderá, contra a vontade de quem de direito (*invito domino*), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, sob pena de a prova resultante da diligência de busca e apreensão assim executada reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude material". (**HC 93.050, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 10/6/2008, 2ª Turma**).

Nesse sentido, o conceito de “casa” abrange qualquer recinto, seja de natureza residencial, seja de **natureza profissional**, permanente ou temporária.

“A garantia da inviolabilidade domiciliar como limitação constitucional ao poder do estado (...) – conceito de ‘casa’ para efeito de proteção constitucional – amplitude dessa noção conceitual, que também compreende os espaços privados não abertos ao público, onde alguém exerce atividade profissional. Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo de ‘casa’ revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III)” (**HC 82788, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 12/04/2005**)

Incluem-se aí, **apartamentos de hotel, casa de praia, embarcação, consultório médico, escritório de advocacia, inclusive lojas e estabelecimentos não franqueados ao público (balcão, suporte, back-office)**.

Segundo o Supremo Tribunal Federal,

"O conceito de "casa", para os fins da proteção constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da CF ("XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;"), reveste-se de caráter amplo e, por estender-se a qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, compreende o **quarto de hotel ocupado por hóspede**" (**RHC 90.376/RJ, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 3/4/2007**).

Especificamente quanto a veículos, a doutrina enfatiza a necessidade do mandado judicial, quando estes se destinem à residência do investigado:

"Busca em veículo: o veículo (automóvel, motocicleta, navio, avião, etc.) é coisa pertencente à pessoa, razão pela qual deve ser equiparada à busca pessoal, sem necessitar de mandado judicial. A única exceção fica por conta do veículo destinado **a habitação do indivíduo**, como ocorre com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros" (**NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed., pág. 552**).

A relevância deste dispositivo reside na extinção do antigo mandado de busca e apreensão determinada por autoridade administrativa – policial, fazendária ou fiscal -, sem a devida autorização judicial.

Mesmo em caso de flagrante delito, o ingresso forçado de autoridade policial em domicílio, inclusive para **apreensão de objetos de crime, independentemente de autorização judicial**, é condicionado à demonstração de fundada suspeita de ocorrência de crime no local, conforme já se pronunciou o STF:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". (**RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 5/11/2015**)

O difícil é justamente configurar a situação de flagrante delito ocorrendo no interior da residência. No caso concreto apreciado pelo Supremo, foram encontrados 8,5kg de cocaína em veículo de propriedade do cidadão, estacionado na garagem. A indicação do local foi dada por motorista de caminhão preso em flagrante por transportar o restante da droga. Assim, de acordo com entendimento majoritário do Plenário do STF e nos termos da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), guardar entorpecentes em depósito constitui crime permanente, que caracteriza a condição de flagrante delito exigida pelo inciso XI do art. 5º da Constituição.

De outra vertente, mas na mesma perspectiva, em 2017, o STF **extinguiu processo penal** contra réu que teve casa vasculhada por policiais sem mandado judicial. Nesse caso, a prisão em flagrante e a denúncia apresentada contra o acusado o enquadraram no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), mesmo que tenham sido encontradas apenas 8 gramas de crack e 0,3 gramas de cocaína. Além disso, não foi encontrado, na residência, qualquer instrumento que indique a prática de tráfico, como balanças, dinheiro ou anotações. Segundo o ministro Celso de Mello, a busca realizada sem mandado judicial só seria justificada **por uma fundada suspeita da prática de crime**, o que não se verificou no caso, revelando assim a ocorrência de flagrante ilicitude (**HC 138.565, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julg. em 18/4/2017**).

Por derradeiro, guarde que o **mandado judicial de busca e apreensão** só poderá ser cumprido **durante o dia**, independentemente do consentimento do morador ou do dono do estabelecimento profissional. Nesse sentido, os **agentes da fiscalização fazendária**, podem, no exercício de suas atribuições, proceder à busca e apreensão de documentos ou informações comprobatórias de crime fiscal, ainda que sem ordem judicial, havendo necessidade, entretanto, de **consentimento** do proprietário para adentrar no estabelecimento. Assim há muito tem entendido o STF, no sentido de que o ingresso no domicílio, sempre que necessário vencer a oposição do morador, passa a depender de **autorização judicial prévia** (**HC 79.512, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, julg. em 16/12/1999**). Dessa forma, a apreensão de livros contábeis e documentos fiscais em estabelecimento comercial, sem autorização do proprietário, carece de qualquer validade.

Assim, não havendo consentimento dos proprietários ou possuidores, as autoridades **administrativas, fiscais, fazendárias, trabalhistas, sanitárias, ambientais e mesmo membros do Ministério Público**, somente poderão adentrar nas dependências dos administrados se munidos de **ordem judicial autorizativa** (mandado judicial de busca e apreensão) e **desde que durante o dia**.

Ainda que diante de fortes indícios de que, no interior do estabelecimento, haja provas comprobatórias da ocorrência de ilícitos, se não houver consentimento, não poderá o agente administrativo executar a busca e apreensão, sem autorização do Poder Judiciário.

Entendimento do STF, cobrado de forma recorrente nas provas, diz respeito à possibilidade de ingresso em recinto profissional protegido pela inviolabilidade domiciliar para **instalação de equipamentos de escuta ambiental**, durante o dia ou **à noite**, desde que haja ordem judicial para tanto, no caso concreto.

É que o STF admitiu provimento judicial (oriundo de Ministro do próprio STF) que autorizou o ingresso de autoridade policial em **recinto profissional durante a noite**, no caso em questão, **escritório de advocacia**, para o fim de instalar **equipamentos de captação acústica (escuta ambiental)**.

Observou-se que essa instalação de equipamentos de escuta não poderia ser realizada com publicidade, afinal de contas, ficaria frustrada sua finalidade.

No caso concreto, ponderaram-se os bens jurídicos em conflito e admite-se o procedimento, tendo como de fundo os valores da proteção à intimidade, à privacidade e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a instalação de escuta ambiental em escritórios vazios não se sujeitaria **estritamente** aos mesmos limites da busca em domicílios stricto sensu (em que haveria pessoas habitando). Diante disso, **desde que existente a autorização judicial**, poderia ser admitida essa atuação do Estado, seja para execução durante o dia, seja para execução durante a noite. (**Inq 2.424/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 19 e 20.11.2008**).

E o que significa “durante o dia”? Trata-se de um critério **astronômico** e não temporal, motivo pelo qual considera-se **dia** a partir de e enquanto o céu estiver **claro**.



Veja como foi cobrado!

(**CESPE/OFICIAL POLÍCIA MILITAR/PM CE/2014**) De acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a casa, domicílio, que constitui o objeto de proteção da garantia da inviolabilidade consagrada pelo texto constitucional é todo o espaço delimitado que determinado indivíduo utiliza para uso residencial ou profissional. Dessa forma, um simples quarto de hotel ou um escritório podem ser abrangidos pela referida proteção constitucional.

CERTO. Segundo o STF, o conceito de "casa" para proteção constitucional do inciso XI do art. 5º e art. 150, § 4º, II, do Código Penal, compreende os aposentos de habitação coletiva, como por exemplo, os quartos de hotel, pensão, hospedaria, desde que ocupados, bem como os locais reservados ao exercício da atividade profissional.

Inviolabilidade das correspondências e comunicações

Garantia fundamental prevista no art. 5º, XII:

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Trata-se de um inciso muito valorizado pelas bancas e com farta jurisprudência recente. Prescreve o inciso ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Poderíamos ser forçados ao entendimento de que o sigilo das correspondências teria natureza absoluta. Como vimos, **não existem** direitos e garantias fundamentais de **natureza absoluta**. Entretanto, vimos que a própria Constituição Federal prevê limitações, além de outras, do sigilo de correspondência, em caso de Estado de Defesa (art. 136) e Estado de Sítio (art. 139), por parte da própria **autoridade administrativa**, isto é, sem necessidade de autorização judicial.

Nesse sentido, o **Supremo Tribunal Federal** também já se manifestou pela constitucionalidade da regra prevista no **art. 41, inciso XV da Lei 7.210/1984**, que permite a **abertura prévia das cartas de detentos (recebidas ou enviadas), quando tiver por finalidade evitar práticas ilícitas**.

Razões de segurança pública, de disciplina penitenciária ou de preservação da ordem jurídica poderão justificar, sempre excepcionalmente, e desde que respeitado o artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, a interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas" (**HC 70.814-5/SP, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 1/3/1994**).

Atualmente, essa previsão legal transformou-se quase em caricatura, dada a enorme quantidade de atos criminosos perpetrados de dentro das instituições prisionais por meio de telefonia celular.

Bom, a Constituição previu expressamente **apenas a possibilidade da violação das comunicações telefônicas**, pois são as únicas que não deixam rastro, registros. **Não existe mais** a possibilidade jurídica de gravação e armazenamento desse tipo de comunicação por parte das operadoras de telefonia. As demais espécies de comunicação deixam registros – cartas, e-mails.

Existem mecanismos legais, hoje, que possibilitam a interceptação das comunicações telefônicas ou telemáticas (telex, fax). O requisito básico para a interceptação telefônica é a **ordem judicial**, sendo matéria sujeita à chamada **reserva de jurisdição**. Outro requisito são as hipóteses e a forma autorizadas em lei, no caso, a Lei 9.296/96, que regulamenta a matéria. Só pode ser utilizada para processos cujo desfecho culmine em pena privativa de liberdade na modalidade de **reclusão**, e quando a medida mostrar-se indispensável à investigação.

Não confunda a interceptação telefônica com a **quebra de sigilo telefônico** que permite o acesso aos **dados da ligação** (quem ligou, para quem, duração, número, operadora de telefonia, horário etc) e não a transcrição das conversas. A quebra de sigilo pode ser determinada, inclusive, por comissão parlamentar de inquérito, não estando sujeita à reserva de jurisdição:

"O princípio constitucional da reserva de jurisdição – que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) – **não se estende ao tema da quebra de sigilo**, pois, em tal matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria CR (CF, art. 58, § 3º), assiste competência à CPI, para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas" (**MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, julg. em 16/09/1999**).

Não é albergada, pois, a interceptação das comunicações telefônicas, no âmbito de **processos administrativos ou cíveis**. Não há possibilidade, por exemplo, que num curso de procedimento de separação judicial ou divórcio, um dos cônjuges solicite ao magistrado a autorização para escuta telefônica do consorte, com o intuito de comprovar de infidelidade conjugal. Também não é constitucionalmente cabível a interceptação telefônica no curso de ação civil pública de improbidade administrativa.

Com relação às formas de gravação e captação de sons e comunicações, o **Prof. Luiz Flávio Gomes** (Interceptação Telefônica, ed. Revista dos Tribunais) fez a seguinte classificação:

- a) Gravação ambiental: gravação de comunicação ambiente, feita por um dos interlocutores sem o conhecimento da outra parte;
- b) Interceptação ambiental: captação de comunicação ambiente, feita por terceiro, sem a ciência dos comunicadores.
- c) Escuta ambiental: captação de comunicação ambiente, realizada por terceiro, com o conhecimento de um dos comunicadores e sem conhecimento da outra parte;
- d) Gravação telefônica: gravação da comunicação telefônica realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro;
- f) Interceptação telefônica: também chamada de interceptação em sentido estrito, é a captação da comunicação telefônica feita por um terceiro, sem a ciência dos comunicadores;
- e) Escuta telefônica: captação de comunicação telefônica por terceiro, com conhecimento de um dos comunicadores, e sem conhecimento da outra parte.

Todas essas modalidades exigem **requisição judicial** para sua execução, à exceção da escuta ambiental e da gravação telefônica realizadas em defesa própria, e feita por um dos interlocutores ou por terceiros, sem conhecimento do outro interlocutor. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento, em sede de **repercussão geral**, segundo o qual é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro (**RE 583937 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 19/11/2009**). O STF considera como excludente de ilicitude, a gravação feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, para o exercício de **defesa contra chantagem, ameaça ou outra prática criminosa** a que o interessado esteja submetido. Tal gravação ou interceptação poderá ser feita inclusive **por terceiro**, a pedido do interessado:

"Ementa: habeas corpus. Prova. Lícitude. Gravação de telefonema por interlocutor. É lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, ou com sua autorização, sem ciência do outro, quando há investida criminosa deste último. É inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Ordem indeferida" (**HC 75.338/RJ - Rel. Ministro Nelson Jobim - DJ 25/09/1998**).



Fique ligado!

Entretanto (**outra dica quantíssima para a prova**), isso não impede o **uso emprestado de provas**, ou seja, se no curso da investigação penal surja fato envolvendo servidor público, por exemplo, as provas ligadas à interceptação telefônica poderão ser utilizadas para punição do servidor, no âmbito de processo **administrativo** disciplinar, ou, ainda, no âmbito de processo **civil** de improbidade administrativa, mas apenas como **prova emprestada**, e desde que haja correlação entre o ilícito penal e as condutas apenadas nas outras esferas, **nunca** como fonte ou prova autônoma em processo civil ou administrativo. Nesse sentido, o STF

"Prova emprestada. (...) Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova". (Inq 2.424 QO-QO, rel. min. Cezar Peluso, j. 20/6/2007, Plenário)

A Primeira Turma do STF assentou que o fato de a escuta telefônica ter visado elucidar **outra prática delituosa não impede sua utilização em persecução criminal diversa** (compartilhamento de prova) (HC 128.102/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 9/12/2015).

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que é constitucional a chamada gravação de conversa, **telefônica ou ambiental**, por **um dos interlocutores**, sem o consentimento ou conhecimento por parte do outro. Em regra, essa gravação é ilícita, por ofensa à privacidade ou à intimidade (Art. 5º, X) ou das comunicações telefônicas (art. 5º, XII). Entretanto, a gravação constituirá prova lícita se um dos comunicantes estiver em situação de legítima defesa (ameaça, chantagem, coação, proposta ilícita). Dentre vários precedentes, o **RE 583.937 QO/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 19.11.2009**.

São essas as chamadas situações excludentes da **antijuridicidade** (tais como legítima defesa, estado de necessidade), em que a gravação poderá ser realizada validamente sem necessidade de autorização judicial.

Também possível, nesse caso, a gravação de conversa realizada **por terceiro**, também apenas se for utilizada em **legítima defesa de um dos interlocutores**, que poderá estar sendo vítima de uma investida criminosa.

Vale lembrar também que **Comissão Parlamentar de Inquérito(CPI) não tem** competência para determinar a **interceptação telefônica**, mas apenas e tão somente a **quebra dos registros telefônicos** – quem ligou para quem, duração das chamadas, data e hora.

Caso ocorra, no curso da investigação criminal, a descoberta **fortuita** (acidental) de crime punível com **detenção**, a utilização da prova decorrente de interceptação dependerá da conexão daquele crime com outro, punível com pena de **reclusão**.

É importante ainda lembrar que a inviolabilidade das comunicações refere-se ao **trânsito, à comunicação em si** e não aos **dados armazenados**. Assim, pode ser autorizado, no âmbito de processo cível, por exemplo, mandado de busca e apreensão de computadores e fax contendo informações passíveis de utilização como prova de ilícitos

Quanto às **prorrogações do prazo** de interceptação, a Lei 9.296/96 só permitia que o magistrado autorizasse por 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias. Entretanto, o STF autorizou **prorrogações sucessivas**, desde fundamentadas e solicitadas ao juízo competente.

Por fim, todas as interceptações deverão ser obrigatoriamente **degravadas e reduzidas a termo** (transcritas), e somente aquelas partes ou trechos **imprescindíveis** à investigação. Conversas familiares, íntimas ou que não digam respeito ao processo não deverão constar das degravações.



Veja como foi cobrado!

(CESPE/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/TJ AC/2007) A inviolabilidade do sigilo de correspondência, prevista na Constituição Federal, alcança, inclusive, a administração penitenciária, a qual não pode proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados.

ERRADO. Como sempre falamos e você vai cansar de "ouvir", **não existem** direitos e garantias de natureza **absoluta**. Dessa forma, tais regalias não podem ser utilizadas para **acobertar práticas delituosas**. Há julgados do STF que autorizam, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de prevenção da ordem jurídica, a interceptação de correspondência remetida pelos sentenciados, por parte da administração penitenciária, eis que a cláusula da inviolabilidade do sigilo epistolar (de correspondência) **não pode** constituir-se em instrumento de salvaguarda de atividades criminosas.

Liberdade do exercício de ofício ou profissão

Prescreve o inciso XIII do art. 5º que

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

Trata-se, aqui, de dispositivo de **eficácia contida**, dotado de aplicabilidade **direta e imediata**, porém sujeito a restrições estabelecidas pela lei. Nesse sentido, para que você exerça a profissão de analista de sistemas, processador de dados ou profissional comunicação e marketing não necessita comprovar a graduação em curso superior específico ou estar registrado no órgão profissional competente.

Já para exercer o ofício de médico, odontólogo ou advogado, não poderá fazê-lo senão após cumprir as exigências legais e as normas expedidas pelas autarquias profissionais que regulamentam essas profissões.

Importante jurisprudência do STF diz respeito à **profissão de jornalista**. O Supremo assentou que é **inconstitucional a exigência do diploma de jornalismo e registro profissional** no Ministério do Trabalho como condição para o exercício da profissão de jornalista. Segundo o STF, no campo da profissão de jornalista, não há espaço para a regulação estatal quanto às qualificações profissionais. A impossibilidade do estabelecimento de controles estatais sobre a profissão jornalística leva à conclusão de que **não pode o Estado criar uma ordem ou um conselho profissional (autarquia)** para a fiscalização desse tipo de profissão (**RE 511.961, rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 17/6/2019**).

Segundo o Supremo,

"O art. 5º, incisos IV, IX, XIV, e o art. 220, não autorizam o controle, por parte do Estado, quanto ao acesso e exercício da profissão de jornalista. Qualquer tipo de controle desse tipo, que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade jornalística, configura, ao fim e ao cabo, controle prévio que, em verdade, caracteriza censura prévia das liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada pelo art. 5º, inciso IX, da Constituição" (**RE 511.961, rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 17/6/2009**).

Ou seja, ao conferir quase absoluta liberdade à atividade jornalística, o STF acabou criando um paradoxo, cerceando o próprio direito da classe de estabelecer controles ou limites a si própria (curso superior específico, fiscalização mediante conselho etc).

Liberdade de acesso à informação

A fonte do jornalista será sempre sigilosa. O sigilo na fonte é resguardado quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV, CF).

Art. 5º

.....

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

A esse respeito, pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal:

A atuação do jornalista Glenn Greenwald na divulgação recente de conversas e de trocas de informação entre agentes públicos atuantes na chamada Operação Lava-Jato é digna de proteção constitucional, independentemente do seu conteúdo ou do seu impacto sobre interesses governamentais. A despeito das especulações sobre a forma de obtenção do material divulgado pelo jornalista – matéria que inclusive é objeto de investigação criminal própria –, a liberdade de expressão e de imprensa não pode ser vilipendiada por atos investigativos dirigidos ao jornalista no exercício regular da sua profissão”. (RE 511.961, rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 17/6/2009).

Liberdade de locomoção

Prevista no inciso XV, do art. 5º:

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

Trata-se de direito ligado à liberdade, direito de primeira dimensão, cuja violação oportuniza a interposição de Habeas Corpus, remédio constitucional destinado a assegurar a liberdade de ir e vir (inciso LXVIII, art. 5º).

Naturalmente, não estão amparados por este direito forças militares estrangeiras, que somente poderão transitar em território nacional caso haja permissão nesse sentido pelo Presidente da República, conforme art. 49, II e art. 84, XXII, da CF:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

Liberdade de reunião

Determina o inciso XVI do art. 5º da CF/88 que:

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

Importante ressaltar que o direito de reunião, no Estado brasileiro, **não exige autorização prévia**, o que não se confunde com a **comunicação prévia** à autoridade competente, no caso a polícia militar, sem que haja frustração de outra reunião marcada para o mesmo local.



Perigo!

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2021, que são permitidas reuniões ou manifestações em locais públicos, independentemente de comunicação oficial prévia às autoridades competentes. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário 806.339, com repercussão geral reconhecida no **Tema 855**, que fixou a seguinte tese:

"A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local"

É dizer, o Supremo entendeu que manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. A inexistência de notificação não torna ipso facto ilegal a reunião. Assentou ainda que anotificação não precisa ser pessoal ou registrada, porque implica reconhecer como necessária uma organização que a própria Constituição não exigiu. Além disso, as manifestações pacíficas gozam de presunção de legalidade, vale dizer, caso não seja possível a notificação, os organizadores não devem ser punidos por sanções criminais ou administrativas que resultem multa ou prisão (**RE 806.339/SE, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 15/12/2020**).

A votação foi por maioria, e a corrente vencida liderada pelo relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que o direito de reunião não é absoluto e que, no caso concreto, a manifestação bloqueou o trânsito na BR 101, impedindo o tráfego de automóveis e caminhões de carga. "O exercício do direito de reunião pacífica deve ser precedido de aviso à autoridade competente, não podendo implicar a interrupção do trânsito em rodovia", afirmou. Seu voto foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes.

Para combater a frustração ao direito de reunião o remédio adequado não é o habeas corpus mas sim o **mandado de segurança**, *remédio* constitucional que iremos estudar na próxima aula.

Essa reunião poderá ser estática ou dinâmica, uma passeata, uma reunião, uma manifestação, uma parada gay. O STF deu interpretação conforme a Constituição ao art. 287 do Código Penal, e ao § 2º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, para afastar qualquer entendimento no sentido de que as "**marcha da maconha**" constituem apologia ao crime. Para os ministros presentes à sessão, prevalece nesses casos a **liberdade de expressão e de reunião** (art. 5º, IV e XVI, CF). A Corte destacou, entretanto, que as manifestações devem ser lícitas, pacíficas, sem armas, e com prévia notificação da autoridade competente (**ADPF 187, rel. min. Celso de Mello, j. 15/6/2011, Plenário; ADI 4.274, rel. min. Ayres Britto, j. 23/11/2011**).

Entretanto, o STF não admite a participação de **crianças e adolescentes** nessas manifestações:

“Obviamente, o atingimento da maioria permitirá ao indivíduo, segundo a sua livre convicção, defender ou não a descriminalização das drogas. Contudo, o engajamento de **menores** em movimentos dessa natureza, esperando-se deles a defesa ostensiva do consumo legalizado de entorpecentes como a maconha, interfere indevidamente no processo de formação de sua autonomia e aponta em sentido oposto àquele sinalizado pela Constituição no art. 227, caput e § 3º, VII” (**voto do Min. Luiz Fux na ADPF 187/DF**).

Outros entendimentos importantes acerca do direito de reunião;

Segundo o STF, **não será motivo para dissolução** da reunião de alguma ou algumas pessoas estarem **portando armas**. Nesse caso, a polícia deverá agir para desarmar ou deter os portadores, prosseguindo-se a reunião com os demais participantes:

"(...) cumprindo ter presente, quanto a tal requisito, a advertência de PONTES DE MIRANDA (...) para quem “(...) a polícia não pode proibir a reunião, ou fazê-la cessar, pelo fato de um ou alguns dos presentes estarem armados. As medidas policiais são contra os que, por ato seu, perderem o direito a reunirem-se a outros, e não contra os que se acham sem armas”. (**ADPF 187/DF, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 15/6/2011**)

É inconstitucional ato normativo que vede a utilização de objetos e aparelhos sonoros em reunião:

"No acórdão paradigma da ADI nº 1.969/DF, a Corte foi instada a se pronunciar acerca da constitucionalidade de norma distrital (Decreto nº 20.098/99), que proscrevia a realização de manifestações públicas, com a utilização de carros, aparelhos e objetos sonoros na Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios e Praça do Buriti. (...) a restrição estabelecida ao direito de reunião não se compatibilizava com o postulado da proporcionalidade e seus subprincípios (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito)" (**Rcl 15.887 DF, rel. Min. Luiz Fux, julg. 19/6/2013**)

O direito de reunião pode ser qualificado como **garantia coletiva e direito individual**:

"Paolo Barile bem qualifica o direito de reunião como, simultaneamente, um direito individual e uma garantia coletiva, uma vez que consiste tanto na possibilidade de determinados agrupamentos de pessoas reunirem-se para livre manifestação de seus pensamentos, concretizando a titularidade desse direito inclusive para as minorias, quanto na livre opção do indivíduo de participar ou não dessa reunião" (**Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional - 32ª. ed. São Paulo: Atlas, 2016; p. 152-153**)

Liberdade de Associação

Dispõem os incisos XVII a XX do art. 5º da Constituição Federal:

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Tal liberdade alcança apenas as associações criadas para fins lícitos. Não poderão os cidadãos, portanto, criar uma “associação dos perseguidores de mendigos”, ou de “combate armado ao sistema que está aí”, sob pena de interferência direta ou dissolução compulsória.

Aliás, tema recorrente e que confunde os candidatos diz respeito à suspensão das atividades da associação e à sua dissolução compulsória. Somente a **dissolução compulsória** (extinção) da associação exige o **trânsito em julgado** da decisão judicial. Para a **suspensão**, basta a decisão de **primeiro grau**.

Suponha que as torcidas organizadas da “Mancha Verde” e da “Gaviões da Fiel” entrem em conflito e provoquem perturbação da ordem, agressões e mortes. O Ministério Público poderá solicitar e o juiz deferir, a **suspensão** das atividades dessas agremiações, mas a **dissolução compulsória** somente ocorrerá com o **trânsito em julgado** da decisão (art. 5º, XIX). Trânsito em julgado é aquele relativo à decisão da qual não caiba mais recurso judicial, a não ser ação rescisória, no prazo de dois anos.

Além disso, “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado” (inciso XX), o que preconiza o livre direito de participar ou **aderir**, de se **desligar** ou de se **dissolver espontaneamente** qualquer associação.

Representação processual *versus* substituição processual

Dispõe o inciso XXI do art. 5º que as “*entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente*”. Trata-se, aqui, da hipótese de **representação judicial**, na qual o titular do direito tem o direito de outorgar expressamente a terceiros, **representantes**, que o representem perante o Poder Judiciário, na defesa dos direitos do **representado**.

Em alguns casos, entretanto, a Constituição autoriza a determinadas pessoas jurídicas a denominada **legitimação ativa extraordinária**, o que caracteriza a chamada **substituição processual**. Nesses casos, o substituto processual ajuíza a ação em seu nome, mas em defesa de um direito alheio, do **substituído**, como no **mandado de segurança coletivo** (art. 5º, LXX, “b”) e de **outras ações coletivas que não obedeçam a rito ordinário**, como a ação civil pública, bastando que os **estatutos jurídicos** das entidades ali referidas autorizem a defesa do direito pleiteado pelo substituído, consoante jurisprudência do Supremo:

Art. 5º.....

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

- a) partido político com representação no Congresso Nacional;
- b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

Segundo o Supremo,

“Na oportunidade, considerado o artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, o Tribunal proclamou a indispensabilidade de prévia e específica autorização dos associados para ajuizamento de ação, por associação civil, a envolver interesses destes, sendo insuficiente a constatação de previsão genérica no estatuto. (...) Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. (...) Atendem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio (**TEMA 499 RE 612.043/PR-ED, rel. Min. Marco Aurélio, julg. em 6/6/2018**)

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. C.F., ART. 5., LXX; ART. 5., XXI. I. - A LEGITIMIDADE DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, ENTIDADES DE CLASSE OU ASSOCIAÇÕES, PARA A SEGURANÇA COLETIVA, E EXTRAORDINÁRIA, OCORRENDO, EM TAL CASO, SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. C.F., ART. 5., LXX. II. - NÃO SE EXIGE, TRATANDO-SE DE SEGURANÇA COLETIVA, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ALUDIDA NO INCISO XXI DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO, QUE CONTEMPLA HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO. III. - R.E. NÃO CONHECIDO”. (RE: 182.543 SP, Rel. Min. Carlos Velloso, julg. 29/11/1994)

“a diferença entre representação e substituição processual, a esclarecer o alcance do preceito do inciso XXI do artigo 5º, que trata da necessidade de a associação apresentar autorização expressa para agir em Juízo, em nome dos associados, e o do preceito que versa o mandado de segurança coletivo e revela o sindicato como substituto processual. Nesse último caso, a legitimação já decorre da própria Carta – representação gênero – e também da previsão do artigo 8º, do qual não me valho. Estou-me valendo apenas daquele referente às associações”. (RE 573.232/SC, rel. Min. Marco Aurélio, julg. 14/5/2014)

Constituição Federal:

Art. 8º.....

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Veja o quadro-resumo:

Representação Judicial (art. 5º, XXI)	Substituição Processual
Necessidade de autorização expressa dos associados	Desnecessidade de autorização expressa dos associados (basta autorização genérica nos atos constitutivos)
Defesa do direito dos associados em outras ações judiciais de rito ordinário ou recursos administrativos.	Defesa dos direitos dos associados mediante impetração de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 5º, LXX, e outras ações coletivas de rito especial próprio.

Em relação à legitimação do partido político com representação no Congresso Nacional, lembre-se de que basta que a agremiação política possua apenas **um representante** em quaisquer das Casas do Congresso Nacional. Assim, o STF assentou o entendimento de que a representação deve ser comprovada no momento da propositura da ação, e mesmo que o partido perca essa representação, a ação não perderá seu objeto, e poderá seguir seu curso normalmente (ADI 2.618 AgR-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, julg. 12/8/2004, Pleno). Além desse julgado:

"Ação direta de inconstitucionalidade. Partido político. Legitimidade ativa. Aferição no momento da sua propositura. Perda superveniente de representação parlamentar. Não desqualificação para permanecer no pólo ativo da relação processual. Objetividade e indisponibilidade da ação." (ADI 2.159-AgR, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 12/8/2004).

Direito de Propriedade

A propriedade, como manifestação de um direito de primeira geração, encontra-se consagrado no caput do art. 5º, incisos XXII a XXVI, ao lado de outros direitos individuais elementares, e caracteriza o Brasil como estado capitalista. **Não é, entretanto, um direito de natureza absoluta**, como podemos depreender de diversos incisos e artigos da Constituição:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à **propriedade**, nos termos seguintes:

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI - **a pequena propriedade rural**, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Note que, quanto à pequena propriedade rural, o art. 185, I, estabelece que ela não poderá ser desapropriada para fins de reforma agrária, bem como será imune ao imposto territorial rural - ITR (art. 153, §4º), **mas apenas se o proprietário não possuir outra**.

Também o **inciso II do art. 170** preconiza como princípio fundamental da ordem econômica a propriedade privada. Entretanto, diante do direito constitucional contemporâneo, não se concebe mais a propriedade como um direito absoluto, característico das organizações liberais clássicas.

O próprio art. 170, no seu inciso III, também estabelece que a **propriedade atenderá à sua função social**.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

..... III - função social da propriedade;

O art. 182, §2º, também determina que a propriedade deve cumprir sua **função social**:

Art. 182.....

..... § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Dessa forma, não pode o proprietário de terreno urbano mantê-lo não edificado ou subutilizado, sob pena de sanções administrativas sucessivas (**art. 182, § 4º**); não pode o proprietário de imóvel rural mantê-lo improdutivo (**art. 186**), sob pena de desapropriação.

O direito de propriedade pode ceder, inclusive, quando for necessária a **tutela do interesse público**, como nas hipóteses de desapropriação por necessidade ou utilidade pública (art. 5º, XXIV), de requisição administrativa (art. 5º, XXV), de requisição em estado de sítio (art. 139, VII) ou ainda, expropriação ou perda de bens (art. 5º, XLVI, “b” e art. 243).

O direito de propriedade consagra uma típica norma de **eficácia contida**, já que o constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a essa matéria, mas deixou margem à atuação restritiva do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, nos limites estabelecidos pela Constituição. Apesar de o inciso XXII afirmar peremptoriamente que “é garantido o direito de propriedade”, sem restrições do tipo “nos termos da lei” ou “na forma da lei”. Tais restrições encontram-se esparsas em outros incisos constitucionais.

Nesse sentido, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação de **imóvel urbano** (inciso XIV), por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa indenização **em dinheiro** (**não é em títulos**). Trata-se de hipótese de desapropriação ordinária.

Há ainda uma possibilidade de desapropriação de imóvel urbano que não esteja cumprindo sua função social (devidamente ocupado), denominada **desapropriação-sanção**, prevista no art. 182, §4º:

*§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano **não edificado, subutilizado ou não utilizado**, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:*

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

*III - **desapropriação com pagamento mediante títulos** da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.*

Da mesma maneira, na forma do art. 184:

*Art. 184. Compete à União **desapropriar por interesse social**, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.*

*§ 1º - As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas **em dinheiro**.*

Importante mencionar a recente aprovação da Emenda Constitucional 81, de 5/6/2014, e que trata da expropriação (não é desapropriação) de propriedades rurais e urbanas destinadas à exploração de trabalho escravo. Na verdade, a referida Emenda alterou o art. 243 da CF, que ficou com a seguinte redação;

*Art. 243 As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas **ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei** serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.*

*Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da **exploração de trabalho escravo** será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.*

A Emenda, no que toca ao trabalho escravo, para ganhar **eficácia**, depende **de regulamentação legislativa**, a qual iria ocorrer uma semana após a promulgação, porém de forma a favorecer os interesses da bancada ruralista e de alguns empresários no Congresso Nacional, afastando algumas condutas que não seriam tipificadas como condição de escravidão ou análoga à de escravo, tais como condições degradantes de trabalho e a servidão por dívida, muito comuns no interior do país e mesmo em alguns centros urbanos.

Felizmente, a referida regulamentação foi adiada, e espera-se que saia com a redação adequada a dar plena eficácia ao dispositivo constitucional.

O inciso XXV trata de uma modalidade de intervenção do Poder Público no domínio econômico privado, denominado **ocupação provisória**.

Art. 5º.....

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

Sugiro um mnemônico que me foi muito útil nos estudos de Direito Administrativo, da lavra do Professor André Luiz, atual Ministro do Tribunal de Contas da União, e que descrevo abaixo:

TLOR SeDe DIMC

Tombamento

Limitação Administrativa

Ocupação Provisória

Requisição Administrativa

Servidão Administrativa

Desapropriação

Demolição ou Destruição

Interdição e Intervenção em concessionárias ou Empresas Públicas

Multa

Confisco

Esse assunto, portanto, é estudado em profundidade na disciplina de Direito Administrativo.

Direitos do Consumidor

Estabelece o inciso XXXII do art. 5º:

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, elaborado em obediência ao art. 48 do ADCT que, ordenou a elaboração da referida lei dentro de 120 dias da promulgação da Constituição. No entanto, o referido Código (Lei 8.078/1990), só entrou em vigor em março de 1991.

Além dessa, outras leis tratam da defesa dos direitos do consumidor, sob diversos aspectos, como o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e o Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2005).

Direito de informação, de petição e de obter certidões

A Constituição garante o direito de obter informações dos órgãos públicos, nas condições do inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição:

*XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu **interesse particular**, ou de **interesse coletivo ou geral**, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, **ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**.*

Referido direito assegura ao indivíduo ainda o exercício do **controle social**, mediante a participação política e a possibilidade de fiscalização na gestão da coisa pública, configurando-se em meio para tornar efetivo o exercício da cidadania. Constitui-se em instrumento de que dispõe qualquer pessoa para levar ao **conhecimento dos poderes públicos fato ilegal ou abusivo**, contrário ao interesse público, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias.

Por exemplo, o art. 31, em seu § 3º, estabelece que “*as contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei*”. Diante da constatação de descumprimento ou violação da lei orçamentária anual, um contribuinte poderá peticionar ao poder público no sentido de ver satisfeita a correta execução orçamentária prevista na lei aprovada pela Câmara de Vereadores.

Perceba que não são somente as informações de interesse particular mas também **de interesse coletivo ou geral**.

A Constituição consagra ainda a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos e a obtenção de certidões, no art. 5º, inciso XXXIV:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Segundo o STF, a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de recurso administrativo **constitui obstáculo sério** (e intransponível, para consideráveis parcelas da população) **ao exercício do direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório** (CF, art. 5º, LV). Nesse sentido editou a seguinte Súmula Vinculante:

Súmula Vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Entretanto, de acordo com o STF, o direito de petição **não poderá** ser utilizado como sucedâneo (substituto) da ação penal, o que implicaria usurpação de atribuição institucional do Ministério Público, e nem torna apto o interessado a postular em juízo, em nome próprio.

Já o direito de obter certidões **não pode** ser invocado por quem pretenda obter cópia de documento a respeito **de terceiro**, a menos que este tenha lhe conferido mandato de representação (**procuração**). O Estado está obrigado a prestar as informações solicitadas, ressalvadas naturalmente as hipóteses sob proteção de sigilo.

A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que **não se exige** do requerente a demonstração da **finalidade específica** do pedido. Se você for a uma repartição solicitar uma certidão de nada consta, por exemplo, não preciso informar para quê vou utilizá-la, se para ingresso no serviço público por ter passado em concurso público, se para obtenção de passaporte etc.

Atenção: em respeito à **negativa da administração** para o **fornecimento de informações de interesse particular, coletivo ou geral** (inciso XXXIII, art. 5º), ou ao **direito de petição**, (inciso XXXIV, "a", art. 5º) **ou ainda ao fornecimento de certidões** (inciso XXXIV, "b", art. 5º) qual o remédio idôneo para sua repressão? Seria **o habeas data**?

Negativo. É o **mandado de segurança**. Mesmo que ainda não tenhamos estudado esses dois remédios, vale a pena já ir conferindo algumas questões sobre o assunto, mais abaixo. É porque neste caso se trata de direito líquido e certo assegurado pelo constituinte de ter acesso às informações, com as ressalvas do inciso XXXIII, do art. 5º.

*XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu **interesse particular**, ou de **interesse coletivo ou geral**, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, **ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**.*

E isso também porque o habeas data é somente para assegurar o conhecimento de informações relativas à **pessoa do impetrante**, constantes de **registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público**; ou para retificação desses dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo (art. 5º, LXXII, CF):

Art. 5º.....

LXXII - conceder-se-á habeas data:

- a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

É nesse diapasão que o STF tem entendido a via do *mandamus* como a adequada para assegurar o referido direito fundamental de obter **dos órgãos públicos informações de seu interesse pessoal, coletivo e geral**, como legítimo exercício do **direito de petição**:

“O direito de receber, dos órgãos integrantes da estrutura institucional do Estado, informações revestidas de interesse geral ou coletivo qualifica-se como prerrogativa de índole constitucional, sujeita, unicamente, às limitações fixadas no próprio texto da Carta Política (CF, art. 5º, XIV e XXXIII). (...)A ora impetrante, que é empresa jornalística, sustenta que a omissão atribuída à Mesa da Câmara dos Deputados, representada por seu ilustre Presidente, importa em grave, injusta e inegável lesividade ao seu direito de receber, desse órgão integrante da estrutura institucional do Poder Legislativo, informações, que, por se referirem ao uso de recursos públicos, revestem-se, necessariamente, de interesse coletivo e geral, o que torna plenamente justificável a asserção, **contida nesta impetração mandamental, de que o tema em causa põe em evidência a prerrogativa - que assiste aos cidadãos e aos meios de comunicação social ("mass media") - de fiscalizar e de controlar a destinação, a utilização e a prestação de contas relativas a verbas públicas**” (**MS 24.725, rel. Min. Celso de Mello, jul. em 28/11/2003**). (Grifos acrescentados)

Por fim, como todos os demais remédios constitucionais, tanto o direito de informação, como o de petição, de certidão e o mandado de segurança, **podem ser manejados por estrangeiro**, que resida ou que esteja apenas em trânsito no território nacional.

Direito de Propriedade Intelectual

Estabelecido em 3 incisos do art. 5º:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

As questões sobre este assunto envolvem basicamente a literalidade do texto constitucional. Lembre-se de que a transmissão do direito autoral dos autores aos herdeiros **dura somente o tempo que a lei fixar**.

Outra observação diz respeito ao **privilégio vitalício** do direito autoral (pois a CF não estabeleceu prazo, permitindo inclusive a transmissão desse direito aos herdeiros) e do **privilégio temporário** do direito de propriedade industrial.

Dessa forma, um escritor deterá os direitos exclusivos de suas obras até o fim da vida. Já o desenvolvedor de uma nova tecnologia (um software, um aplicativo, um material novo) deverá, mais cedo ou mais tarde, compartilhar essa descoberta, cedendo os direitos de produção e exploração.

Direito de Herança

A Constituição Federal de 1988, altamente prolixa ou analítica, trata dos mais diversos assuntos, este especificamente ligado ao direito civil das sucessões. Estabelecem os incisos XXX e XXXI do art. 5º:

XXX - é garantido o direito de herança;

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus";

E quem é esse tal de **de cujus**? É o falecido que deixou algo para os herdeiros, além de dívidas... agora, se a lei do país de origem do falecido, caso este seja estrangeiro, for mais favorável aos herdeiros, aplica-se a lei estrangeira. Caso contrário, via de regra, vale a lei brasileira, em especial o Código Civil de 2002, no capítulo do direito das sucessões.

Regra geral, a LINDB determina que a **sucessão por morte ou ausência** será **regida pela lei do país em que seja domiciliado o morto ou desaparecido**, qualquer que seja a natureza ou situação dos bens, na forma do art. 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que em seu parágrafo 1º repete o dispositivo constitucional acima:

Art. 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens.

§ 1º A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus.

§ 2º A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder.

Inafastabilidade da Jurisdição

O Princípio do Acesso ao Judiciário ou Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição o qual assegura a todos o pleno acesso ao Judiciário para defesa de direitos (art. 5º, XXXV, CF):

Art. 5º....

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Tem como corolário (decorrência), o princípio da jurisdição una, em que toda e qualquer tutela de direitos e interesse dos cidadãos pode ser levada ao Judiciário, ao contrário da França, onde impera o sistema de jurisdição dual, com um tribunal administrativo que exaure em si as causas oriundas das lides que envolvam a administração, tribunal de contas e afins.

Assim, no Brasil, mesmo a última decisão administrativa irreformável pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. A esfera administrativa, em regra é facultativa, com algumas exceções, nas quais o cidadão é obrigado a percorrer as instâncias administrativas antes de buscar a tutela do Judiciário. A chamada **jurisdição condicionada** ocorre em três hipóteses:

a) **habeas data**;

b) **Justiça Desportiva**;

c) Descumprimento de Súmula Vinculante por ato administrativo.

No descumprimento de súmula vinculante por ato administrativo (art. 7º, §1º, Lei 11.417/2006) exige-se o esgotamento das vias administrativas e no habeas data não há necessidade de esgotar a instância administrativa, apenas a negativa da Administração (art. 8º, Lei 9.507/1997):

Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.

§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.

Art. 8º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;

II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.

Quanto à Justiça Desportiva, de acordo com o art. 217, § 1º, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. Claro está que os tribunais desportivos não integram o Poder Judiciário.

A EC 45/04 conferiu força **vinculante** a algumas Súmulas aprovadas pelo STF. Trataremos desse assunto ao falar de Poder Judiciário e Controle de Constitucionalidade, mas, em resumo, isso significa que nenhum outro tribunal inferior e nenhum órgão/entidade da Administração Direta ou Indireta de todas as esferas não poderão decidir em sentido contrário a essa Súmula.

Se um juiz ou tribunal inferior descumprir uma Súmula Vinculante, qualquer brasileiro que se sinta prejudicado pelo descumprimento da mesma pode impetrar reclamação perante o STF. No entanto, se o descumprimento originar-se da Administração Pública, Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, nenhum brasileiro poderá reclamar diretamente no STF **antes de esgotar a via administrativa**.

Somente após o esgotamento das vias administrativas, é que poderá o requerente interpor **Reclamação** perante o Supremo Tribunal Federal, conforme autoriza o art. 103-A, § 3º:

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito

A Constituição estabelece, como regra, que a lei não poderá retroagir para prejudicar direitos e situações constituídas. Estabelece o inciso XXXVI do art. 5º da CF/88:

Art. 5º....

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Essa limitação visa a garantir o princípio da **segurança jurídica**, dificultando que novas leis sejam aplicadas a situações já consolidadas sob a vigência da legislação anterior.

Entretanto, isso não impede que o Estado adote leis retroativas, desde que estabeleçam situações **menos gravosas**, mais favoráveis ao indivíduo, do que as consolidadas sob as leis anteriores. Exemplo disso é o inciso XL do art. 5º, determinando que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

Direito adquirido. É aquele que a lei considera definitivamente integrado ao patrimônio do titular, ainda que não o exercite de imediato, uma vez que o exercício está protegido pelo direito. Essa proteção **não alcança** a chamada “expectativa de direito”, caracterizada quando a lei nova alcança o indivíduo que está na iminência de atender os requisitos para aquisição do direito.

É aquele direito que se aperfeiçoou a partir da **reunião de todos os elementos** exigidos pela lei para a formação do direito. Cumpridos esses requisitos, o direito se torna oponível *erga omnes*, e protegendo o titular inclusive de alterações ulteriores da norma que lhe conferiu o direito.

Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem assentado que uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência (quando o servidor público deixa de contribuir para a Previdência porque já preencheu os requisitos para aposentadoria), esse direito adquirido não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Inteligência da Súmula 359 (**ARE 825.334 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 24/5/2016**).

Súmula 359/STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Já o **ato jurídico perfeito**, entende-se aquele que se aperfeiçoou, reunindo todos os elementos necessários à sua formação, sob a vigência de determinada lei. Constitui-se em um passo além do direito adquirido, pois é o **próprio direito que se concretizou**. No exemplo acima, aquele que **exerceu o direito** ao recebimento do abono de permanência, está albergado não só pelo direito adquirido mas também pelo ato jurídico perfeito.

Coisa julgada é a decisão judicial irrecorrível, da qual não cabe mais recurso, a não ser ação rescisória, que pode ser interposta no prazo de 2 anos após o trânsito em julgado, diante de fatos ou provas novas com eficácia sobre a decisão recorrida.

Alguns entendimentos importantes do STF:

I - **Não existe** direito adquirido:

a) em face de uma nova Constituição (**texto originário**), direito esse adquirido na vigência da ordem constitucional pretérita, em face do caráter autônomo, inicial e ilimitado do poder constituinte originário; com relação às **emendas constitucionais**, há controvérsias, pois o constituinte derivado não pode desrespeitar direitos e garantias individuais, por exemplo, ao seu alvedrio.

b) em face de **mudança do padrão monetário** (alteração da moeda);

c) em razão da **criação ou aumento de tributos**;

d) em função de **mudança de regime estatutário**. Os servidores públicos não podem alegar direito adquirido ao regime jurídico anterior, sob a alegação de que faziam jus aos benefícios quando adentraram o serviço público. Nesse sentido, o Supremo entende **possível a redução ou mesmo supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias**, desde que **preservado o valor nominal da remuneração** (**ARE 770.619 MG, Min. Rosa Weber, Re-AgR 593.711, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17.4.2009**). O STF pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da **estabilidade financeira** e sobre a ausência de direito a regime adquirido. **Não há direito adquirido a regime jurídico de fixação e reajuste de vencimentos**:

"O STF pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. Nesta linha, a LC 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração". (RE 563.965, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11/2/2009, Tema 41)

O que a estabilidade financeira assegura é continuidade da **percepção da diferença** entre os vencimentos do cargo em comissão ou assemelhado, após certo tempo de exercício e os vencimentos do cargo efetivo, incorporando à sua remuneração parcela relativa à função ou cargo comissionado por ele exercido. No entanto, a jurisprudência do Supremo **desvinculou o reajuste futuro** desse benefício dos vencimentos do cargo em comissão incorporados, passando a quantia a ele correspondente a ser reajustada segundo **critérios de revisões gerais do funcionalismo** (RE n.º 226.462/SC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01).

II - O não exercício do direito **na época da lei de regência** não implica a perda do direito adquirido após a revogação/alteração da lei, mesmo que ele não seja exercitado

III - **Lei de ordem pública**: qualquer lei, seja de ordem pública, seja privada, deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

IV - O direito adquirido pode mesmo ser invocado **mesmo no âmbito de declaração de inconstitucionalidade** de uma lei. É nessa vertente a que a jurisprudência do STF tem se assentado. Exemplo é o direito a determinada retribuição declarada inconstitucional, que **não precisa ser devolvida se recebida durante o período de validade inquestionada da lei de origem, mas tampouco deverá ser paga após a declaração de inconstitucionalidade**. Trata-se de uma espécie de **modulação dos efeitos temporais da decisão**, em face do direito adquirido.

V - A União, os estados, o DF ou os municípios não podem invocar a garantia constitucional do ato jurídico perfeito ou do direito adquirido para se insurgir contra a aplicação de dispositivo de lei **do próprio ente federado** que concede vantagem retroativa, por exemplo que conceda vantagem pecuniária a servidores públicos relativa a período já trabalhado e anterior à própria edição da própria lei.

Nesse sentido, o STF possui verbete de Súmula a respeito:

Súmula 654/STF: "A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado".

Significa dizer que a União não pode editar hoje uma lei que tenha efeitos retroativos favoráveis a terceiros para depois **ela mesma arguir a inconstitucionalidade da mesma lei, pelo simples fato de ser retroativa**, em suposta ofensa ao ato jurídico perfeito e do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF). Trata-se, isso sim, de uma **garantia constitucional do particular frente ao abuso do poder estatal** e não de sua complacência ou de seus benefícios, sempre bem-vindos!

Vale registrar ementa de julgado do Supremo sobre a matéria (RE 118.074/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, julg. 25/5/2004):

"Previdência Social: aposentadoria por tempo de serviço: conversão em aposentadoria especial: aplicação da lei nova (L. 6.887/80) a situação pretérita: não invocável a garantia constitucional da irretroatividade da lei pela entidade estatal que a tenha editado (Súmula 654), não cabe ao STF, hoje limitado, no recurso extraordinário à função de "Guarda da Constituição", rever a interpretação que à lei ordinária deu o Tribunal a quo: RE não conhecido".

Atenção com este item: a garantia de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada informa **todos os ramos do direito** (não só o direito penal), e que proíbe à lei retroagir para prejudicar ou infringir um desses institutos.

Entretanto, existem exceções a essa regra, uma delas no próprio artigo 5º, inciso XL:

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu

Ou seja, a lei penal poderá **retroagir**, desde que para **beneficiar** o réu. Essa exceção vale também para outras esferas judiciais, como a **civil** e a **administrativa**.



Veja como foi cobrado!

(FGV/MPE-AL/ANALISTA/2018) A Lei estadual X34, de iniciativa do Governador do Estado, alterou a sistemática de cálculo das gratificações devidas aos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, o que afetou as projeções de ganhos futuros. Apesar disso, não houve qualquer redução de vencimentos, pois os valores pagos à época foram incorporados. À luz dos balizamentos estabelecidos pela Constituição da República, é correto afirmar que a Lei estadual X34 é.

c) constitucional, pois não há direito adquirido a regime jurídico.

Correto. É assente a jurisprudência do Supremo de que não há direito adquirido a regime jurídico, ficando entretanto, assegurada a irredutibilidade de vencimentos:

"O STF pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. Nesta linha, a LC 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração". (RE 563.965, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11/2/2009, Tema 41)

É importante também que você saiba que o STF decidiu que o princípio da irredutibilidade salarial de que trata o inciso XV do art. 37, além das limitações que o próprio inciso já prevê, é **nominal**, ou seja, não pode ser invocada para reposição da perda de poder aquisitivo em virtude de desvalorização inflacionária da remuneração ou vencimento, o que, na prática, torna a irredutibilidade sem muito efeito, pois caso o governo não dê qualquer aumento ao longo dos anos, chegará um momento em que o salário quase nada valerá.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, portanto, a mudança de regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decurso de caráter pecuniário, não viola o direito adquirido (Dentre outros, RE 227.755 CE, Rel. Min. Dias Toffoli), motivo pelo qual é constitucional a lei X34.

Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º incisos XXXVI a LXXVIII)

Princípio do juiz natural

Estabelecido nos incisos XXXVII e LIII da Constituição, este princípio preconiza que eu e você só podemos ser julgados por órgãos criados previamente pela lei para isso, não podendo haver tribunais de exceção, o que traria insegurança e caos na sociedade:

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

E o que é um juízo ou **tribunal de exceção**? É o criado posteriormente à prática de determinado delito para o julgamento dos infratores. Foi o que se observou, por exemplo, quando dos atos terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América, que culminaram na criação do tribunal de Guantánamo. É um tribunal que distingue **pessoas** e não situações.

E as justiças especializadas (trabalhista, eleitoral, militar), bem como os juizados especiais (federais e estaduais)? Não podem ser considerados justiças de exceção, pois estão devidamente constituídas e organizadas, com base na Constituição Federal e leis de organização judiciária, que estabelecem as respectivas regras de competência. O mesmo se aplica aos tribunais de ética, como o da Ordem dos Advogados do Brasil, pois se constituem em organismos disciplinares cujas decisões desafiam revisão judicial. Não são igualmente cortes de exceção os tribunais de contas, o CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica -, o Conselho de Recursos da Previdência Federal e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Já a autoridade ou juízo competente estão previstos na própria Constituição, no caso do Poder Judiciário, nas leis processuais e também nos regramentos administrativos, motivo pelo qual este princípio informa tanto a esfera judicial quanto a administrativa.

E o que é um juiz competente ou natural? É o juiz cujas regras de investidura foram estabelecidas previamente aos atos questionados ou aos crimes perpetrados.

Este princípio tem ainda como corolário (decorrência) o princípio da **inafastabilidade da jurisdição**, visto acima. Relaciona-se também, com o princípio do **devido processo legal**, constante do inciso LIV do mesmo art. 5º. Por fim, tem como desdobramento **o princípio do promotor natural**, princípio implícito que decorre da independência funcional e da inamovibilidade dos promotores, previstos no art. 127, § 1º e 128, § 5º.

Tribunal do Júri

A instituição do tribunal do júri é prevista no art. 5º, XXXVIII:

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Trata-se de um instituto de origem anglo-saxã, presente na maior parte dos Estados Democráticos, no pressuposto de que determinados crimes, pela sua gravidade e impacto social, devam ser julgados não pelo Estado-Juiz mas por pessoas comuns, cidadãos leigos, não necessariamente com formação jurídica.

A **plenitude de defesa** é assentada no princípio da ampla defesa e do contraditório destinados aos acusados em geral, e diz respeito ao réu, mormente na área penal. Além disso, os jurados são oriundos de todas as classes sociais e tipos de ocupação.

O **sigilo das votações** é imprescindível para assegurar a autonomia e a imparcialidade dos jurados. Diferentemente da praxis processual norte-americana, por exemplo, em que os jurados conversam e discutem entre si, para tentar chegar a um consenso, no Brasil, os integrantes do Conselho de Sentença não podem trocar informações, sendo nulo o veredicto que violar essa regra.

A **soberania dos veredictos** é inerente ao tribunal do júri. Significa que das decisões do tribunal do júri, e em penhor da soberania dos veredictos, **não é garantido o direito de recorrer**. Entretanto, esse princípio **não é absoluto**. Suas decisões podem ser confrontadas pelo Poder Judiciário em situações **excepcionais**, por exemplo, quando os jurados decidem de forma manifestamente contrária à prova dos autos, devendo eventual recurso ser conhecido para que o "tribunal popular" profira outra decisão (**HC 103.805, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/04/2011; HC 104.301/ES, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04/03/2011, e outros**).

Agora anote que quanto ao **princípio do contraditório e da ampla defesa**, conquanto não estejam explícitos no rol elencado no referido inciso XXXVIII, decidiu o Supremo Tribunal Federal, utilizando-se do **princípio de interpretação da concordância prática**, segundo o qual em se deparando o intérprete com situações de concorrência entre bens constitucionalmente protegidos, adote a solução que otimize a realização de todos eles, mas, ao mesmo tempo, não acarrete a negação de nenhum, **ser vedada a reformatio in pejus**, ou seja, o agravamento da situação daquele que recorreu de decisão do magistrado tomada em face do veredicto do júri, **sem que haja recurso da parte contrária, e o estabelecimento do necessário contraditório**. Nesse sentido, o juiz que venha a proferir nova decisão em sede recursal, sem o estabelecimento de novo contraditório, **está adstrito à pena máxima imposta na sentença anterior**, não podendo de modo algum piorar a situação jurídico-material do réu (**Dentre outros, HC 89.544/RN, rel. Min. Cezar Peluso, j. 14.4.2009**).

O STF decidiu também, por mais estranho que pareça, que o crime de **latrocínio** (roubo com utilização de violência e com resultado morte, art. 157, § 3º, Código Penal) **não se submete ao júri**, pois configura crime contra o patrimônio e não crime doloso contra a vida. E ainda editou Súmula a respeito:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 3º Se da violência resulta:

....

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Súmula 603/STF: A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri

No caso do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dois entendimentos importantes para a prova: matéria controvertida na doutrina é a que diz respeito à **ampliação da competência** do júri popular, estabelecida na Constituição. Parte da doutrina entende que sim, a lei pode especificar, inclusive ampliar a competência do tribunal do júri. Essa é a posição de Alexandre de Moraes, **que as bancas vêm aceitando até o momento**. A pergunta que se faz é: É possível ampliar a competência do júri popular sem restringir a competência do Poder Judiciário? Os adversários da tese dizem que não, e que isso feriria o princípio da **inafastabilidade da jurisdição**.

Nem todo aquele que pratica um crime doloso contra a vida é julgado pelo júri popular. Embora a Constituição outorgue competência ao júri popular, o STF assentou entendimento de que as autoridades que dispõem **foro especial por prerrogativa de função definido na Constituição Federal** se praticarem crime doloso contra vida, serão julgadas **de acordo com seu foro**. Por exemplo: o Prefeito será julgado pelo **Tribunal de Justiça**; Governador tem foro especial no **STJ**.

Já as **Constituições estaduais** podem dilatar o foro especial para autoridades locais, desde que não haja, a juízo do STF, incompatibilidade do exercício da função pública. Diante do caso concreto, o tribunal vai decidir se há ou não compatibilidade: por exemplo, o STF decidiu que delegados de polícia civil não têm direito a foro especial, não há razoabilidade nessa previsão da constituição estadual.

Entretanto, a competência do Foro Especial **definido exclusivamente na Constituição Estadual não prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra vida**, apenas para os demais crimes. Caso a prerrogativa esteja também prevista na Constituição Federal, prevalecerá o foro privilegiado sobre a competência do júri. Por exemplo, não há previsão, na Constituição Federal, de foro privilegiado para crimes contra a vida praticados por **secretários de estado**, não podendo a Constituição Estadual estabelecer, portanto, a competência do órgão especial do tribunal de justiça para o julgamento de tais crimes.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal editou a seguinte Súmula Vinculante:

Súmula Vinculante 45 “A competência Constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual.”

Exemplo são os **juízes estaduais e membros do Ministério Público Estadual**, que dispõem de prerrogativa de foro com relação aos crimes comuns no próprio **Tribunal de Justiça** local, por força do art. 96, III da Constituição Federal:

Art. 96. Compete privativamente:

.....

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Questão tormentosa diz respeito à competência para julgamento de **parlamentares estaduais** que cometam crimes dolosos contra a vida. Não obstante a Súmula Vinculante 45, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, entendeu que as Constituições locais, ao estabelecerem para os deputados estaduais idêntica garantia prevista para os congressistas, refletiriam a própria Constituição Federal, e não se poderia afirmar que a referida prerrogativa encontra-se prevista, exclusivamente, na Constituição estadual. Assim, deve prevalecer a teoria do **paralelismo constitucional ou simetria**, estabelecido no art. 25 da Constituição da República, dispondo que os estados organizam-se e se regem pelas constituições e leis que adotarem, observando-se, contudo, os princípios por ela adotados. Dessa forma, o Superior Tribunal assentou a competência do **Tribunal de Justiça** para julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por deputado estadual (**CC 105.227-TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgamento em 24/11/2010**).

Segundo a Relatora do feito, a Constituição Federal reserva aos deputados estaduais as **mesmas prerrogativas** previstas aos deputados federais, conforme o art. 27, § 1º:

Art. 27.....

§ 1º. Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

No art. 53, §1º, a CF prevê que os deputados federais gozam de foro por prerrogativa de função, assim como de imunidade processual temporária, já que a Casa Legislativa poderá **sustar o andamento da ação**, o que se aplica, igualmente, aos deputados estaduais, com relação à **assembleia legislativa**:

Art. 53....

§ 1º. Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.....

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

Assim, embora a súmula do STF tenha fixado entendimento de que a competência do Tribunal do Júri deve prevalecer, nos casos em que a prerrogativa de função seja estabelecida exclusivamente na Constituição estadual, a Ministra do STJ entende que pelo princípio da simetria, o foro por prerrogativa de função para os parlamentares estaduais decorre da própria Lei Maior.

Poder-se-ia questionar o posicionamento da 3ª Turma do STJ, ao abrigo de que a própria Constituição outorgou expressamente o foro por prerrogativa de função aos **Chefes do Executivo Municipal (art. 29, X) e Estadual (art. 105, I, "a")**, não obstante o Chefe do Poder Executivo Federal (**Presidente da República**), já disponha de foro privilegiado (art. 102, I, "a", CF), não tendo feito o mesmo com relação aos parlamentares estaduais:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

....

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal....

Entretanto, enquanto não houver novo pronunciamento definitivo do STF ou do próprio STJ sobre o tema, guarde esse posicionamento do Superior Tribunal.

Bem, nas hipóteses de conexão ou continência entre mais de uma infração penal, por exemplo, um crime doloso contra a vida e outro com foro por prerrogativa de função, o Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de atração, prevalecendo a regra do juiz natural. Desse modo, havendo corréus, **o processo será desmembrado**, para processamento e julgamento por órgãos judiciais distintos, inclusive o tribunal do júri, ressalvadas as situações em que a cisão implique prejuízo ao esclarecimento dos fatos:

“1. Cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014), ressalvadas as situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), o que não ocorre no caso. Deferimento do desmembramento do processo quanto aos não detentores de foro por prerrogativa de função”. (**Inq 4.104, rel. min. Teori Zavascki, 2ª T, j. 22-11-2016**)

Não obstante, permanece válida a Súmula 704 da Suprema Corte:

Súmula 704/STF: Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados

Por fim, guarde que o STF assentou que **não viola o princípio da soberania do veredicto** do júri decisão judicial proferida em *habeas corpus* que ordene a extinção de processo penal instaurado por crime contra a vida. Segundo o STF o Tribunal de segunda instância,

"ao julgar a ação de revisão criminal, dispõe de competência plena para formular tanto o juízo rescindente (*judicium rescindens*), que viabiliza a **desconstituição da autoridade da coisa julgada penal** mediante invalidação da condenação criminal, quanto o juízo rescisório (*judicium rescissorium*), que legitima o reexame do mérito da causa e autoriza, até mesmo, quando for o caso, a prolação de **provimento absolutório, ainda que se trate de decisão emanada do júri**, pois a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, que representa garantia fundamental do acusado, não pode, ela própria, constituir paradoxal obstáculo à restauração da liberdade jurídica do condenado" (**ARE 674.151, rel. min. Celso de Mello, j. 15/10/2013**).

Quanto à prisão de réu condenado por decisão soberana do júri, o STF firmou a tese de que "*a prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade*" (**HC 118.770/SP, DJe 24/4/2017**).

Nesse sentido, o Supremo reiterou o teor da Súmula 691/STF, e **não admitiu habeas corpus impetrado contra liminar em HC indeferida no Superior Tribunal de Justiça**, em decisão monocrática do Relator. Vencido o Ministro Marco Aurélio, pra variar, que concedia a ordem para soltar assassino condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado, por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver, por entender não aplicável à espécie a Súmula 691/STF (**HC 139.612/MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, julg. 25/4/2017**):

Súmula 691/STF: "**a prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade**".

Princípio da legalidade e da irretroatividade da lei penal

Previstos nos incisos XXXIX e XL da Constituição:

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Dessa forma, com a interpretação do dispositivo do inciso XL, é possível afirmar que a CF/88 incorporou a **irretroatividade da lei penal mais prejudicial**, e, por outro lado, a **retroatividade da lei penal mais benéfica**.

Quanto a estes pressupostos, é importante que você conheça uma exceção contida no **Enunciado de Súmula 711 do STF**, que adora aparecer em prova:

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência

Crime continuado é aquele que se perpetua no tempo e não se exaure imediatamente. Exemplos são o tráfico de drogas e o sequestro com cárcere privado.

Da proteção dos direitos e liberdades fundamentais

O Inciso XLI ordena ao legislador ordinário que estabeleça punições a quaisquer discriminações que atentem contra os direitos e liberdades fundamentais. Trata-se de dispositivo de conteúdo difuso, determinando medidas coercitivas a atos que atentem contra os direitos e liberdades. Contudo, como esses direitos não possuem caráter absoluto, **poderão ser limitados** em determinadas situações.

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

Crimes Constitucionalizados

De redação muito ruim, e com **grande presença nas provas** de direito constitucional, os incisos abaixo do art. 5º versam sobre os chamados **crimes constitucionalizados**, que mereceram especial preocupação de nosso constituinte originário.

Art. 5º.....

....

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Perceba que **todos** os crimes mencionados nos incisos acima são **inafiançáveis**.

Agora guarde o esquema a seguir:

RAÇÃO (Racismo e ação de grupos armados)	Inafiançáveis	Imprescritíveis
3T1H (Terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes, tortura e hediondos)	Inafiançáveis	Insuscetíveis de graça ou anistia

Guarde ainda estes conceitos:

Indulto: causa extintiva de punibilidade (art. 107, II, do Código Penal) e consiste em ato de clemência do Poder Público, concedido privativamente pelo Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, em **caráter geral ou coletivo**. Pode ser delegado aos Ministros de Estado, nos termos do § único do art. 84.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

*XII - **conceder indulto e comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;*

Em relação ao indulto, o STF decidiu que o indulto da pena privativa de liberdade **não alcança a pena de multa que tenha sido objeto de parcelamento espontaneamente** assumido pelo sentenciado (**EP 11 IndCom-Agr/DF, rel. Min. Roberto Barroso, julg. em 8/11/2017**).

Graça: causa extintiva de punibilidade, de caráter **pessoal**, concedido privativamente pelo Presidente da República, da mesma forma que o indulto, que é de caráter coletivo.

Anistia: é a renúncia do Estado do seu direito de punir determinados fatos. É direcionada **a fatos** e não a pessoas.

Reclusão e detenção: a distinção ocorre basicamente por conta de que a pena de **detenção não admite o regime inicial fechado** para execução da pena, apenas o semi-aberto cumprido em estabelecimentos menos rigorosos tais como colônias agrícolas ou similares, ou no regime aberto, em casas de albergue ou estabelecimentos similares. A pena de **reclusão admite o regime inicial fechado**, em estabelecimentos prisionais de segurança máxima ou média.

Importante anotar que o STF (**dentre outros, o HC 81.565**) assentou que a **graça individual** e o **indulto coletivo** são **modalidades do poder geral de graça** do Presidente da República, os quais sofrem igualmente as restrições previstas no art. 5º, XLIII, da CF.

Salientou ainda o STF que a **comutação de penas é espécie de indulto**. Desse modo, o indulto e a comutação de penas amoldam-se à proibição do inciso XLIII da CF/88, que a veda a concessão de graça e anistia aos crimes hediondos e de tortura, tráfico e terrorismo.



Veja como foi cobrado!

(CESPE/AGENTE ADM/POLÍCIA FEDERAL/2014) O terrorismo, o racismo, a tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes são crimes hediondos, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia.

ERRADO. O crime de racismo não foi atingido pela restrição de concessão de graça ou anistia, não obstante seja inafiançável, como os demais. Lembre-se, **RAÇÃO** -> são inafiançáveis e imprescritíveis.

(CESPE/INVESTIGADOR/POLÍCIA CIVIL/BA/2013) A previsão constitucional da prática de tortura como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia expressa um dever de proteção identificado pelo constituinte e traduz-se em mandado de criminalização dirigido ao legislador.

CERTO. os mandados de criminalização estabelecem matérias sobre as quais o legislador ordinário não tem outra opção senão legislar na forma prescrita pela Constituição, protegendo determinados bens ou interesses de forma adequada. É um verdadeiro mandamento constitucional, como o caso da questão. Não pode o legislador editar norma em sentido diverso daquela prescrito pelo constituinte.

Princípios da Sucessão e Individualização da pena

Previstos nos incisos XLV e XLVI da Constituição:

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

- a) privação ou restrição da liberdade;*
- b) perda de bens;*
- c) multa;*
- d) prestação social alternativa;*
- e) suspensão ou interdição de direitos;*

Os incisos XLV e XLVI tratam do princípio da **intranscendência subjetiva** das sanções. Esse princípio veda a que sanções pessoais alcancem aqueles que não tiveram participação na execução do ato ilegítimo ou irregular ou não tiveram como impedi-lo. Esse princípio está consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também em relação à **Administração Pública**, em três vertentes distintas (**RE 813.216, Rel. Min. Celso de Mello, julg. em 28/05/2014 e AC 2.614/PE, rel. Min. Luiz Fux, julg. em 23/6/2015**):

I - descumprimento de obrigação por entidade da administração indireta não pode ser atribuídas ao ente federal da qual participam;

II - quando o desrespeito for ocasionado pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, as consequências não podem alcançar o Poder Executivo;

III - Não serão impostas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Ou seja, havendo atos irregulares oriundos de administrações anteriores e os novos gestores tomarem providências para sanar as irregularidades verificadas, aplica-se o princípio da intranscendência subjetiva.

Ainda quanto ao esse princípio, o STF assentou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (**Lei de Crimes Hediondos**), por entender que a imposição de cumprimento da pena em regime integralmente fechado feria o **princípio da individualização da pena** ao impedir a **progressão no regime**, nas espécies fechado, semiaberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso.

Direitos constitucionais do preso

Consignados nos incisos XLVII a XLIX da CF/88:

Art. 5º....

XLVII - não haverá penas:

*a) de morte, **salvo em caso de guerra declarada**, nos termos do art. 84, XIX;*

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

Apesar de a Constituição vedar o trabalho forçado, a Lei de Execuções Penais (Lei 7.810/1984), recepcionada pela CF/1988 prevê a **obrigatoriedade** do trabalho do recluso (art. 39, V), ficando aquele que se recusar sujeito a sanções por **falta grave**:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

.....

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

.....

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

O trabalho do preso tem direito ao benefício da remição de pena na proporção de 3 dias trabalhados por 1 dia de pena, conforme o art. 126, §1º da LEP.

Guarde ainda que o **Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1969**, do qual o Brasil é subscritor, não considera como "trabalhos forçados ou obrigatórios" aqueles impostos por um tribunal competente para cumprimento de sentença judicial (art. 8º, "a" e "c", "i"):

Art. 8º. Ninguém será mantido à escravidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos sob todas as formas.

Ninguém pode ser submetido a servidão.

a) Ninguém será constrangido a executar trabalho forçados ou obrigatórios;

b) A alínea anterior **não poderá ser interpretada no sentido de proibir**, em países em que certos crimes podem ser punidos com pena de prisão acompanhada de trabalhos forçados, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados imposta por um tribunal competente;

c) Para os efeitos do presente parágrafo, **não serão considerados** "trabalhos forçados ou obrigatórios":

i) qualquer trabalho ou serviço, não previsto na alínea b) normalmente exigido de um indivíduo que tenha sido encarcerado em cumprimento de decisão judicial ou que, tendo sido objeto de tal decisão, ache-se em liberdade condicional;

A pena de **banimento** é aquela em que um cidadão perde direito à sua nacionalidade, passando a ser apátrida, a não ser que já detenha nacionalidade de outro país. Essa pena, utilizada como instrumento de repressão política, é vedada de modo absoluto pela nossa Constituição.

O direito à vida, como todos direitos fundamentais caracterizados na Constituição, não se reveste de caráter absoluto. Dentre outros, está a possibilidade **de pena de morte**. Em 1989, foi aprovado um Protocolo Facultativo ao **Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos**, que prevê a abolição da pena de morte. Esse Protocolo entrou em vigor em 1991, e o Brasil, aderiu ao Protocolo por meio do Decreto Legislativo 311/2009, com reserva expressa no artigo 2º do Tratado, pois apesar de a Constituição proibir a execução da pena capital, permite a sua execução no caso de guerra declarada (CF, art. 5º, XLVII, "a"). Assim, o referido tratado possui status **supralegal**, isto é, derroga disposições legais eventualmente com ele conflitantes, mas submete-se à autoridade da Constituição Federal.

Quanto à extradição de estrangeiro, duas interessantes posições do STF: a primeira, condiciona a extradição de preso estrangeiro ao Estado de origem, que deverá assumir compromisso formal de comutar a **pena de morte** em pena privativa de liberdade, ressalvado o caso de guerra, por simetria com a nossa Constituição:

"O ordenamento positivo brasileiro, nas hipóteses em que se delineia a possibilidade de imposição do supplicium extremum, impede a entrega do extraditando ao Estado requerente, a menos que este, previamente, assumo o compromisso formal de comutar, em pena privativa de liberdade, a pena de morte, ressalvadas, quanto a esta, as situações em que a lei brasileira – fundada na CF (art. 5º, XLVII, a) – permitir a sua aplicação, caso em que se tornará dispensável a exigência de comutação" (**Ext 855, rel. min. Celso de Mello, julg. 26/8/2004**)

A segunda, diz respeito à pena de **caráter perpétuo**, em que o Supremo oscilou entre uma e outra posição, quanto à obrigatoriedade de o Estado requerente da extradição assumir compromisso de comutar a **pena para o máximo de 40 anos (lei penal brasileira atualizada pela Lei 13.964/2019)**. Inicialmente, o STF reputava necessário o compromisso, depois voltou atrás, e agora, a partir do julgamento da Ext. 885, confirmada pela Ext. 1.221, exigiu novamente a assunção do compromisso pelo Estado estrangeiro. Trata-se de verdadeira ingerência no sistema penal alienígena para condicionar a extradição de criminosos:

"A extradição somente será deferida pelo STF, tratando-se de fatos delituosos puníveis com prisão perpétua, se o Estado requerente assumir, formalmente, quanto a ela, perante o Governo brasileiro, o compromisso de comutá-la em pena não superior à duração máxima admitida na lei penal do Brasil (CP, art. 75), eis que os pedidos extradicionais – considerado o que dispõe o art. 5º, XLVII, b, da CF, que veda as sanções penais de caráter perpétuo – estão necessariamente sujeitos à autoridade hierárquico-normativa da Lei Fundamental brasileira. Doutrina. Novo entendimento derivado da revisão, pelo STF, de sua jurisprudência em tema de extradição passiva". (**Ext 855, rel. min. Celso de Mello, julg. 26/8/2004. No mesmo sentido, Ext 1.201, rel. min. Celso de Mello, julg. 17/2/2011**)

Quanto ao respeito à integridade física e moral dos presos, o Brasil tem sido denunciado de forma recorrente em organismos internacionais de proteção dos direitos humanos, pelo total desrespeito a esse postulado, em virtude das condições precárias de diversos institutos prisionais, com episódios de selvageria e morte de repercussão mundial (Vide presídios Urso Branco em Rondônia, Carandiru em São Paulo, Pedrinhas no Maranhão).

Quanto ao uso de **algemas**, o STF editou a **Súmula Vinculante 11**:

Súmula Vinculante 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo das responsabilidades civil do Estado.

Além da Súmula, é bom dar uma olhada nos pronunciamentos do STF sobre o tema, que têm aparecido em prova. Uma dessas "pérolas" é do Ministro Marco Aurélio, que não admitiu o uso de algemas pelo réu durante o julgamento do júri, pois tal fato poderia "sugestionar" os jurados, independentemente da periculosidade do sujeito:

"O julgamento do Júri é procedido por pessoas leigas, que tiram as mais variadas ilações do quadro verificado. A permanência do réu algemado, indica, à primeira vista, cuidar-se de criminoso da mais alta periculosidade, desequilibrando o julgamento a ocorrer, ficando os jurados sugestionados". (**HC 91.952, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, julgamento em 7/8/2008**).

Mas é admitido o uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento:

"O uso de algemas durante **audiência de instrução e julgamento** pode ser determinado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos à segurança do acusado ou das pessoas ao ato presentes" (**Rcl. 9.468 Agr, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, julg. em 24/3/2011**).

"O uso **injustificado** de algemas em audiência, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa - o que não se evidenciou no caso -, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção (...). A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio de que "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563). Esse postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo" (**Rcl. 16.292 Agr, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 15/3/2016**).

Limites à extradição

A extradição é uma solicitação de um Estado estrangeiro para que condenado ou processado no país de origem seja extraditado para que cumpra a pena em seu território. instituto que obedece a tratados internacionais de extradição, à Constituição Federal brasileira e ao Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980).

A extradição classifica-se em **ativa** (quando solicitada pelo Brasil a outro Estado - *exemplo de ex-diretor do Banco do Brasil condenado na Ação Penal 470 - Mensalão -, cuja extradição foi requerida pelo Brasil à Itália*) ou **passiva** (quando requerida por outro país ao Brasil - *exemplo da Itália, que requereu a extradição do ativista e guerrilheiro Cesare Battisti*).

Nesse sentido, a CF/88 estabeleceu alguns limites à extradição, nos incisos LI e LII do art. 5º:

*LI - nenhum brasileiro será extraditado, **salvo o naturalizado**, em caso de **crime comum**, praticado **antes da naturalização**, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;*

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

A extradição está condicionada à observância de **4 pressupostos**:

I - O crime **não pode ser político ou de opinião**;

II - o crime deve ter **tipificação tanto no país de origem quanto no Brasil**;

III - A pena de restrição de liberdade imposta ao extraditando **não pode ultrapassar 30 anos** (vide posições oscilantes do STF);

IV - o **brasileiro nato** não será extraditado. Entretanto, **poderá perder a condição de brasileiro**, ao adquirir outra nacionalidade, por exemplo, sem reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, nos termos do art. 12, § 4º, II, da CF. Nessa condição, poderá ser extraditado. A perda da nacionalidade de brasileiro nato é declarada por meio de **Portaria do Ministério da Justiça**.

Exemplo da espécie foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do **MS 33.864, rel. Min. Roberto Barroso, julg. 19/4/2016**, no qual brasileira adquiriu voluntariamente a nacionalidade americana em setembro de 1999, mesmo já sendo portadora de um "green card"; jurou fidelidade e lealdade aos Estados Unidos da América, renunciando à cidadania brasileira, casando-se posteriormente com o cidadão americano Karl Hoerig, que foi assassinado, em 12/3/2007, mesma data em que Claudia Sobral – principal suspeita do crime – retornou ao Brasil.

Considerada foragida pela Justiça dos Estados Unidos e com processo de extradição em curso, a defesa de Claudia ajuizou o MS contra a portaria do Ministério da Justiça, de julho de 2013, que declarou a "perda da nacionalidade brasileira" da autora, carioca de 51 anos, alegando violação ao inciso LI do artigo 5º da Constituição:

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

A maioria dos cinco ministros da Primeira Turma do STF considerou válida a portaria do Ministério da Justiça, e cassou liminar do Superior Tribunal de Justiça favorável à autora, considerando **legítima a decretação da perda da nacionalidade**, com fundamento em outro dispositivo constitucional (parágrafo 4º do artigo 12, da CF):

Art. 12

[...]

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)**

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)**

O art. 102, I, g, da Constituição, estabelece ainda a **competência do STF** para julgamento de extradição solicitada por Estado estrangeiro:

Portanto, o **brasileiro naturalizado** poderá ser extraditado, se cometer **crime comum, antes da naturalização, ou tráfico ilícito de entorpecentes, a qualquer tempo**, na forma da lei.

Princípio do Devido Processo Legal

Esse princípio importantíssimo, estabelecido no inciso LIV do art. 5º, juntamente com seus consectários, o princípio da ampla defesa e do contraditório (inciso LV), preconiza que todo cidadão tem direito a um processo justo, no âmbito do Judiciário ou da Administração, direito à citação e conhecimento prévio do teor das acusações, a um julgamento público e célere e direito à defesa, inclusive técnica (de advogado).

Art. 5º.....

.....

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

Como decorrência desses princípios, e com fundamento em diversas assentadas do STF, importantes para sua prova, tem-se ainda que são decorrências do princípio do devido processo legal (ou *due process of law*):

I - igualdade entre as partes;

II - direito ao benefício da gratuidade, quando necessário;

III - direito a um juiz natural;

IV - direito ao silêncio, garantia contra a autoincriminação. Curioso anotar que no interrogatório policial, o acusado não poderá furtar-se a fornecer informações pessoais - nome, endereço, estado civil, se já cumpriu pena etc, podendo apenas omitir-se **quanto aos fatos que lhe são imputados**.

V- direito de produzir provas em sua defesa e de verificar as provas de acusação;

VI - direito de presenciar os atos de interrogatório dos demais litisconsortes penais;

Importante ainda destacar o princípio constitucional implícito da razoabilidade e proporcionalidade, manifestação do princípio do devido processo legal em seu **sentido material ou substantivo**. Preconiza que além de um processo justo e dos instrumentos a ele inerentes, não se poderá chegar a uma conclusão desarrazoada ou desproporcional, motivo pelo qual este princípio é também chamado de **vedação do excesso**.

Não confunda esse princípio com o inciso LXXVIII do art. 5º, que traz a palavra “razoável”, mas não no sentido de razoabilidade e sim no de **celeridade processual**, relativa à razoável duração do processo, seja judicial, seja administrativo.

Estudamos em capítulo próprio a respeito da teoria dos **limites dos limites**, a qual preconiza que leis restritivas de direitos constitucionais enfrentam uma barreira, que é justamente o princípio da razoabilidade. Assim, não basta a observância aos procedimentos estabelecidos na Constituição e nas leis processuais respectivas, as limitações impostas aos direitos fundamentais devem ser **razoáveis** e **não podem ferir o núcleo essencial** do direito em foco.

Os princípios da proporcionalidade e o da razoabilidade são decorrência implícita do princípio do devido processo legal, estabelecido no art. 5º LIV, da Constituição, no seu sentido material ou substantivo. O princípio da proporcionalidade é também chamado de princípio da vedação do excesso.

Na proporcionalidade, além de obedecer aos requisitos legais e constitucionais do devido processo, seja na função de intérprete, seja na de julgador, o resultado deverá ser adequado, necessário e proporcional, dentro dos seguintes conceitos:

I - **Adequação**: a medida alcançada deve ser adequada para a busca dos fins almejados;

II - **Necessidade**: verifica-se se não há outra medida menos gravosa para o alcance da finalidade buscada;

III - **Proporcionalidade em sentido estrito**: efetiva ponderação, em sentido estrito, entre os benefícios e prejuízos advindos da decisão escolhida.

Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório

Está explícito no inciso LV do art. 5º:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Os princípios do contraditório e da ampla defesa são **garantias**, indissociáveis, caminhando juntas no processo judicial e também no administrativo. Constituem-se em corolário do **devido processo legal**, pois não como falar em devido processo legal sem a outorga da plenitude de defesa, que inclui o direito à defesa técnica, publicidade dos atos processuais, à citação, à produção de provas, de recurso, de contestação, de intervenção no processo, de acesso aos elementos de prova constituídos em procedimento inquisitório.

Nesta quadra, vale a pena falarmos um pouco do **inquérito policial**. O inquérito é um **procedimento administrativo**, um conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária (civil ou federal) com o intuito de arremeter provas de determinada infração penal. Por ser um procedimento **sigiloso** não **exige o contraditório e a ampla defesa**. Contudo, o sigilo **não abrange** o promotor, o juiz da causa e o advogado do investigado, nos termos do Enunciado de Súmula Vinculante nº 14, editado pelo STF:

Súmula Vinculante 14/STF: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, **já documentados em procedimento investigatório** realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”

Por **ampla defesa** entende-se o direito dado aos litigantes de trazer ao processo, administrativo ou judicial, todos os elementos de prova lícitamente obtidos para provar os fatos que alega, ou até mesmo o direito de se omitir ou permanecer calado, a fim de evitar sua auto-incriminação.

Por **contraditório**, entende-se o direito do indivíduo de tomar conhecimento do que é alegado contra ele e contraditar a parte adversa na lide. O contraditório instaura-se a partir da **citação válida do réu**, no processo judicial ou da comunicação de **audiência ou citação**, o processo administrativo. Para que esteja caracterizada a oportunidade do contraditório, **não há necessidade da realização efetiva** do mesmo, basta **conferir a oportunidade** ao interessado para fazê-lo. Se não o fizer, arcará com os ônus processuais de sua desídia.

Também não é obrigatório em algumas fases do processo administrativo, por exemplo, na **sindicância prévia** para abertura do PAD – Processo Administrativo Disciplinar. Concluindo a sindicância pela abertura do PAD, este sim deverá oportunizar a defesa do indiciado.

Por força da jurisprudência do Supremo, consolidada na Súmula Vinculante nº 5, a falta de defesa técnica por advogado no PAD **não viola o direito à ampla defesa e ao contraditório**, consectários do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição:

Súmula Vinculante 5/STF. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Entretanto, **é nula** a punição disciplinar de servidores, ainda que mera advertência, não precedida de sindicância ou processo administrativo no qual seja oferecido o exercício da ampla defesa.

Ainda quanto à ampla defesa, o STF firmou orientação no sentido de que o princípio do **duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional absoluta**. Duplo grau de jurisdição é a possibilidade de revisão das decisões judiciais por instância ou juiz diverso daquele que decidiu originalmente.

O Pacto de São José da Costa Rica (ou Convenção Americana de Direitos Humanos), internalizado por nossa ordem jurídica por meio do Decreto 678/92, estabelece que o acusado tem o direito de revisão das decisões que lhe sejam desfavoráveis, o que daria a entender que o duplo grau seria obrigatório.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o Duplo Grau de Jurisdição, no Brasil, **não é garantia obrigatória**. Ele existiria somente nos casos em que a lei o estabelecer, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição. Assim, no Brasil, o duplo grau não é de ordem constitucional, mas sim **de ordem legal** (uma vez que só será exigível nos casos em que a lei prever). Ex: os senadores, nos crimes comuns, são julgados e processados perante o STF. Nesse caso, sendo a decisão desfavorável, não haverá outro grau recursal. Consequentemente, não há que se falar em duplo grau jurisdicional nessa hipótese.

Este foi o posicionamento adotado STF no julgamento da **Ação Penal nº 470**, em julgamento no dia 2/8/2012, no qual se decidiu que o Pacto de São José da Costa Rica não se sobrepõe à Constituição, confirmando-se a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar os casos em que haja prerrogativa de foro e os crimes conexos, **sem possibilidade de recurso à instância superior**. Na ocasião, foi mencionada a **Súmula 704/STF**:

Súmula 704/STF: "Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados".

Por fim, com relação ao princípio do contraditório, vale uma análise da **Súmula Vinculante 3** do STF, que preceitua:

Súmula Vinculante 3/STF: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Aparentemente, a Súmula suscita a supressão do contraditório nos processos de registro de aposentadoria. Entretanto, o STF entendeu que no caso não há litígio, pois, no registro inicial das aposentadorias, trata-se apenas do aperfeiçoamento de um **ato complexo** – ato que depende da manifestação independente de mais de um órgão para que tenha eficácia.

Entretanto, **cuidado**, pois essa Súmula também já tem **exceção**! Entendimento mais recente do STF inclinou-se no sentido de que se o TCU demorar **mais do que cinco anos** para efetuar o registro inicial da aposentadoria, ele é obrigado a chamar o beneficiado para apresentar sua defesa, ou seja, para **exercer o contraditório**. Isso em penhor do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica, pois entende o STF que **cinco anos** é um prazo já consagrado em outros diplomas (Lei do Processo administrativo, lei da ação civil pública), constituindo-se em um interregno razoável para que o TCU efetue o registro.

O Supremo Tribunal Federal já assentou, em mais de uma oportunidade, as violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado (**relações verticais**), mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado (**relações horizontais**), aplicando-se, pois, os consectários do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório às relações entre particulares:

"Sociedade civil sem fins lucrativos. Entidade que integra espaço público, ainda que não-estatal. Exclusão de sócio sem garantia do devido processo legal. Aplicação direta dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório. (...) A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. (...)" (**RE 201.819/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, julg. em 11/10/2005**).

Provas ilícitas

O inciso LVI do art. 5º estabelece:

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Também o Código de Processo Penal, em seu art. 157, estabelece:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.

Pois bem, é importante que você saiba que a exclusão da **prova originariamente ilícita** – ou daquela afetada pelo **vício da ilicitude por derivação** – representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do *due process of law* (**devido processo legal**) e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal.

A chamada doutrina dos **frutos da árvore envenenada** (*fruits of the poisonous tree*) estabelece que ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude **originária**, quer se cuide de ilicitude por **derivação**. É essa a vertente adotada pelo STF:

"Irrecusável, por isso mesmo, o fato de que a ineficácia probatória dos elementos de convicção — cuja apuração tenha decorrido, em sua própria origem, de comportamento ilícito dos agentes estatais — torna imprestável, por derivação, a prova penal, inibindo-lhe, assim, a possibilidade de atuar como suporte legitimador de qualquer decisão judicial, mesmo aquela que recebe a denúncia. Esse entendimento, Senhores Ministros, que constitui a expressão mesma da teoria dos “frutos da árvore envenenada” (“fruits of the poisonous tree”) – firmada e desenvolvida na prática jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados Unidos da América" (**Inq 2.424/RJ, rel. min. Cezar Peluso, julg. 26/11/2008**).

Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma **fonte autônoma de prova** (Código de Processo Penal, art. 157, §§ 1º e 2º) – que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal –, **essa prova é admissível**, porque não contaminada pela mácula da ilicitude originária. Trata-se da **fonte autônoma de prova** (*an independent source*) e a sua desvinculação causal da prova ilicitamente obtida. Para o Supremo,

"É certo, ademais, como adverte o Ministro Celso de Mello, que, “se (...) o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com es[s]a não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária. (**RHC 142.902, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 28/6/2018; no mesmo sentido, Rcl. 12.484/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 29/4/2014**)

Por fim, guarde que a doutrina moderna e a legislação processual penal tem distinguido as **provas ilícitas** das **provas ilegítimas**, espécies do **gênero prova ilegal**. As provas **ilícitas** são as que violam diretamente ou indiretamente a Constituição Federal (ferem normas constitucionais ou legais, **de direito material**). **Ilegítimas** são as provas que violam **normas processuais** (por exemplo, reconhecimento do acusado sem observância das formalidades previstas no Código de Processo Penal). Mas há alguma relevância nessa distinção?

Sim! É que a **prova ilícita** é **inadmissível no processo** e não pode ser acostada aos autos; se o for deve ser **imediatamente desentranhada** e não pode ser refeita ou renovada, **ainda que utilizada para beneficiar o réu; já a prova ilegítima é nula**, assim declarada pelo juiz e **pode ser refeita ou renovada**, com observância agora dos requisitos processuais, nas hipóteses do art. 573 Código de Processo Penal, que você não precisa conhecer, para esta disciplina de Direito Constitucional. Basta que você saiba a distinção entre uma e outra, ok?

O Supremo decidiu ainda que a prova obtida por interceptação telefônica decretada por **juízo incompetente** é ilícita, ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal:

"Nulidade da interceptação telefônica determinada por autoridade judicial incompetente, nos termos do art. 102, inc. I, al. b, da Constituição da República e do art. 1.º da Lei n. 9.296/1996. 4. Ausência de remessa dos autos da investigação para o Supremo Tribunal Federal, depois de apresentados elementos mínimos caracterizadores da participação, em tese, de Ministro do Tribunal de Contas da União e de membro do Congresso Nacional na prática de ilícito objeto de investigação. 5. Contaminação das provas produzidas, por derivação, por não configuradas as exceções previstas no § 1º e no § 2º do art. 157 do Código de Processo Penal. " (**Inq 3.732, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/03/2016**)

Entretanto, em outra assentada, o Supremo decidiu:

"A nulidade do processo criminal por incompetência do juízo processante não torna ilícitas as provas colhidas em interceptação telefônica que fora deferida por juiz que, à época da decisão, era competente" (**HC 81.260-ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julg. em 14/11/2001**)

Presunção de inocência e identificação criminal

Previstos nos incisos LVII e LVIII do art. 5º:

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

Esse princípio tem sido conhecido como da **presunção da inocência**. Agora veja como o STF oscilou na interpretação desse dispositivo. No julgamento do HC 68.726, rel. Min. Néri da Silveira, em 28/6/1991, a Corte assentou que a presunção de inocência não impedia a prisão decorrente de acórdão recorrível, e que a ordem de prisão decorrente de órgão julgador de segundo grau, ainda que pendente julgamento de recurso especial ou extraordinário era concernente aos interesses de garantia da aplicação da lei penal e sua execução, não conflitando com o art. 5º, LVII, da Constituição. Tal orientação foi reiterada em diversas oportunidades, no HC 72.366/SP, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 26/4/1/1999, HC 79.814, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13/10/2000, HC 80.174, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 12/4/2002, RHC 85.024, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 10/12/2004; HC 91.675, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7/12/2007.

No julgamento do HC 84.078/MG, relator o Min. Eros Grau, realizado em 5/2/2009, por sete votos a quatro o STF assentou que o princípio da presunção de inocência se mostrava incompatível com a execução provisória da sentença antes do trânsito em julgado da condenação.

Em 17/2/2016, no julgamento do HC 126.292/SP, rel. Min. Teori Zavascki, a Corte, por sete votos a quatro, tornou à orientação original, da possibilidade de execução da pena de prisão após a condenação por órgão colegiado, visto que, dentre outros fundamentos, nesta fase já houve demonstração de materialidade e autoria.

No julgamento das ações de controle abstrato ADC 's 43, 44 e 54, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 7/11/2019, o Supremo promoveu a **terceira alteração jurisprudencial** no tema em dez anos, retornando à posição adotada em 2009, pela impossibilidade da execução da pena após condenação em 2ª instância, ao assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.

Ainda com relação a esse princípio, decidiu o STF que "a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado **não podem ser considerados como maus antecedentes** para fins de dosimetria da pena" (**RE 591.054, rel. Min. Marco Aurélio, julg. em 17/12/2014, com repercussão geral reconhecida**).

Bem, o princípio da **presunção de inocência** implica também na não produção de provas contra si mesmo, que justifica o **direito ao silêncio**. O ônus da prova do delito é da acusação, motivo pelo qual o réu também não pode ser obrigado a provar que não praticou tal ou qual ato.

"O privilégio contra a auto-incriminação - *nemo tenetur se detegere* -, erigido em garantia fundamental pela Constituição - além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 C.Pr.Pen. - importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio" (**HC 80.949/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1.ª Turma, DJ de 14/12/2001**).

Segundo o STF, a falta da advertência do direito ao silêncio implica em **nulidade** da audiência ou das provas eventualmente colimadas:

"Juizados especiais criminais. (...) Não tendo sido o acusado informado do seu direito ao silêncio pelo juízo (art. 5º, LXIII), a audiência realizada, que se restringiu à sua oitiva, é nula" (**HC 82.463, rel. min. Ellen Gracie, julg. 5/11/2002**). "O privilégio contra a autoincriminação - *nemo tenetur se detegere* -, erigido em garantia fundamental pela Constituição (...) importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência - e da sua documentação formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em "conversa informal" gravada, clandestinamente ou não" (**HC 80.949, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 30/10/2001**).

Por este princípio, o Estado tem a obrigação de **comprovar a culpabilidade** do infrator. O acusado não poderá levantar provas contra si mesmo. É oponível, entretanto, nos processos no âmbito das **Comissões Parlamentares de Inquérito**:

"O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as CPIs - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário" (**HC 79.812, rel. min. Celso de Mello, Julg. 8/11/2000, Pleno**).

O direito ao silêncio, portanto, **não está restrito ao preso**, e pode ser invocado por pessoas em **qualquer instância**, tais como: administrativa, judicial, de CPI, em processo administrativo disciplinar, ou seja, em qualquer processo administrativo ou judicial, sempre que forem feitos questionamentos que possam levar à incriminação do investigado. **Não poderá ficar calado**, entretanto, em interrogatório perante autoridade policial para **coleta de informações e dados pessoais**.

A jurisprudência vigente do STF é assente também no sentido de que o princípio constitucional da não-culpabilidade impede que se lance o nome do réu no **rol dos culpados antes do trânsito em julgado** da decisão condenatória (**HC 82.812/PR, rel. Min. Carlos Velloso, julg. 3/6/2003**).

Outro tópico que merece atenção: **conversas informais** mantidas com autoridades policiais ou com representantes do ministério público em que a pessoa relate algum fato que possa vir a incriminá-lo, **não valem como prova**, ou seja trata-se de **prova ilícita**.

Já o princípio da identificação criminal pressupõe que não haverá identificação criminal do civilmente identificado, mas **salvaguarda as ressalvas previstas em lei**! Algumas dessas ressalvas incluem a identificação criminal no caso de os documentos de identidade, motorista etc estiverem rasurados, com indício de falsificação ou com homônimos,

com quando essa identificação for essencial às investigações e outras, previstas na **Lei 12.037/2009**, inclusive com a coleta de **material biológico**.

Ação penal privada subsidiária da pública

Segundo o inciso LIX do art. 5º:

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

No âmbito do direito penal, as ações são via de regra **públicas**, de iniciativa privativa do Ministério Público (art. 129, I, CF). Entretanto, se não for intentada no prazo legal, normalmente 5 dias se preso o indiciado e 15 dias se solto, pode o ofendido (particular) entrar com a ação privada, subsidiariamente.

Publicidade dos atos processuais

Segundo o inciso LX do art. 5º:

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

Em algumas hipóteses, a Constituição assegura a preservação da intimidade e do interesse social, nos termos definidos **pela lei**.

Lembre-se ainda de que o **inquérito policial** não é ato processual, constituindo-se em procedimento administrativo sigiloso, com hipóteses taxativas de quebra do sigilo, dentre elas a Súmula Vinculante 14, de que tratamos acima.

Pressupostos da prisão

O assunto prisão é tratado em diversas vertentes na Constituição Federal. A primeira delas diz respeito aos pressupostos básicos para que alguém seja recolhido à prisão e os direitos do preso, previstos nos incisos LXI a LXVI do art. 5º:

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

Essa regra encontra exceções nos casos de **transgressão ou crime militar**, durante **o estado de defesa e do estado de sítio (arts. 136 e 139 da CF)** e no caso de **recaptação do réu condenado e evadido**, nos termos do art. 684, do CPP:

Art. 684. A recaptação do réu evadido não depende de prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por qualquer pessoa.

É ilegal e inconstitucional também qualquer espécie de prisão administrativa para averiguação, caracterizando **abuso de autoridade**.

Entretanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão de 2014, entendeu que a condução de suspeito até a presença da autoridade policial para ser inquirido sobre os fatos investigados, sem ordem judicial escrita e nem situação de flagrante delito, e ainda, **mantê-lo custodiado na delegacia de polícia até a decretação de sua prisão temporária não é inconstitucional**.

O STF assentou que a própria Constituição asseguraria, em seu art. 144, § 4º, às polícias civis, dirigidas por delegados de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Também o art. 6º, II a VI, do CPP, por sua vez, estabelecerá as providências a serem tomadas pelas autoridades referidas quando tivessem conhecimento da ocorrência de um delito. Assim, pode a polícia, autonomamente, buscar a elucidação de crime, sobretudo nas circunstâncias descritas. Os agentes policiais, sob o comando de autoridade competente (CPP, art. 4º), possuem

legitimidade para tomar todas as providências necessárias, incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar esclarecimentos, resguardadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos (**HC 107.644, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julg. em 6/9/2011**).

Também para o Supremo Tribunal Federal, as **falhas de fundamentação na decisão de prisão preventiva** não podem ser supridas nem sanadas por informações prestadas *a posteriori* pelo órgão prolator. Nesse sentido, a idoneidade formal e substancial da motivação da decisão há de ser aferida segundo o que nela haja posto o juiz da causa, não sendo dado ao Tribunal do recurso ou do Habeas Corpus, que a impugnem, suprir-lhe as faltas ou complementá-las (**HC 90.064/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julg. 8/5/2007**). Também segundo o Supremo, sendo a **falta da motivação da prisão cautelar causa de nulidade da decisão**, não a podem suprir ou retificar nem as informações do órgão prolator da decisão, nem o acórdão das instâncias superiores ao negar o habeas corpus ou desprover recurso (**HC 84.293/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julg. 29/6/2004**).

Em 2017, o STF assentou que a celebração de **acordo de colaboração premiada** não constitui, por si só, motivo para **revogação de prisão preventiva**. De outra borda, a mesma prisão preventiva não pode decretada em razão de descumprimento do acordo premiado. Entendeu a 2ª Turma do STF não haver relação direta entre a prisão preventiva e o acordo de colaboração. A Lei 12.850/2013 não apresenta a revogação da prisão preventiva como benefício previsto pela realização de acordo de colaboração premiada. Há que se verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos da preventiva, nos termos da legislação penal (**HC 138.207/PR, rel. Min. Edson Fachin, julg. em 25/4/2017**).

Os incisos LXII a LXIV tratam dos direitos do preso:

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

Os incisos LXV e LXVI tratam da **prisão ilegal** e da **liberdade provisória**:

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

Já o inciso LXVII trata da chamada prisão civil por dívida, assunto no qual vamos nos demorar um pouco:

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Quem é o **responsável por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia**? É o devedor de prestação de alimentos, ou pensão alimentícia, que não quer e não tem motivos para não efetuar o pagamento.

É claro que se o devedor estiver em situação de hipossuficiência e não tiver condições de arcar com a prestação alimentícia, não será considerado inadimplente voluntário e inescusável.

Depositário é aquele que figura num contrato de depósito (direito privado) do qual existem 2 sujeitos: **depositante** e **depositário**. O objeto típico de um contrato de depósito é sempre coisa móvel. O titular desta coisa móvel a deposita, ou seja, a deixa sob custódia de um terceiro, que é o depositário.

O depositante espera, obviamente, que o depositário restitua a coisa móvel quando solicitado, nas condições de conservação e manutenção em que foi entregue. Caso o depositário não cumpra o contrato, seja por perda, alienação, consumo ou destruição do bem sob depósito, a Constituição autoriza a **prisão do depositário infiel**. Mas essa prisão, atualmente, **não é mais aplicável**. Vamos entender porquê, analisando a cronologia a seguir:

I - **1988**: a CF/88 criou 2 hipóteses de prisão civil: a do devedor de alimentos; e a do depositário infiel;

II - **1992**: firmado o Pacto de San José da Costa Rica, Tratado Internacional de Direitos Humanos, que prevê apenas a hipótese de prisão civil do **devedor de alimentos**. Surge, então, um conflito entre a Constituição Federal e o Tratado de San José, sendo que boa parte da doutrina e da jurisprudência, na época, passou a entender que o Pacto teria afastado do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade da prisão do depositário infiel.

III - **1997**: o STF firma entendimento de que os Tratados Internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil têm status de Lei Ordinária Federal. Como lei ordinária não poderia contrariar a CF, logo, permaneceram válidas as duas hipóteses de prisão civil.

IV - **2004**: a EC 45/2004 estabelece que os Tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados na forma do parágrafo 3º do art. 5º têm status de emenda constitucional; isso não mudou em nada o entendimento do STF de 1997, somente passou a permitir que os Tratados Internacionais, daí por diante, pudessem se aprovados pelo rito especial de Emenda.

V - **2008**: o STF firma o entendimento de que os tratados internacionais de direitos humanos possuem status **supralegal** (Infraconstitucional, acima das leis e abaixo da Constituição); assim, o status do tratado de direitos humanos, a partir daí, dependeria de como ele foi incorporado. Se foi incorporado pelo rito ordinário, ele terá status de **supralegalidade**. Se for aprovado pelo rito de emenda, ele terá status **constitucional**.

Diante disso, o Pacto de San José da Costa Rica **derrogou legislação pretérita que regulamentava a prisão civil do depositário infiel** impedindo igualmente a sua regulamentação futura, pois o referido tratado é superior à lei ordinária. Assim, hoje, **não é mais possível a prisão do depositário infiel**. A única prisão legítima por dívida civil é a do devedor **inescusável de alimentos**. A esse respeito, o STF assentou:

"Há o caráter especial do Pacto Internacional dos Direitos Civis Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ratificados, sem reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado o lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo **supralegal** dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação" (**HC 95.967, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, julg. em 11/11/2008**).

Isso está definitivamente assentado em Súmula Vinculante:

Súmula Vinculante 25/STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

Guarde ainda que nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a norma do art. 5º, LXVII, de que "*Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel*" qualifica-se como típica norma revestida de **eficácia contida ou restringível**, eis que, em função de seu próprio conteúdo material, contempla a possibilidade de **o legislador comum limitar o alcance da vedação constitucional** pertinente à prisão civil, autorizando-o a excepcionar a cláusula proibitória em duas únicas hipóteses: (a) inadimplemento de obrigação alimentar e (b) infidelidade depositária (**RE 249.970-RS, Rel. Min. Celso de Mello**).

Assistência judiciária gratuita e indenização por erro judiciário

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Função que é exercida pela **Defensoria Pública** (art. 134, CF).

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação da EC 80/2014)

Trata-se de um direito de prestação de **um serviço essencial pelo Estado**, pautado na dignidade da pessoa humana. Segundo o STF "a prestação jurisdicional é uma das formas de se concretizar o princípio da dignidade humana, o que torna imprescindível seja ela realizada de forma célere, plena e eficaz" (**Rcl 5.758, rel. min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 07/08/2009**).

Também segundo o STF, "a Constituição Federal alçou a defensoria pública ao patamar de instituição permanente, essencial à prestação jurisdicional do Estado. (...) Pelo que, sob este último prisma, se revela como instrumento de democratização do acesso às instâncias judiciárias, de modo a efetivar o valor constitucional da universalização da justiça (inciso XXXV do art. 5º do Texto Magno). Fazendo de tal acesso um direito que se desfruta às expensas do Estado, em ordem a se postarem (as defensorias) como um *luminoso ponto* de interseção do constitucionalismo liberal com o social. Vale dizer, fazem com que um clássico direito individual se mescle com um moderno direito social" (**AI 739.151 PI, rel. Min. Rosa Weber, julg. em 24/4/2013**).

Nesse sentido, o STF decidiu ainda que não implantação das defensorias públicas dos Estados configura omissão estatal que compromete e frustra direitos fundamentais de pessoas necessitadas. Trata-se de Intervenção jurisdicional concretizadora de programa constitucional destinado a viabilizar o acesso dos necessitados à orientação jurídica integral e à assistência judiciária gratuitas (CF, art. 5º, LXXIV, e art. 134).

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Trata-se de garantia individual contra o abuso do Estado-Juiz, e tem sentido amplo, de modo a alcançar não apenas a prisão preventiva injustificada ou o modo incorreto de cumprimento do regime da pena, mas também os demais atos do juiz, ainda que não culminem na aplicação de medida restritiva de liberdade.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que, tratando-se de atos jurisdicionais emanados da soberania do Estado, a atribuição de responsabilidades por danos decorrentes da atividade judicial está condicionada a **expressa disposição legal**, prevista no art. 630 do Código de Processo Penal e agora, no art. 143 do CPC/2015 (**dentre outros, RE 228.035-AgR/SC, rel. Min. Carlos Velloso**).

Tenha em mente que o STF assentou também o entendimento de que o decreto judicial de prisão preventiva, quando suficientemente fundamentado e obediente aos pressupostos que o autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República, **mesmo que o réu ao final do processo venha a ser absolvido ou tenha sua sentença condenatória reformada** na instância superior (**RE 429.518/SC, Rel. Min. Carlos Velloso**).

O **Novo Código de Processo Civil de 2015** delimita as hipóteses em que o magistrado responde por erro judicial:

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias.

Gratuidades

Os incisos LXXVI e LXXVII estabelecem a gratuidade para determinadas prestações de serviços públicos e dois remédios constitucionais:

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: a) o registro civil de nascimento; b) a certidão de óbito;

Quanto a estes incisos, o STF decidiu que embora a atividade desenvolvida pelos titulares de serventias de notas e registros seja de cunho privado, análoga à atividade empresarial, sujeita-se a regime de direito público, assentando que não ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os reconhecidamente pobres do pagamento de emolumentos pela expedição de registro civil de nascimento e óbito bem como a **primeira certidão respectiva (ADC 5, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julg. em 11/6/2007)**.

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.

A ação de **habeas corpus**, de natureza penal e de rito especial é **gratuita e isenta de custas, não havendo pagamento do ônus de sucumbência** - honorários advocatícios. Assim também ocorre com o **habeas data**, mas para este é necessário **advogado** para impetração. Também é gratuita a **ação popular**.

Celeridade Processual

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela EC 45/2004)

Diversos julgados do STF versam sobre o princípio da celeridade processual, norma de aplicação plena e imediata, sem que o Supremo defina, objetivamente, o que venha a ser considerado "razoável duração". Dentre os mais relevantes, destacamos:

A razoável duração do processo **se aplica no âmbito administrativo** (RMS 28.172); Extrapola o limite do razoável o não julgamento de recurso de apelação interposto há quase dois anos e meio (HC 99.425); O **excesso de prazo**, mesmo tratando-se de delito hediondo (ou a este equiparado), não pode ser tolerado, impondo-se, ao Poder Judiciário, a imediata **revogação da prisão cautelar** do indiciado ou do réu (HC 100.574); O excesso de prazo **não resulta de simples operação aritmética**, e envolve complexidade do processo, atos procrastinatórios, número de réus envolvidos e outros (HC 97.461)

Proteção de Dados

A Emenda Constitucional nº 115/2022 também estabeleceu o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Este dispositivo constitucional assegura que todos os indivíduos têm o direito de que seus dados pessoais sejam protegidos por lei, abrangendo tanto as informações armazenadas fisicamente quanto as em ambientes digitais.

A proteção dos dados pessoais refere-se ao cuidado e controle sobre informações que identificam ou podem identificar uma pessoa, como nome, endereço, dados bancários e até hábitos de navegação na internet.

Com a evolução tecnológica, e o aumento no uso de dados digitais, essa proteção tornou-se ainda mais crucial para preservar a privacidade e os direitos fundamentais dos cidadãos.

Esse direito é regulamentado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estabelece as diretrizes sobre como os dados podem ser coletados, armazenados, tratados e compartilhados, garantindo maior transparência e segurança às informações pessoais.

A inclusão desse inciso no texto constitucional reforça a importância da privacidade como um direito fundamental e protege os cidadãos contra o uso indevido de suas informações, sendo um reflexo da necessidade de adaptação da legislação frente aos avanços tecnológicos e o uso massivo de dados na sociedade moderna.

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)



Veja como foi cobrado!

(FCC/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/SEFAZ PI/2015) No curso de processo administrativo disciplinar, tendo por objeto a apuração de conduta supostamente irregular de servidor da Administração pública direta, identificou-se a necessidade de realização dos seguintes atos instrutórios:

- a) busca e apreensão de documentos no ambiente de trabalho e na residência do servidor;
- b) quebra de seus sigilos fiscal e bancário; e
- c) interceptação de suas comunicações telefônicas. Sem o consentimento do servidor cuja conduta é apurada, dependerá de prévia determinação judicial a obtenção das medidas referentes à

(A) busca e apreensão de documentos na residência do servidor; e interceptação de comunicações telefônicas, assegurado,

no primeiro caso, o direito à ampla defesa e ao contraditório.

(B) busca e apreensão de documentos no ambiente de trabalho e na residência do servidor; quebra de sigilos fiscal e bancário; e interceptação de comunicações telefônicas, assegurado, em qualquer caso, o direito à ampla defesa e ao contraditório.

(C) busca e apreensão de documentos na residência do servidor; quebra de sigilo bancário; e interceptação de comunicações telefônicas, assegurado, no último caso, o direito à ampla defesa e ao contraditório.

(D) busca e apreensão de documentos na residência do servidor; e quebra de sigilos fiscal e bancário, assegurado, no último caso, o direito à ampla defesa e ao contraditório.

(E) quebra de sigilos fiscal e bancário; e interceptação de comunicações telefônicas, assegurado, no primeiro caso, o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Questão anulada pela FCC. Em primeiro lugar, o princípio do contraditório e da ampla defesa informa todos processos judiciais e administrativos, alcançando igualmente a busca e apreensão e a interceptação telefônica. Além disso, a interceptação telefônica não pode ser determinada para instruir processo administrativo disciplinar, nem mesmo judicialmente. Apenas poderia figurar no PAD como **prova emprestada de feito criminal** onde os fatos e a autoria estejam vinculados ao processo administrativo. Só aí temos dois erros no item "a".

Vamos analisar cada uma das espécies de exceções à garantia do Direito à Privacidade listadas na questão, à luz da Constituição e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(i) busca e apreensão de documentos no ambiente de trabalho e na residência do servidor: sem o consentimento do servidor, já que tanto o ambiente de trabalho quanto a residência estão inseridos no conceito de domicílio, esta incursão **só poderá ser realizada com prévia autorização judicial**, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório. Isso não impede, conforme a jurisprudência do Supremo, a entrada, durante a noite, para **instalação de escuta ambiental** em estabelecimento profissional investigado por prática criminosa. Fundamento constitucional: art. 5º, XI:

*XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, **por determinação judicial**;*

(ii) quebra de sigilo bancário e fiscal: pode ser determinada tanto pelo magistrado quanto pelo **Plenário** das Casas do Congresso Nacional, **Comissões Parlamentares** ou Comissões Parlamentares de Inquérito (**CPIs**); **Não pode** ser determinada pelo Tribunal de Contas da União, nem por agentes do Fisco, ainda que na função

fiscalizadora e nem pelo Ministério Público, ainda que investigando malversação de recursos públicos, segundo a mais recente jurisprudência do STF. A alternativa "a" foi anulada porque

(ii) interceptação de suas comunicações telefônicas: só pode ser determinada por decisão judicial, nos termos do inciso XII do art. 5º. Aqui, o STF entende que pela sua natureza cautelar, o contraditório será diferido **para a ação penal porventura deflagrada**.

*XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, **no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;***

Além disso, a interceptação telefônica **não poderia ser feita para instruir PAD**, nem mesmo por decisão judicial, a não ser na hipótese de prova emprestada do processo criminal análogo, conforme remansosa jurisprudência do STF.

Entretanto, o STF considera como excludente de ilicitude, a gravação feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, para o **exercício de defesa contra chantagem, ameaça ou outra prática criminosa** a que o interessado esteja submetido. Tal gravação ou interceptação poderá ser feita inclusive por terceiro, a pedido do interessado:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROVA. LICITUDE. GRAVAÇÃO DE TELEFONEMA POR INTERLOCUTOR. É LÍCITA A GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES, OU COM SUA AUTORIZAÇÃO, SEM CIÊNCIA DO OUTRO, QUANDO HÁ INVESTIDA CRIMINOSA DESTE ÚLTIMO. É INCONSISTENTE E FERE O SENSO COMUM FALAR-SE EM VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE QUANDO INTERLOCUTOR GRAVA DIÁLOGO COM SEQUESTRADORES, ESTELIONATÁRIOS OU QUALQUER TIPO DE CHANTAGISTA. ORDEM INDEFERIDA" (**HC 75.338/RJ - Rel. Ministro Nelson Jobim - DJ 25/09/98**).

(**CESPE/PROCURADOR/PGE AL/2008**) Ao analisar a constitucionalidade da legislação brasileira acerca da prisão do depositário que não adimpliu obrigação contratual, o STF, recentemente, concluiu no sentido da derrogação das normas estritamente legais definidoras da custódia do depositário infiel, prevalecendo, dessa forma, a tese do status de suprallegalidade do Pacto de San José da Costa Rica.

Exatamente o que apresentamos sobre o status conferido pelo STF aos tratados internacionais de direitos humanos, especialmente ao Pacto de San José da Costa Rica, que se não revogou a Constituição Federal o fez quanto aos dispositivos legais que tratavam da prisão do depositário infiel.

Gabarito: **CERTO**.

(**CESPE/CONSULTOR LEGISLATIVO/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2014**) Conforme entendimento do STF, não é possível o exercício do direito de resposta com o intuito de retificar matéria publicada em jornal impresso, por ser tal direito destituído de eficácia plena, dada a não recepção da Lei de Imprensa pela CF.

Tema ligado à liberdade de expressão. Para a sua prova, é importante que você saiba que o Supremo Tribunal Federal realmente declarou que a Lei de Imprensa (Lei nº 5250/67) é incompatível com a atual ordem constitucional. Ao mesmo tempo, o STF entendeu que a ausência de regulação legal pela não recepção da Lei de

Imprensa pela Constituição de 1988 **não é obstáculo para o exercício dessa prerrogativa por quem se sentir ofendido, seja para exigir o direito de resposta ou de retificação.**

Item **errado**.

(FGV/ADVOGADO/SENADO/2008) A respeito do catálogo de direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir:

I. A todos é assegurado o direito de reunião, para fins pacíficos, em locais abertos ao público, independentemente de autorização e de aviso prévio à autoridade competente.

II. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação de autoridade judicial ou de Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito.

III. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

IV. A apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito será assegurada na forma e observados os limites previstos em lei complementar.

Assinale:

(A) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

(C) se apenas a afirmativa I estiver correta.

(D) se apenas a afirmativa III estiver correta.

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

O item I está incorreto, pois o prévio aviso à autoridade competente é imprescindível (art. 5º, XVI). Essa autoridade, normalmente, é a polícia militar.

O item II está errado pois a Constituição e nem tampouco a jurisprudência do STF excepcionalizam a reserva de jurisdição para a entrada em domicílio a qualquer hora do dia ou da noite fora das hipóteses do inciso XI do art. 5º (flagrante delito ou desastre ou prestar socorro). Assim, durante o dia, apenas por **determinação judicial**. CPI não tem essa prerrogativa, devendo solicitar ao juiz competente a medida invasiva. Importante lembrar que o STF acolheu, recentemente, a possibilidade de adentrar, por determinação judicial, domicílio profissional de advogado, durante a noite, para instalação de escutas ambientais.

Correto o item III, por reproduzir literalmente o inciso XXXIII do art. 5º. Lembre-se que o remédio constitucional adequado para assegurar o exercício dessa garantia de direito à informação é o **mandado de segurança** e não o habeas data!

O item IV está incorreto pois trata-se de norma constitucional de eficácia plena, produzindo, desde já, os seus plenos efeitos, sem necessidade de intermediação de lei ordinária ou complementar. O citado inciso XXXV do art. 5º trata do princípio da inafastabilidade de jurisdição ou jurisdição una.

Entretanto, cabe aqui um comentário. No Brasil, esse princípio é **temperado** ou **condicionado**, pois em três hipóteses, a busca pela tutela jurisdicional deverá ser precedida pelo recurso à esfera administrativa:

a) Habeas data: há de se comprovar que o interessado buscou o direito de informação sobre sua pessoa constante de bancos de dados oficiais ou de caráter público e então deverá entrar com o recurso administrativo. Somente após esgotadas as ferramentas extrajudiciais, deverá buscar a tutela do Poder Judiciário;

b) Justiça Desportiva: apesar do nome, não pertence ao Judiciário, trata-se de instância de caráter administrativo, que deverá ter os seus recursos próprios esgotados antes de se buscar a tutela judicial;

c) Descumprimento de Súmula Vinculante por ato administrativo: normalmente, o descumprimento de uma Súmula Vinculante emanada do STF induz à utilização do expediente da Reclamação junto ao próprio Supremo. Entretanto, isso ocorre no caso de desobediência judicial, ou seja, um juiz ou tribunal que tenha contrariado, em sua decisão ou despacho, o conteúdo da Súmula. No caso de ato administrativo, o interessado ou lesado deverá buscar primeiramente as instâncias administrativas antes de se valer da ação judicial

Gabarito: **alternativa D.**

(FGV/FISCAL DE RENDAS/SEFAZ RJ/2010) Em relação aos direitos e garantias fundamentais expressos da Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir:

I. os direitos e garantias expressos na Constituição Federal constituem um rol taxativo.

II. todos os tratados e convenções internacionais de direitos humanos internalizados após a EC-45/2004 serão equivalentes às emendas constitucionais.

III. as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

I – item incorreto: a Constituição Federal, no art. 5º, § 2º admite expressamente outros direitos e garantias, espalhados pelo texto constitucional ou ainda que possam vir a ser criados, inclusive por tratados internacionais.

II – Item incorreto: conforme § 3º do o art. 5º da CF (incluído pela EC-45/2004), apenas "os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais".

III – Item correto: trata-se do disposto no § 1º do art. 5º.

Gabarito: **alternativa B.**

(CESPE/JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO/TRT 1ª REGIÃO/2011) Assinale a opção correta acerca dos direitos e garantias fundamentais.

(A) A CF não admite o ingresso no domicílio legal sem consentimento do morador.

(B) Embora a CF admita a decretação, pela autoridade judicial, da interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, é possível a utilização das gravações no processo civil ou administrativo, como prova emprestada.

(C) Diante da natureza dos interesses envolvidos, a administração pública pode legitimamente determinar a quebra dos sigilos fiscal e bancário em procedimento administrativo na esfera tributária.

(D) O princípio da inafastabilidade da jurisdição tem aplicação absoluta no sistema jurídico vigente, o qual não contempla a hipótese de ocorrência da denominada jurisdição condicionada.

(E) A CF assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, razão pela qual, no âmbito do processo administrativo disciplinar, é imprescindível a presença de advogado.

Item “A”: Prescreve o art. 5º, XI que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Item “B”: a prova emprestada é possível desde que haja correlação entre os fatos apurados no processo penal e os do processo civil ou administrativo; Item correto.

Item “C”: Essa possibilidade não era possível (RE 389808/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 15.12.2010.). Entretanto, a nova jurisprudência do STF permite a quebra de sigilo em procedimento administrativo ou fiscal aberto, por parte das autoridades fiscais. Questão desatualizada.

Item “D”: O princípio da inafastabilidade da jurisdição é previsto no inciso XXXV do art. 5º da CF e prescreve que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No Brasil, mesmo a última decisão administrativa irreformável pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. A esfera administrativa, em regra é facultativa, com algumas exceções, nas quais o cidadão é obrigado a percorrer as instâncias administrativas antes de buscar a tutela do Judiciário. São três as jurisdições condicionadas: justiça desportiva, Habeas Data e descumprimento de Súmula Vinculante por ato administrativo..

Item “E”: Guarde que a presença de advogado é **dispensável** no processo administrativo, inclusive perante o TCU. Exige-se no âmbito administrativo, por outro lado, quando a matéria for de tal forma específica e complexa que impeça ao homem médio, não versado nas ciências jurídicas, exercer sua defesa plenamente.

Gabarito: **alternativa B.**

(FGV/ADVOGADO/BADESC/2010) Considerando o direito fundamental de privacidade assegurado no art. 5º da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

(A) A quebra de sigilo de movimentações financeiras do indivíduo pode ser decretada por ordem judicial, por deliberação das comissões parlamentares de inquérito e pelo ministério público, nas investigações de sua competência.

(B) A interceptação das comunicações telefônicas pode ser decretada por ordem judicial em processo de natureza penal, civil ou administrativa, na forma da lei.

(C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. É vedado o ingresso durante a noite, salvo no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, na forma da lei.

(D) A Constituição só permite a interceptação das comunicações telefônicas nos casos de investigação de crimes de terrorismo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública, por ordem judicial, na forma de lei complementar.

(E) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Item “A”: a quebra de sigilo fiscal e bancário é espécie de direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevista no art. 5º, X da CF. o Ministério Público não tem competência para determinar quebra de sigilo bancário, nem mesmo em procedimento tendente a investigar desvio de recursos públicos, conforme último posicionamento do STF. Item errado.

Item “B”: a interceptação de comunicações telefônicas não pode ser decretada em processo de natureza civil ou administrativa. No máximo, as transcrições podem ser utilizadas como prova emprestada nestes processos, desde que sejam conexos com o principal. (art. 5º, XII); Item errado.

Item “C”: o art. 5º, XI exige que a invasão por ordem judicial se dê durante o dia. Jurisprudência recente do STF excepciona a possibilidade de instalação de escuta telefônica em ambiente profissional do investigado durante a noite. Item errado.

Item “D”: De acordo com o art. 5º, XII, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a **lei** estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Item errado.

Item “E”: Correta reprodução do art. 5º, XII, observada a ressalva comentada no item “B”.

Gabarito: **alternativa E**.

Resumo

✚ Estrutura do art. 5º da CF/88

- Trata **dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos**.
- Contém **4 parágrafos** com disposições importantes sobre sua aplicabilidade e expansão.

⚖️ § 1º – Aplicação imediata

- Determina que os direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**.
- Nem todas têm eficácia plena: há normas de eficácia **limitada e contida**.
- Doutrinadores:
 - **Sérgio Moro**: juízes podem suprir omissões estatais para garantir direitos.
 - **Ingo Sarlet**: § 1º confere **juridicidade reforçada** aos direitos fundamentais.

📖 Art. 60, § 4º, IV – Cláusulas pétreas

- Os **direitos e garantias individuais** não podem ser abolidos nem por emenda constitucional.
- Isso inclui não apenas os do art. 5º, mas também os espalhados pela Constituição.

🌐 § 2º – Princípio da não taxatividade

- Os direitos expressos na Constituição **não excluem** outros direitos:
 - Derivados do regime e princípios da CF/88.
 - Presentes em tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

🌐 § 3º – Status constitucional de tratados internacionais de direitos humanos

- Se aprovados em **dois turnos, por 3/5 dos votos em cada casa do Congresso, têm status de emenda constitucional**.
- Exemplo:
 - **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência** (Decreto 6.949/2009).
 - **Tratado de Marraquexe** (Decreto 9.522/2018).

📘 Tratados internacionais no ordenamento jurídico

- **Etapas de incorporação**:

- **Assinatura** pelo Presidente da República (art. 84, VIII, CF).
- **Envio ao Congresso** com justificativa.
- **Aprovação pelo Congresso** via Decreto Legislativo (art. 49, I, CF).
- **Ratificação por Decreto Presidencial:** dá força de lei ordinária.
- **Classificação:**
 - **Tratados comuns:** força de **lei ordinária**.
 - **Tratados de direitos humanos:**
 - Se **não** aprovados com quórum qualificado → **status supralegal** (acima da lei, abaixo da CF).
 - Se **aprovados com quórum qualificado** → **status constitucional** (equivalente a emenda).

⚠ **Exemplos importantes de tratados com status supralegal**

- **Pacto de San José da Costa Rica:**
 - Derrogou a **prisão do depositário infiel**, mesmo prevista no art. 5º, LXVII.
 - Fundamentou a **Súmula Vinculante 25**: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”.
- **Convenções sobre transporte aéreo:**
 - Prevalecem sobre o CDC conforme art. 178 da CF, mas **não** têm status supralegal (não tratam de direitos humanos).

📌 **Princípio da Igualdade (Art. 5º, caput e inciso I, CF/88)**

1. Igualdade Formal e Material

- **Igualdade na lei:** vincula o **Legislador**, que deve elaborar normas gerais e abstratas sem discriminação.
- **Igualdade perante a lei:** vincula o **Judiciário e Administração Pública**, proibindo tratamento desigual na aplicação das normas.

2. Abrangência do Princípio

- Aplica-se **a todos**, inclusive estrangeiros em trânsito no país (interpretação conforme STF).
- Possibilidade de uso de **remédios constitucionais** por estrangeiros: habeas corpus, mandado de segurança etc.

3. Direitos restritos a brasileiros

- Ex: **ação popular** é restrita a **cidadãos brasileiros e portugueses equiparados** (CF, art. 12, §1º).

4. Desdobramentos do Princípio

- Proibição ao **racismo** (Art. 5º, XLII)
- Proibição de discriminação em salários/funções por **sexo, cor ou estado civil** (Art. 7º, XXX)
- Igualdade nas **licitações públicas** (Art. 37, XXI)
- Igualdade **tributária** (Art. 150, II)
- Proibição de **tribunal de exceção** (Art. 5º, XXXVII)

5. Ações afirmativas e discriminação positiva

- Medidas estatais para compensar desigualdades históricas: **cotas raciais, inclusão de PCDs**, proteção à mulher.
- Devem ser **temporárias, proporcionais e justificadas**.
- **STF** considera constitucionais desde que não se tornem privilégios permanentes.

6. Proteção especial à mulher

- Ex: **Aposentadoria diferenciada**, proteção ao trabalho (CF, arts. 7º, XVIII-XIX; 40, §1º, III; 201, §7º).

7. Discriminação etária em concursos

- Permitida apenas quando **justificada pela natureza do cargo** (Súmula STF 683).

8. Reconhecimento de união homoafetiva

- STF reconhece como **entidade familiar**, com os mesmos direitos da união estável heteroafetiva (ADPF 132).

📌 Princípio da Legalidade (Art. 5º, II, CF/88)

1. Legalidade ampla (para o cidadão)

- Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em **virtude de lei**.
- "Lei" = **norma jurídica** em sentido amplo (leis formais + atos com força de lei + regulamentos).

2. Legalidade administrativa (para o Estado)

- O agente público **só pode fazer** o que estiver **expressamente autorizado em lei**.

3. Reserva legal (legalidade estrita)

- Exige **lei formal ou ato normativo com força de lei** (ex: MP, leis delegadas).
- Ex: interceptações telefônicas, criação de cargos públicos, regras de nacionalidade etc.

4. Lei em sentido formal vs material

- **Formal:** elaborada conforme o processo legislativo.
- **Material:** conteúdo GIA (geral, impessoal e abstrato).
- Nem toda lei formal tem conteúdo material (ex: normas específicas e individualizadas).

📌 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

- Fundamento da República (art. 1º, III da CF).
- Desdobramento nos incisos III e XLVII do art. 5º:
 - Proibição de tortura e tratamento desumano ou degradante.
 - Proibição de penas: morte (salvo guerra declarada), perpétuas, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis.
- 🌟 **Jurisprudência relevante:**
- **ADI 4.275/2018 (STF):** Transexuais têm direito de alterar nome e gênero no registro civil **sem necessidade de cirurgia ou autorização judicial**.
- Interpretação conforme o **Pacto de San José da Costa Rica:**
 - Art. 1º: Proibição de discriminação.
 - Art. 18: Direito ao nome.

📌 Liberdade de Pensamento e Suas Limitações

- Garantia no art. 5º, IV da CF: livre manifestação, **vedado o anonimato**.
- Limitações constitucionais: arts. 5º, V, X, XXXIII e 220, §3º, I.
- ⚖️ **Sobre anonimato:**
- STF: denúncia anônima **não pode fundamentar sozinha** ação penal.
- Possível uso apenas para **investigação preliminar informal**.
- Documentos anônimos não podem integrar processos, exceto se forem:
 - Produzidos pelo acusado.
 - Corpo de delito (ex: bilhetes de sequestro).

📌 Direito de Resposta (art. 5º, V)

- Direito de resposta proporcional + indenização por dano material, moral ou à imagem.

💡 Entendimentos do STF/STJ:

1. Indenização por lesão deformante = **dano moral**.

2. Indenização + direito de resposta possível contra imprensa, **sem censura prévia**.
3. **Discurso de ódio** (racismo, discriminação) não é protegido pela liberdade de expressão.
4. Direito de resposta não pode violar intimidade do agressor.
5. **ADPF 130/2009**: STF declarou inconstitucionalidades da Lei de Imprensa.
6. **RE 683.751/RS**: Direito de resposta judicial é assegurado pela CF (aplicabilidade imediata).
7. **ADI 5415**: direito de resposta pode ter suspensão cautelar por juiz individualmente.
8. Lei 13.188/2015 regulamenta o direito de resposta.
9. **Pessoas jurídicas** também têm:
 - Direito à honra, nome, imagem (inclusive dano moral – Súmula 227/STJ).
 - **STF**: não é direito fundamental de nível constitucional, portanto, sem repercussão geral.
 - **Pessoa jurídica de direito público** também possui garantias processuais (due process).

✳ **Liberdade de Expressão e Proibição de Censura**

- Art. 5º, IX: livre expressão artística, científica, intelectual, sem censura.
- Art. 220 e seus parágrafos:
 - Proibição de censura política, ideológica e artística.
 - Nenhuma lei pode restringir a liberdade jornalística.

⚠ Classificação indicativa:

- **Não é censura**, mas medida de proteção a crianças e adolescentes.
- STF (ADI 2404): classificação é **indicativa**, não autorizativa.
- A expressão “em horário diverso do autorizado” (ECA) foi declarada inconstitucional.

✳ **Liberdade de consciência, crença e escusa de consciência (Art. 5º, VI, VII e VIII)**

- ▶ **Liberdade de crença (Art. 5º, VI)**
 - Inviolável a liberdade de consciência e crença.
 - Assegurado o livre exercício de cultos religiosos e a proteção a locais e liturgias.
 - **Estado laico** ≠ Estado ateu.
 - **Laico**: sem religião oficial, garante liberdade religiosa.
 - **Confessional**: adota religião oficial (ex.: Brasil até 1824).
 - **Teocrático**: normas civis subordinadas a normas religiosas (ex.: alguns países islâmicos).
- ▶ **Assistência religiosa (Art. 5º, VII)**
 - Garante assistência religiosa em hospitais, presídios e unidades de internação.
 - **Divergência doutrinária sobre a eficácia**:
 - Alexandre de Moraes: eficácia limitada.
 - Pedro Lenza: eficácia contida.
 - Normas regulamentadoras:
 - **Lei 9.982/2000**: acesso de religiosos aos internados.
 - **Lei 6.923/1981**: Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas.
- ▶ **Escusa de consciência (Art. 5º, VIII)**
 - Ninguém será privado de direitos por crença religiosa, filosófica ou política, **exceto** se:
 - Invocar a crença para se eximir de obrigação legal e

- Recusar-se a cumprir prestação alternativa.
- **Consequência:** suspensão de direitos políticos (art. 15, IV).
- **Norma de eficácia contida**, regulamentada pela **Lei 8.239/1991**.

✚ **Ensino religioso (Art. 210, § 1º)**

- Ensino religioso de matrícula **facultativa** nas escolas públicas de ensino fundamental.
- STF (ADI 4.439/DF):
 - Julgou constitucional o **ensino confessional** nas escolas públicas.
 - Destacou que a laicidade brasileira não impede condutas **positivas** do Estado em favor da liberdade religiosa.

✚ **Imunidade tributária para templos religiosos (Art. 150, VI, “b”)**

- Vedação à instituição de impostos sobre:
 - Templos de qualquer culto.
 - Suas organizações assistenciais e beneficentes (EC 132/2023).
- **Limitação (Art. 150, § 4º):**
 - Abrange apenas patrimônio, renda e serviços ligados à finalidade essencial da entidade.
 - Não se aplica a atividades comerciais desvinculadas da missão religiosa.

✚ **Inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem (Art. 5º, X)**

- Garante o direito à indenização por dano **material ou moral** decorrente de violação.
- Protege pessoas físicas e jurídicas.
- Não exige prova de ofensa à reputação, basta a publicação não consentida que gere constrangimento.
- **► Jurisprudência relevante:**
 - **STF:** indevida a coação para realização de exame de DNA em ações de paternidade.
 - **STJ:** danos morais incluem perturbações psíquicas e danos estéticos.

✚ **Sigilo bancário e fiscal**

- Espécies do gênero “direito à privacidade”.
- Possível quebra:
 - Por decisão judicial.
 - Por **CPIs** com fundamentação razoável.
- **Mudança de entendimento do STF:**
 - Recursos públicos não estão protegidos pelo sigilo bancário (Lei Complementar 105/2001).

🔒 **Inviolabilidade Domiciliar (Art. 5º, XI, CF/88)**

- **Regra geral:** Ninguém pode entrar na casa sem consentimento do morador.
- **Exceções constitucionais:**
 - Flagrante delito
 - Desastre
 - Prestar socorro
 - Por determinação judicial (somente durante o dia)
- **Conceito de "casa" segundo o STF:**
 - Abrange domicílio residencial e profissional
 - Inclui locais privados não abertos ao público, como:

- Escritórios
- Consultórios médicos
- Quartos de hotel
- Lojas (back-office)
- Barcos, trailers, etc.

- **Decisões importantes do STF:**

- Busca e apreensão sem mandado → ilegal, salvo exceções.
- Flagrante delito exige **fundadas razões** (ex: tráfico de drogas).
- Veículos só são equiparados à residência se **servirem de moradia** (ex: trailer).
- Autoridades administrativas (fiscais, MP, etc.) só entram com mandado judicial ou consentimento.

- **Instalação de escuta ambiental:**

- Permitida com ordem judicial, inclusive à noite, quando não há habitação no local (ex: escritório vazio).
- STF pondera valores: intimidade × investigação criminal.

- **Mandado judicial "durante o dia":**

- Critério **astronômico**: enquanto o céu estiver claro.

Inviolabilidade das Comunicações (Art. 5º, XII, CF/88)

- **Abrangência do sigilo:**

- Correspondência
- Comunicações telegráficas
- Dados
- Comunicações telefônicas (únicas com **possível violação por ordem judicial**)

- **Exceções previstas:**

- Interceptação telefônica → **somente com ordem judicial**, para fins penais (Lei 9.296/96)
- Estados de Defesa (Art. 136) e de Sítio (Art. 139)
- Correspondência de presos pode ser aberta, com justificativa legal (Lei 7.210/84)

- **Diferença importante:**

- **Interceptação telefônica** → captação do conteúdo da conversa (só com ordem judicial)
- **Quebra de sigilo telefônico** → dados das ligações (quem ligou, quando, duração), pode ser feita até por CPI

- **Proibições:**

- Não cabe interceptação em:
- Processos civis (ex: divórcio)
- Processos administrativos

Liberdade do Exercício de Ofício ou Profissão (Art. 5º, XIII)

- Direito de exercer qualquer trabalho ou profissão, sujeito a qualificações estabelecidas por lei.
- Exigências para algumas profissões (médico, advogado) e não para outras (analista de sistemas, comunicador).
- **Jurisprudência do STF:** Considera inconstitucional a exigência de diploma de jornalismo para o exercício da profissão (RE 511.961).

Liberdade de Acesso à Informação e Sigilo da Fonte (Art. 5º, XIV)

- Direito de acesso à informação e proteção do sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (jornalista).
- **Jurisprudência do STF:** Protege a atuação do jornalista no caso de divulgação de informações da Lava-Jato, independentemente da investigação sobre a origem dos dados (RE 511.961).

Liberdade de Locomoção (Art. 5º, XV)

- Garantia de locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo entrar, permanecer ou sair com seus bens.
- Exceções: Forças militares estrangeiras, que só podem transitar com autorização do Presidente da República (Art. 49, II e Art. 84, XXII da CF).

Liberdade de Reunião (Art. 5º, XVI)

- Direito de reunir-se pacificamente, sem armas, em locais públicos, sem necessidade de autorização, apenas com aviso prévio à autoridade competente.
- **Jurisprudência do STF:**
 - Decisão de 2021: Manifestação espontânea não precisa de notificação oficial, apenas informação à autoridade (RE 806.339).
 - A reunião não será dissolvida se alguns participantes estiverem armados; a polícia deve intervir apenas nos responsáveis (ADPF 187/DF).
 - **Manifestação:** Uso de objetos sonoros não pode ser proibido em manifestações (Rcl 15.887 DF).
 - A reunião pode ser tanto estática quanto dinâmica, como passeatas ou manifestações, desde que pacíficas e lícitas.

Liberdade de Associação (Art. 5º, incisos XVII a XX)

- **Liberdade plena de associação:** As associações podem ser formadas para fins lícitos, mas associações de caráter paramilitar são proibidas (inciso XVII).
- **Criação de associações e cooperativas:** Não depende de autorização, e o Estado não pode interferir no funcionamento dessas entidades (inciso XVIII).
- **Dissolução compulsória e suspensão das atividades:** A dissolução compulsória de uma associação exige trânsito em julgado da decisão judicial, mas a suspensão das atividades pode ser determinada em decisão de primeiro grau (inciso XIX).
- **Liberdade de associação:** Ninguém pode ser obrigado a se associar ou permanecer em uma associação (inciso XX).

Representação Processual vs. Substituição Processual

- **Representação processual (Art. 5º, XXI):** Entidades associativas podem representar judicialmente seus membros, mas exigem **autorização expressa** dos filiados para isso.
- **Substituição processual:** Entidades como sindicatos têm **legitimidade ativa extraordinária**, podendo agir em nome de seus membros, mesmo sem autorização específica, quando **envolvem direitos coletivos** (exemplo: ação civil pública, mandado de segurança coletivo).
- **Distinção:** A representação requer uma autorização expressa dos associados, enquanto a substituição processual pode ser feita com autorização genérica (nos casos de ações coletivas).

Direito de Propriedade (Art. 5º, incisos XXII a XXVI)

- **Garantia de direito de propriedade:** O direito de propriedade é garantido pela Constituição, mas com limites, como a **função social** da propriedade (inciso XXIII) e as **possibilidades de intervenção estatal**, como a desapropriação (inciso XXIV) e a requisição administrativa (inciso XXV).
- **Desapropriação por função social:** A propriedade deve cumprir sua função social, caso contrário, pode ser desapropriada (art. 182 e 186).
- **Expropriação de propriedades por exploração de trabalho escravo:** A Emenda Constitucional 81/2014 permite a expropriação de propriedades onde seja constatada a exploração de trabalho escravo, sem indenização ao proprietário.
- **Intervenções:** O poder público pode usar propriedade particular em caso de perigo iminente (inciso XXV), com a devida indenização posterior se houver dano.

Direitos do Consumidor

- **Inciso XXXII do art. 5º:** O Estado promoverá a defesa do consumidor, norma constitucional de eficácia limitada.
- **Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990):** Regulamenta a defesa do consumidor, com entrada em vigor em 1991.
- **Outras leis relacionadas:** Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2005).

Direito de Informação, Petição e Certidões

- **Inciso XXXIII do art. 5º:** Direito de receber informações de órgãos públicos sobre interesse particular, coletivo ou geral, exceto informações sigilosas.
- **Controle social e participação política:** O direito de informação também permite fiscalização da gestão pública.
- **Art. 31, § 3º:** As contas dos Municípios devem estar à disposição dos contribuintes para exame e apreciação.
- **Inciso XXXIV do art. 5º:** Direito de petição aos poderes públicos e de obtenção de certidões.
- **Súmula Vinculante 21:** Inconstitucionalidade de exigência de depósito ou arrolamento prévios para admissibilidade de recurso administrativo.
- **Mandado de segurança:** Remédio jurídico para repressão ao descumprimento de direitos de informação, petição e certidão.
- **Habeas data:** Exclusivo para acesso a informações pessoais ou retificação de dados.

Direito de Propriedade Intelectual

- **Incisos XXVII, XXVIII e XXIX do art. 5º:** Proteção ao direito autoral e à propriedade industrial.
 - Direito exclusivo de utilização e reprodução das obras.
 - Privilégio temporário para invenções industriais e marcas.
 - Proteção dos direitos dos criadores, intérpretes e suas associações.

Direito de Herança

- **Incisos XXX e XXXI do art. 5º:** Garantia de direito à herança, regulado pela lei brasileira, com exceções para herdeiros de estrangeiros.
- **Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB):** Determina que a sucessão será regida pela lei do país de domicílio do falecido.

Inafastabilidade da Jurisdição

- **Inciso XXXV do art. 5º:** Acesso pleno ao Judiciário para defesa de direitos.

- **Jurisdição una no Brasil:** Toda demanda pode ser levada ao Judiciário, ao contrário de sistemas de jurisdição dual (como na França).
- **Exceções:** Jurisdição condicionada para habeas data, Justiça Desportiva e descumprimento de Súmula Vinculante.
- **Reclamação ao STF:** Caso a Administração Pública ou decisões judiciais contrariem Súmula Vinculante, deve-se esgotar a via administrativa antes de recorrer ao STF.

Direito Adquirido, Coisa Julgada e Ato Jurídico Perfeito

- **Inciso XXXVI do art. 5º:** A lei não retroagirá para prejudicar direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e coisa julgada.
- **Direito adquirido:** Proteção de direitos consolidados, não alcançando expectativas de direito.
- **Ato jurídico perfeito:** Direito que se concretizou sob a vigência de determinada lei.
- **Coisa julgada:** Decisão judicial irrecorrível, passível de revisão somente por ação rescisória no prazo de 2 anos.

Proteção dos Direitos e Liberdades Fundamentais (Art. 5º, XLI)

- A lei deve punir qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais.
- Esses direitos não são absolutos e podem ser limitados.

Crimes Constitucionalizados (Art. 5º, XLII a XLIV)

- **XLII – Racismo:** crime inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão.
- **XLIII – Tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos:** inafiançáveis e **insuscetíveis de graça ou anistia**.
- **XLIV – Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático:** inafiançável e imprescritível.

Mnemônicos úteis:

- **RAÇÃO** → Racismo + Ação de grupos armados → Inafiançáveis e imprescritíveis.
- **3T1H** → Tortura, Tráfico, Terrorismo, Hediondos → Inafiançáveis e sem graça/anistia.

Indulto, Graça e Anistia

- **Indulto:** Extinção da punibilidade. Concedido pelo Presidente, pode ser coletivo.
- **Graça:** Extinção da punibilidade. Concedida individualmente pelo Presidente.
- **Anistia:** Renúncia do Estado ao direito de punir. Aplica-se a fatos, não pessoas.
- **STF:** indulto e comutação de pena não se aplicam aos crimes do art. 5º, XLIII.

Princípios da Sucessão e Individualização da Pena (Art. 5º, XLV e XLVI)

- **XLV – Intranscendência da pena:** A pena não passa da pessoa do condenado.
- Reparação de dano pode ser cobrada dos sucessores até o valor herdado.
- **XLVI – Individualização da pena:** A lei adotará diferentes formas de pena.
-  STF: esse princípio aplica-se também à Administração Pública. Sanções não devem atingir:
 1. Entes federais por atos de entes da administração indireta.
 2. Poderes diversos.
 3. Gestores por atos de administrações anteriores (se sanadas irregularidades).
-  Inconstitucionalidade do §1º, art. 2º, Lei de Crimes Hediondos: vedação da progressão de regime fere individualização da pena.

Direitos Constitucionais do Preso (Art. 5º, XLVII a L)

- **XLVII – Proibição de penas:**

- de morte (salvo guerra declarada)
- perpétuas
- de trabalhos forçados
- de banimento
- cruéis
- **XLVIII** – Prisão em estabelecimentos distintos conforme idade, sexo e tipo de delito.
- **XLIX** – Respeito à integridade física e moral dos presos.
- **L** – Direito das presas de permanecerem com filhos durante a amamentação.
-  **Trabalho do preso:**
 - Obrigatório segundo a LEP (art. 39, V).
 - Recusa configura falta grave.
 - **Remição da pena:** 3 dias trabalhados = 1 dia de pena (art. 126, §1º da LEP).
 - Segundo o Pacto de 1969, trabalho do preso por decisão judicial não é considerado forçado.

Tratados e Extradicação

- Brasil aderiu ao Protocolo da ONU (1989) pela abolição da pena de morte, com reserva constitucional.
- STF condiciona extradicação:
 - à **comutação da pena de morte** para prisão.
 - à **comutação da pena perpétua** para no máximo 40 anos (art. 75, CP).

Uso de Algemas e Integridade Física

- STF: uso de algemas apenas com justificativa por escrito, sob pena de:
 - responsabilidade do agente.
 - nulidade do ato/prisão.
- **Súmula Vinculante 11:** uso lícito só com resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física.
- STF: uso em audiência é permitido se houver risco real.

Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa (Art. 5º, LV da CF/88)

- Garantias aplicáveis tanto em processos **judiciais** quanto **administrativos**.
- São **indissociáveis** e corolários do **devido processo legal**.
- Compreendem direitos como: defesa técnica, publicidade, citação, produção de provas, recursos, acesso aos autos etc.

Inquérito Policial

- Natureza: procedimento administrativo e sigiloso.
- Não exige contraditório e ampla defesa.
- **Súmula Vinculante 14/STF:** garante ao advogado acesso às provas já documentadas.

Ampla Defesa

- Inclui o direito a usar todos os meios de prova lícitos, e o direito ao silêncio.
- **Defesa técnica** não é obrigatória no PAD (Súmula Vinculante 5/STF), mas a ausência total de defesa **anula a punição**.

Contraditório

- Direito de conhecer e se manifestar sobre alegações e provas contrárias.
- Prescinde de manifestação efetiva: basta **oportunizar** a manifestação.

- Exceções: ex. sindicância prévia ao PAD, onde não se exige contraditório.
- Instaurado com a **citação válida** ou comunicação formal.

Duplo Grau de Jurisdição

- **Não é garantia constitucional absoluta.**
- **STF:** só é exigível quando previsto em **lei**.
- Exemplo: senadores julgados diretamente pelo STF não têm direito a outro grau.
- **Pacto de San José da Costa Rica** não se sobrepõe à Constituição (AP 470, 2012).
- **Súmula 704/STF:** conexão ou continência não fere garantias.

Contraditório no TCU

- **Súmula Vinculante 3/STF:** assegurado quando a decisão puder anular/revogar ato benéfico.
- Exceção: atos de **concessão inicial** de aposentadoria.
- Nova orientação: se o TCU **demorar mais de 5 anos**, deve assegurar o contraditório por força da **razoabilidade e segurança jurídica**.

Aplicação Horizontal dos Direitos Fundamentais

- STF reconhece aplicação da ampla defesa e contraditório também em **relações privadas** (RE 201.819/RJ, 2005).

Provas Ilícitas (Art. 5º, LVI da CF/88 e Art. 157 do CPP)

- São inadmissíveis: obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
- **Provas por derivação** também são inadmissíveis (fruits of the poisonous tree).
- Exceções:
 - **Fonte independente.**
 - **Ausência de nexo causal.**
- **Diferença:**
 - **Ilícitas:** violam normas constitucionais/material → inadmissíveis.
 - **Ilegítimas:** violam normas processuais → podem ser refeitas.
- **Jurisprudência:**
 - Prova de interceptação por juiz **incompetente: ilícita** (Inq 3.732).
 - Mas se o juiz era **competente à época**, a prova **não é ilícita** (HC 81.260-ES).

Presunção de Inocência (Art. 5º, LVII)

- Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado.
- Identificação criminal (Art. 5º, LVIII): proibida para civilmente identificado, salvo previsão legal.
- STF oscilou quanto à possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado.

📌 Pressupostos da Prisão (CF, art. 5º, LXI a LXVII)

- **LXI** – Ninguém será preso senão:
 - Em **flagrante delito**;
 - Por **ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente**;
 - Exceções: transgressão/crime militar, estado de defesa, estado de sítio, recaptura de evadido (CPP, art. 684).
- Vedação à prisão administrativa para averiguação, exceto:

- Decisão da 1ª Turma do STF (2014): **condução coercitiva para investigação** pode ocorrer, com garantias constitucionais (HC 107.644).

- **Motivação da prisão preventiva:**

- Deve ser **concreta e contemporânea**;
- **Informações posteriores não suprem falhas de fundamentação** (HC 90.064/SP; HC 84.293/SP).

- **Colaboração premiada:**

- **Não justifica por si só a revogação da preventiva**;
- **Descumprimento do acordo não autoriza decretação automática da prisão** (HC 138.207/PR).

✚ **Direitos do Preso**

- **LXII** – Comunicação imediata da prisão ao juiz e à família/pessoa indicada;
- **LXIII** – Informação sobre direitos, inclusive o de **permanecer calado**, e direito à assistência da família e advogado;
- **LXIV** – Direito à **identificação dos responsáveis** pela prisão/interrogatório.

✚ **Prisões ilegais e liberdade provisória**

- **LXV** – Prisão ilegal será **imediatamente relaxada** pela autoridade judiciária;
- **LXVI** – Ninguém será mantido preso se a lei permitir **liberdade provisória, com ou sem fiança**.

✚ **Prisão Civil por Dívida (LXVII)**

- Regra: **Vedada a prisão por dívida**, salvo:
 - Inadimplemento **voluntário e inescusável de obrigação alimentícia**;
 - **Depositário infiel** (⚠ atualmente inaplicável).
- ✚ Evolução da prisão do depositário infiel:
 - **1988** – CF previu duas hipóteses de prisão civil;
 - **1992** – Brasil ratifica o **Pacto de San José da Costa Rica** (prevê apenas prisão por dívida alimentar);
 - **1997** – STF: tratados = lei ordinária;
 - **2004** – EC 45: tratados podem ter status constitucional se aprovados pelo rito especial;
 - **2008** – STF: tratados de direitos humanos têm **status supralegal** (abaixo da CF, acima da lei);
 - Conclusão: **vedada a prisão do depositário infiel**.
 - **Súmula Vinculante 25/STF**: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.”

✚ **Assistência Jurídica Gratuita (LXXIV)**

- Direito à assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados;
- Exercida pela **Defensoria Pública** (art. 134, CF);
- **STF**: omissão estatal na implantação da Defensoria **compromete direitos fundamentais**.

✚ **Indenização por Erro Judiciário (LXXV)**

- **Estado deve indenizar**:
 - Condenado por **erro judiciário**;
 - Preso **além do tempo da sentença**;
- **Não caracteriza erro judiciário**: prisão preventiva fundamentada, mesmo que posteriormente revertida (RE 429.518/SC).
- **Responsabilidade do juiz** (CPC/2015, art. 143):

- Dolo ou fraude;
- Recusa, omissão ou demora injustificada em providência judicial.

✦ **Gratuidades (LXXVI e LXXVII)**

- **LXXVI** – Gratuidade para reconhecidamente pobres:
 - a) Registro civil de nascimento;
 - b) Certidão de óbito.
- STF: cartórios têm natureza privada, mas atividade é de interesse público – **gratuidade constitucional é válida (ADC 5)**.

Celeridade Processual (CF, art. 5º, LXXVIII)

- **Previsão constitucional: Art. 5º, LXXVIII** — assegura a todos a **razoável duração do processo** e os meios que garantam a **celeridade de sua tramitação**, tanto no âmbito **judicial quanto administrativo**.
- **Inclusão:** Pela **Emenda Constitucional 45/2004**.
- **Natureza da norma:** De aplicação plena e imediata.
- **STF não define objetivamente** o que é "razoável duração", mas possui jurisprudência relevante:
 - **RMS 28.172:** A garantia se aplica **também na esfera administrativa**.
 - **HC 99.425:** Extrapola o razoável quando recurso de apelação **não é julgado após quase 2 anos e meio**.
 - **HC 100.574:** Mesmo em **crimes hediondos, o excesso de prazo não pode ser tolerado**; prisão cautelar deve ser revogada.
 - **HC 97.461:** Excesso de prazo **não é mera conta de tempo** — considera complexidade do caso, número de réus, atos protelatórios, etc.

Proteção de Dados Pessoais (CF, art. 5º, LXXIX)

- **Previsão constitucional: Art. 5º, LXXIX** — garante o direito à **proteção de dados pessoais**, inclusive nos meios digitais.
- **Inclusão:** Pela **Emenda Constitucional nº 115/2022**.
- **Abrangência:** Protege dados armazenados **fisicamente e digitalmente**.
- **Definição:** Dados pessoais são informações que **identificam ou podem identificar** uma pessoa (nome, endereço, dados bancários, hábitos de navegação etc).
- **Importância atual:** A evolução tecnológica aumentou o uso e o risco no tratamento de dados, tornando a proteção **ainda mais essencial**.
- **Regulamentação infraconstitucional:** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (**LGPD**).
 - Define regras sobre **coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento** de dados.
 - Garante **transparência, segurança e privacidade** ao titular dos dados.
- **Finalidade da inclusão constitucional:**
 - Reforçar a **privacidade como direito fundamental**.
 - Proteger contra o **uso indevido** de informações pessoais.
 - Atualizar a legislação frente aos **avanços tecnológicos e ao uso massivo de dados**.

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
